27/10/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS, ARRANJADORES E REGENTE AMAR - SOMBRÁS - SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA E OUTRO(A/S)
REQTE.(S)	: ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS
REQTE.(S)	: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - SBACEM
REQTE.(S)	: SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM
REQTE.(S)	: SOCINPRO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS
REQTE.(S)	: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
ADV.(A/S)	: PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S)	: SYDNEY LIMEIRA SANCHES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S)	: RODRIGO BRANDAO VIVEIROS PESSANHA E OUTRO(A/S)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

ADMINISTRATIVO. GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS. LEI Nº 12.583/2013. NOVO MARCO REGULATÓRIO SETORIAL. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÕES FORMAIS E MATERIAIS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. ESCOLHAS REGULATÓRIAS TRANSPARENTES E CONSISTENTES. MARGEM DE CONFORMAÇÃO LEGISLATIVA RESPEITADA. DEFERÊNCIA JUDICIAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A interpretação ampliativa dos princípios constitucionais não deve se convolar em veto judicial absoluto à atuação do legislador ordinário, que também é um intérprete legítimo da Lei Maior, devendo, nesse mister, atuar com prudência e cautela de modo que a alegação genérica dos direitos fundamentais não asfixiem o espaço político de deliberação coletiva.

2. A gestão coletiva de direitos autorais e a coexistência da participação do Estado assumem graus variados em diferentes democracias constitucionais [GERVAIS, Daniel (org.) *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Alphen aan Den Rijn: Kluwer Law International, 2nd Edition, 2010], o que sugere não existir um modelo único, perfeito e acabado de atuação do Poder Público, mas, ao revés, um maior ou menor protagonismo do Estado, dependente sempre das escolhas políticas das maiorias eleitas.

3. A Constituição de 1988 não estabeleceu prazos mínimos para tramitação de projetos de lei, nem disciplinou o regime urgente de deliberação, circunstância que confere espaço suficiente para o legislador imprimir aos seus trabalhos a cadência que reputar adequada. A interferência judicial no âmago do processo legislativo, para justificar-se, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto expresso das normas da Constituição da República. Inexistência de ofensa formal à Lei Maior.

4. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, impõe a divulgação de informações concernentes à execução pública de obras intelectuais, notadamente músicas, e à arrecadação dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

respectivos direitos (art. 68, §§ 6º e 8º, e art. 98-B, I, II e parágrafo único), além de vedar a pactuação de cláusulas de confidencialidade nos contratos de licenciamento (art. 98-B, VI), estabelecendo penalidades em caso de descumprimento (art. 109-A).

5. O cânone da proporcionalidade encontra-se consubstanciado nos meios eleitos pelo legislador, voltados à promoção da transparência da gestão coletiva de direitos autorais, finalidade legítima segundo a ordem constitucional brasileira, porquanto capaz de mitigar o viés rentista do sistema anterior e prestigiar, de forma imediata, os interesses tanto de titulares de direitos autorais (CRFB, art. 5º, XXVII), dos usuários (CRFB, art. 5º, XXXII) e, de forma mediata, bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual como a educação e o entretenimento (CRFB, art. 6º), o acesso à cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB, art. 5º, XIV).

6. O art. 97, §1º, da Lei nº 9.610/1998, com a redação dada pela Lei nº 12.853/2013, estabelece que as associações de titulares de direitos autorais exercem atividade de interesse público e devem atender a sua função social, ocupando, assim, um espaço público não-estatal, conforme sedimentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 201.819 (red. p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, rel. Originária, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11/10/2005, DJ 27-10-2006).

7. As entidades de gestão coletiva possuem a evidente natureza instrumental de viabilizar trocas voluntárias envolvendo propriedade intelectual, dadas as dificuldades operacionais que marcam o setor. Destarte, tanto a produção de cultura (pelos autores) quanto o acesso à cultura (pelos usuários) dependem do hígido funcionamento das associações arrecadadoras e distribuidoras de direitos. Esse relevante papel econômico é traduzido juridicamente como a função social das aludidas entidades, cuja importância social justifica o interesse público na sua existência e escorreita atuação.

8. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, limita aos titulares originários (art. 5º, XIV) o direito de voto (art. 97, §5º) e a assunção de cargos de direção nas associações de gestão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

coletiva (art. 97, §6º); cria regras sobre a eleição de dirigentes das entidades (art. 98, §§13 e 14) e estabelece critério de voto unitário no ECAD (art. 99, §1º e art. 99-A, parágrafo único).

9. Os titulares originários e titulares derivados de obras intelectuais são diferenciados legalmente, para fins de participação na gestão coletiva de direitos autorais, sendo certo que o *distinguishing*, situa-se dentro da margem de conformação do legislador ordinário para disciplinar a matéria, uma vez que (i) não existe direito constitucional expresso à participação política ou administrativa de titulares derivados na gestão coletiva, ao contrário dos titulares originários (CRFB, art. 5º, XXVIII, *b*); (ii) as regras impugnadas não impactam os direitos patrimoniais dos titulares derivados, que continuam a gozar das mesmas expressões econômicas de que desfrutavam até então; (iii) a importância relativa dos titulares originários é maior para a criação intelectual, cujo estímulo é a finalidade última da gestão coletiva; (iv) é justificável, antes os fatos apurados, a existência de regras voltadas a minimizar a assimetria de poder econômico entre editoras musicais e autores individuais, os verdadeiros criadores intelectuais.

10. O marco regulatório, *sub examine*, exige a habilitação prévia das associações de gestão coletiva em órgão da Administração Pública federal para a cobrança de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998, art. 98, §1º), segundo procedimento fixado pela própria Lei (art. 98-A).

11. A novel legislação considera habilitadas as associações já existentes na entrada em vigor do diploma (Lei nº 12.853/2013, art. 4º e 6º), as quais devem adaptar seus estatutos em prazo determinado (Lei nº 12.853/2013, art. 5º); e atribuí ao Ministério da Cultura o poder de regulamentar a gestão coletiva (Lei nº 12.853/2013, art. 7º e 8º).

12. A transindividualidade da gestão coletiva, revela a sua inequívoca importância, ao envolver interesses de usuários e titulares, justifica a presença regulatória maior do Estado na criação, na organização e no funcionamento das entidades que operam no setor, o que se traduz na incidência de disciplina jurídica específica.

13. A exigência de habilitação prévia configura típico exercício de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

poder de polícia preventivo, voltado a aferir o cumprimento das obrigações legais exigíveis desde o nascedouro da entidade.

14. Sob o prisma da máxima *tempus regit actum*, as associações arrecadadoras já existentes devem conformar-se à legislação em vigor, sujeitando-se às alterações supervenientes à sua criação, dado que (i) as regras de transição são justas e (ii) não existe direito adquirido a regime jurídico na ordem constitucional brasileira.

15. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013 prevê regras para a negociação de preços e formas de licenciamento de direitos autorais (art. 98, §§ 3º e 4º), bem como para a destinação de créditos e valores não identificados (art. 98, §§10 e 11), fixando prazo mínimo para que os titulares comuniquem às respectivas associações a intenção em arrecadar pessoalmente os seus direitos (art. 98, §15).

16. O tratamento normativo não estipula tabelamento de valores, limitando-se a fixar parâmetros genéricos (razoabilidade, boa fé e usos do local de utilização das obras) para o licenciamento de direitos autorais no intuito de corrigir as distorções propiciadas pelo poder de mercado das associações gestoras, sem retirar dos próprios titulares a prerrogativa de estabelecer o preço de suas obras.

17. O licenciamento pelo formato global ou cobertor (*blanket license*) permanece válido, desde que não seja mais o único tipo de contrato disponível. Ademais, o prazo mínimo para a comunicação permite que a associação, ao proceder à cobrança de seu repertório, possa excluir os valores referentes ao titular que atue pessoalmente, minimizando as chances de falhas de comunicação que propiciem duplicidade de cobrança e tumultuem a gestão coletiva.

18. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013: a) exige que as associações mantenham e disponibilizem, por meio eletrônico, cadastro centralizado de dados relativos aos direitos autorais (art. 98, §6º), assegurando ao Ministério da Cultura acesso contínuo e integral a tais informações (art. 98, §7º); b) atribuí ainda ao Ministério da Cultura o papel de arbitrar eventuais conflitos e de retificar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

as informações necessárias (art. 98, §8º).

19. O cadastro unificado de obras justifica-se como forma de (i) prevenir a prática de fraudes e (ii) evitar a ocorrência de ambiguidades quanto à participação individual em obras com títulos similares; problemas esses que vicejavam ante a pouca transparência da sistemática anterior.

20. O modelo regulatório admite a atuação pessoal de cada titular na arrecadação de seus direitos. Por isso que é de interesse de qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter conhecimento acerca das participações individuais nas obras.

21. O acesso de qualquer interessado ao Poder Judiciário (CRFB, art. 5º, XXXV) não foi violado pela possível retificação do cadastro pelo Ministério da Cultura que evita a prematura judicialização de eventuais conflitos, além de permitir o enfrentamento da controvérsia a partir de perspectiva técnica e especializada.

22. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, estabelece critérios para a fixação da taxa de administração praticada pelas associações (art. 98, §12) bem como para a distribuição aos autores dos valores arrecadados (art. 99, §4º), além de limitar o poder de os associados deliberarem sobre a utilização dos recursos recolhidos pelas entidades que integram (art. 98, §16).

23. As taxas de administração e a fixação limites máximos justificam-se pela estrutura econômica do setor, que, apesar de franquear espaço para ganhos de escala nas atividades de arrecadação e distribuição, não se traduzia em benefício aos titulares originários de direitos autorais. A nova sistemática, lastreada em sólidas premissas empíricas, procura reconduzir as entidades de gestão coletiva ao seu papel puramente instrumental.

24. Deveras, o limite para despesa pelas associações com ações que beneficiem seus associados de forma coletiva equilibra, com moderação, a tensão latente entre interesses individuais e coletivos na criação de obras intelectuais.

25. O art. 99, §7º, da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.853/2013, impõe um dever de cooperação às associações que percam a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

respectiva habilitação para atuar na gestão coletiva de direitos autorais, as quais, em virtude de sua essência instrumental, deverão transferir todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos, evitando solução de continuidade na tutela dos direitos autorais.

26. As associações surgem para viabilizar o mercado, não sendo admitido interromper seu hígido funcionamento, inclusive no momento em deixam de operar no setor, razão pela qual, a Lei nº 12.853/2013 apenas zelou pela transição razoável e menos traumática para usuários e titulares.

27. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013: **a)** estabelece que as associações de gestão coletiva deverão prestar contas dos valores recebidos aos seus associados (art. 98-C, *caput*), os quais, embora ostentem legitimidade para exercer a fiscalização diretamente (art. 98-C, §1º), podem provocar o Ministério da Cultura em sua defesa caso não sejam atendidos de plano (art. 98-C, §2º); e **b)** prevê que compete a órgão da Administração Pública Federal o poder de arbitrar conflitos entre usuários e titulares de direitos autorais bem como entre titulares e suas associações a respeito de direitos disponíveis (art. 100-B).

28. A mediação e a arbitragem, enquanto métodos voluntários e alternativos à jurisdição estatal, (i) minimizam a demanda pelo Poder Judiciário e (ii) propiciam a análise dos conflitos intersubjetivos por técnicos e especialistas no tema.

29. A novel disciplina legal deixa evidente o caráter voluntário da submissão de eventuais litígios aos procedimentos alternativos de solução perante órgão da Administração Pública federal. Essa voluntariedade decorre diretamente da Constituição da República (CRFB, art. 5º, XXXV), como reconhecido pelo STF (SE nº 5.206) e devidamente respeitado pelo legislador ordinário (Lei nº 9.610/1998, art. 100-B), pelo Chefe do Poder Executivo federal (Decreto nº 8.469/2015, art. 25) e pelo Ministério da Cultura (IN nº 4/2015, art. 2º).

30. O art. 99-A da Lei n° 9.610/1998, introduzido pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013, autoriza órgão da Administração Pública federal a tornar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

obrigatória a admissão de associados no ECAD, desde que sejam habilitados previamente para desempenhar a gestão coletiva e haja pertinência entre as áreas de atuação.

31. A previsão legal impede que as associações já estabelecidas na gestão coletiva possam asfixiar a criação de novas entidades mediante políticas de alijamento junto ao ECAD, que ostenta, por força de lei, o monopólio da arrecadação e da distribuição de direitos relativos à execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas (Lei nº 9.610/1998, art. 99).

32. A criação de novas entidades coletivas impõe pressão competitiva sobre as associações já atuantes, que tenderão a ser mais eficientes, oferecendo serviço de qualidade e com maior retorno para seus associados.

33. O monopólio legal que favorece o ECAD, entrevisto como bônus, sofre a incidência da contrapartida consistente no dever de admitir toda e qualquer entidade legalmente habilitada.

34. A legitimidade ativa *ad causam* para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade é reconhecida às entidades de classe de âmbito nacional (CRFB, art. 103, IX), que, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem congregar associados homogêneos, assim compreendidos os sujeitos de direito integrantes de uma mesma categoria profissional ou econômica (*leading case*: ADI nº 42, rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, j. 24/09/1992, DJ 02-04-1993).

35. *In casu*, a União Brasileira de Compositores revela homogeneidade da classe formada por seus membros, pertencentes à categoria econômica diferenciada que compreende os **titulares de direitos autorais e conexos, cujas obras estão submetidas à execução pública e sujeitas à gestão coletiva**, setor da vida social alvo de profundas transformações a partir da edição da Lei nº 12.853/2013.

36. Pedido conhecido e julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, em julgar improcedentes os pedidos formulados, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 27 de outubro de 2016.

LUIZ FUX - RELATOR

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384509.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS, ARRANJADORES E REGENTE AMAR - SOMBRÁS - SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA E OUTRO(A/S)
REQTE.(S)	: ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS
REQTE.(S)	: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - SBACEM
REQTE.(S)	: SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM
REQTE.(S)	: SOCINPRO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS
REQTE.(S)	: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
ADV.(A/S)	: PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S)	: SYDNEY LIMEIRA SANCHES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S)	: RODRIGO BRANDAO VIVEIROS PESSANHA E OUTRO(A/S)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384510.

ANTECIPAÇÃO AO RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor Presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre Representante do Ministério Público, Senhores Advogados, Estudantes presentes e demais Autoridades e presentes.

Senhor Presidente, Vossa Excelência apregoou, em conjunto, as duas, porque, na essência, elas realmente versam sobre o mesmo tema. A única diferença é que há uma alegação de inconstitucionalidade formal na 5.065. Então, eu vou ler o relatório da 5.062 e acrescer só essa diferença que há no 5065.

E também, Senhor Presidente, vou utilizar da metodologia que temos utilizado. Qual seja, eu vou fazer um relatório neutro, e aquilo que as partes têm de alegar, elas o farão da tribuna. Com isso ganhamos tempo, e as partes também vão ter mais disponibilidade para fazer as suas sustentações, dentro de um prazo dividido, quando houver mais de um *amicus curiae*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384510.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA E OUTRO(A/S)
REQTE.(S)	: ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S)	: SYDNEY LIMEIRA SANCHES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S)	: RODRIGO BRANDÃO VIVEIROS PESSANHA E OUTRO(A/S)

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuida-se de julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade autuadas sob os números 5.062 e 5.065, ajuizadas por diferentes associações civis (abaixo discriminadas), ambas em face de dispositivos da Lei nº 9.610/1998 a seguir enumerados, todos alterados ou introduzidos pela Lei nº 12.853/2013, que reconfigurou o marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil.

Na ADI nº 5.062, as associações requerentes são as seguintes: (*i*) **ABRAMUS** (Associação Brasileira de Música e Artes), (*ii*) **AMAR-SOMBRÁS** (Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes / Sociedade Musical Brasileira), (*iii*) **ASSIM** (Associação de Intérpretes de Músicos),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

(*iv*) **SBACEM** (Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música), (*v*) **SICAM** (Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais), (*vi*) **SOCINPRO** (Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais), (*vi*) **ECAD** (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Os dispositivos impugnados são os arts. **5º, 68, 97, 98, 98-A, 98-B, 98-C, 99, 99-A, 99-B, 100, 100-A, 100-B e 109-A** da Lei nº 9.610/1998 com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, bem como os arts. **4º, 5º, 6º, 7º e 8º** da própria Lei nº 12.853/2013.

Na ADI nº 5.065, a associação requerente é a **UBC** (União Brasileira de Compositores). Os dispositivos impugnados são os arts. **5º; 68, §6º; 97, §§ 1º, 5º, 6º; 98, §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 13, 14, 16; 99, §§ 1º, 4º, 8º, 9º; 98-A, III, §§ 1º, 2º, 3º; 98-C, §2º; 99-A, § único; 99-B; 100-A; e 100-B** da Lei nº 9.610/1998 com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013.

Transcrevo o teor dos dispositivos questionados, seguidos pelos fundamentos que motivaram ambas as demandas aqui reunidas. Em prol da racionalização do julgamento, optei por agrupar as previsões legais questionadas em razão de afinidade temática, tal como apresentado na inicial da ADI nº 5.062.

> **Art. 68**. (…)
>
> §6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede.
>
> (...)
>
> §8º Para as empresas mencionadas no §7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6º será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

fonogramas utilizados no mês anterior.

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão:

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;

II - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua retenção;

(…)

VI - garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade;

(…)

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser atualizadas periodicamente, em intervalo nunca superior a 6 (seis) meses.

As requerentes da ADI nº 5.062 sustentam que os dispositivos impugnados *"tornam públicas informações de natureza privada concernentes à execução pública de obras musicais e à arrecadação dos respectivos direitos, vedam a pactuação de cláusulas de confidencialidade e estabelecem penalidades"*. Segundo a argumentação articulada, tais previsões *"violam, de maneira direta e frontal, o disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal"*, bem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

como os arts. 1º e 170 da Lei Maior.

Particularmente, a inicial aponta que *"a norma tem origem, segundo a exposição de motivos do respectivo projeto de lei, na intenção do legislador de dar transparência ao sistema"*, mas acaba por se revelar *"desproporcional e inadequada, na medida em que a transparência quanto às informações referentes aos valores pagos deve ser – e já é – garantida apenas aos integrantes das Associações, que são os titulares dos direitos a serem repartidos"*. Ademais, *"ao vedar a celebração de contratos com cláusula de confidencialidade, a Lei nº 12.853/2013 restringe o direito à liberdade de contratar, que, por sua vez, é integrante do princípio da livre iniciativa"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC afirma que *"a divulgação dessas informações permitirá que toda e qualquer pessoa tome conhecimento dos rendimentos dos titulares de direitos autorais, matéria de natureza privada, pessoal e abrigada em seu aspecto personalíssimo"*. E conclui: *"flagrante, pois, a violação aos incisos X e XII, do artigo 5º, da CF"*.

> **Art. 97**. (...)
>
> §1º As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função social.

Na ADI nº 5.062, as requerentes apontam que *"com o intuito de justificar a indevida intervenção estatal nas atividades das Associações e do ECAD, limitando a liberdade dos titulares de direitos autorais de definir as regras aplicáveis às suas respectivas associações e de dispor livremente dos direitos de natureza privada que integram seu patrimônio"*, o dispositivo em referência qualifica como de "*interesse público*" as atividades exercidas pelas Associações. Aduz que, no caso, *"não há interesse público envolvido"*, uma vez que *"a referida lei trata exclusivamente de direitos privados e disponíveis por seus respectivos titulares, assim como regula as relações, igualmente de direito privado, entre esses titulares e as Associações* (…) *e entre os titulares* (...) *e os usuários das obras musicais"*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

Afirmam então que, *"não sendo o exercício dos direitos autorais por seus respectivos titulares de 'interesse público', o Estado está impedido de tutelar esses direitos, sob pena de intervenção indevida nas liberdades individuais, no direito de propriedade e na Ordem Econômica fundada na livre iniciativa"*. Questiona o dispositivo legal em referência por violação aos arts. 1º; 5º, XXII, XXVII, XXVIII; e 170, todos da Constituição da República.

Na ADI nº 5.065, a UBC defende que suas atividades não se adequam *"ao conceito de associação de interesse público"*, tendo em vista os critérios da Lei nº 9.790/1990, que *"dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público"*. Sustenta que *"o conceito de interesse público importa no entendimento de que o bem comum obriga e representa o interesse de toda a coletividade"*. Enfatiza que não é este o caso das associações de gestão coletiva de direitos autorais, as quais *"têm por finalidade à defesa, administração, cobrança e distribuição dos direitos autorais dos titulares de obras musicais e de fonogramas"*. Daí que *"a Lei 12.853/2013, ao tentar dar natureza pública a essa atividade, além de ferir norma específica relativa ao terceiro setor, interfere na forma de organização das entidades, dando azo a cristalina inconstitucionalidade, alimentada pelo artigo 5º , XVIII, da CF"*.

> **Art. 5º (…)**
>
> XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.
>
> **Art. 97**. (...)
>
> §5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo.
>
> §6º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo.

Art. 98. (...)

§13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 (três) anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição.

§14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros.

Art. 99. (…)

§1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no *caput* não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra.

Art. 99-A. (...)

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador.

As requerentes da ADI nº 5.062 sustentam que os dispositivos impugnados *"eliminam o direito de voto de parte dos titulares de direitos autorais nas Associações; criam regras sobre a eleição de dirigentes das Associações e estabelecem critério de voto unitário no ECAD, conferindo poder desproporcional de representação a alguns titulares de direitos autorais"*. Segundo a argumentação articulada, tais previsões violam a *liberdade de associação* (CRFB, art. 5º, XVII, XVIII e XIX), a garantia da *transmissibilidade* dos direitos autorais (CRFB, art. 5º, XXVII), o princípio da *isonomia* (CRFB, art. 5º, *caput*), bem como a *propriedade privada* como princípio geral da Ordem Econômica (CRFB, art. 5º, XXII e art. 170, II).

Mais especificamente, a inicial registra que *"todas as disposições acima representam uma tutela estatal direta e indevida ao direito dos integrantes das*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

Associações estabelecerem as regras aplicáveis aos seu funcionamento (...)", no que tem destaque *"a interferência no próprio direito de votar e ser votado"*. Explica que *"as Associações não são formadas apenas por titulares originários"* e que, *"sendo os direitos patrimoniais sobre obras musicais disponíveis, é lícito ao titular originário cedê-lo a quem bem o quiser"*. A Lei nº 12.853/2013 *"retira de parte dos titulares de direitos autorais (aqueles não qualificados como originários) o poder de influir sobre a forma de disposição de seus direitos"*, o que resulta, segundo a exordial, *"na expropriação parcial do direito de propriedade imaterial dos titulares não originários"*, bem como na criação de um tipo de *"associados em segunda classe, sem voz ou voto"*.

Argumentam ainda que *"igualmente violadoras do direito de propriedade e do princípio da isonomia são as normas que atribuem um único voto a cada uma das Associações nas assembleias do ente arrecadador (o ECAD), seja para fins de sua direção e administração (art. 99, §1º, da Lei nº 9.610/98), seja para o efeito de deliberar quanto à distribuição dos valores arrecadados (art. 99-A, parágrafo único, da Lei nº 9.610/98)"*. Consoante a inicial, *"o sistema associativo deve assegurar"* proporcionalidade nas deliberações coletivas, porém *"o voto unitário, por Associação, em cada uma dessas deliberações, retira essa proporcionalidade"*.

Especialmente quanto ao art. 5º, XIV, apontam que *"esse dispositivo foi introduzido na Lei n° 9.610/98, exclusivamente, em razão de o art. 97, §§ 5° e 6°, ter sido alterado para, de forma inconstitucional,* (...) *impor restrições aos direitos dos titulares 'não originários'."* Sustentam ainda que *"a norma, portanto, torna-se inútil com a declaração de inconstitucionalidade do art. 97, §§ 5° e 6°, da Lei n° 9.610/98, com a redação que decorre do art. 2° da Lei n° 12.853/2013"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC afirma que os §§ 5º e 6º do art. 97 retiram *"dos denominados titulares de direitos patrimoniais, tais como editores de música, sucessores e cessionários de direitos, qualquer ingerência, participação, voz e voto nas assembleias das associações de gestão coletiva de direitos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

patrimoniais". Aos olhos da entidade, cuida-se *"de interferência descabida na organização das entidades de gestão coletiva"*. Aduz ainda que *"a própria Lei reconhece no §5º, do artigo 98, que as associações deverão 'tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual', mas, paradoxalmente, confere tratamento desigual aos titulares de direitos patrimoniais de natureza derivada, decorrente da transferência de direitos patrimoniais"*.

Em relação ao art. 98, §§ 13 e 14, a UBC afirma tratar-se de *"clara violação ao artigo 5º, XVIII, da CF"*, uma vez que *"a forma de organização das associações de gestão coletiva é matéria estranha à Lei, posto que regulada pelos artigos 53 a 61, do Código Civil, dentro do ambiente eminentemente privado"*. Sustenta que *"a definição da periodicidade eletiva, prazos ou a recondução de cargo eletivo é matéria a ser definida no Estatuto de cada associação"*.

Quanto ao art. 99, §1º, e ao art. 99-A, parágrafo único, a UBC assevera que os dispositivos violam o *"artigo 5°, XVIII e XXII, da CF"*, na medida em que *"não pode a Lei determinar como se estrutura uma entidade privada, criada com o patrimônio privado de outras associações congêneres, que administram direitos autorais de titulares de direitos autorais, sob pena de provocar a própria falência do sistema"*. Defende que "*o voto proporcional afasta qualquer possibilidade de haver desequilíbrio no sistema unificado de arrecadação e distribuição de direitos autorais"*. Nesse contexto, a imposição de voto unitário no ECAD configuraria *"uma verdadeira desapropriação de direitos"*.

> **Art. 98** (...)
>
> §1º O exercício da atividade de cobrança citada no *caput* somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.
>
> §2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará:

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição;

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações:

a) cadastros das obras e titulares que representam;

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios, quando aplicável;

c) estatutos e respectivas alterações;

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias;

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes;

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável;

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável;

h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável;

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de 1 (um) ano e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos do art. 100;

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica dos associados;

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados;

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte.

§ 1º Os documentos e informações a que se referem os incisos II e III do *caput* deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura.

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e por seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei, assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público.

§ 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se concederá prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente.

§ 4º A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora.

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

autoridade competente, ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as informações previstos nos incisos II e III deste artigo.

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão (...).

III- buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos;

IV - oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço dos seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica;

V- aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição;

(…)

VII - garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas.

Lei nº 12.853/2013

Art. 4º As associações de gestão coletiva de direitos autorais que, antes da vigência da presente Lei, estejam legalmente constituídas e arrecadando e distribuindo os direitos autorais de obras e fonogramas considerar-se-ão habilitadas para exercerem a atividade econômica de cobrança pelo prazo definido em regulamento, devendo obedecer às disposições constantes do art. 98-A da Lei nº 9.610, de 1998.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> **Art. 5º** As associações a que se refere o art. 4º desta Lei terão 60 (sessenta) dias para adaptar seus estatutos ao § 13 do art. 98 da Lei nº 9.610, de 1998, permitindo-se que seus dirigentes concluam os mandatos em curso quando do início da vigência desta Lei até o prazo originalmente previsto, após o qual poderão candidatar-se para mandato de 3 (três) anos, com possibilidade de 1 (uma) recondução, nos termos desta Lei.
>
> **Art. 6º** Desde que se comprove a observância de todas as exigências para a constituição do novo ente arrecadador unificado, constantes do caput do art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998, as associações referidas no art. 4º desta Lei poderão requerer ao Ministério da Cultura, no prazo estabelecido em regulamento, que reconheça a pessoa jurídica já constituída como ente arrecadador.
>
> **Art. 7º** O Ministério da Cultura constituirá, no prazo e nos termos dispostos em regulamento, comissão permanente para aperfeiçoamento da gestão coletiva, que promoverá o aprimoramento contínuo da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil por meio da análise da atuação e dos resultados obtidos pelas entidades brasileiras, bem como do exame das melhores práticas internacionais.
>
> **Art. 8º** Admite-se a delegação, pelo Ministério da Cultura, das competências a ele atribuídas por esta Lei a outro órgão.

As requerentes da ADI nº 5.062 noticiam que os dispositivos impugnados *"exigem a habilitação prévia das Associações e do ECAD em órgão da Administração Pública Federal para o exercício de suas atividades institucionais, condicionada à observância de normas legais e regulamentares referentes à sua organização; e atribuem ao Ministério da Cultura e/ou a órgão da Administração Pública Federal o poder de regulamentar a gestão coletiva, monitorar as Associações e o ECAD e, administrativamente, determinar a cessação das suas atividades de arrecadação e distribuição"*. Sustentam que as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

aludidas regras violam a *liberdade de associação* (CRFB, art. 5º, XVII a XX), o *princípio da proporcionalidade*, bem como o *direito adquirido* e o *ato jurídico perfeito* (CRFB, art. 5º, XXXVI).

Particularmente, as requerentes alegam que *"as disposições dos arts. 98, §1º, e 98-A da Lei nº 9.610/98, introduzidas pela Lei nº 12.853/2013, e dos arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei ora atacada são aquelas que, de forma mais direta e evidente, contrariam o princípio da liberdade de associação"*. Asseveram que *"o controle estatal ora instituído pela Lei nº 12.853/2013 mostra-se totalmente desproporcional aos fins a que se destina, na medida em que cria restrições absolutas à liberdade de associação, se imiscuindo em questões de organização* interna corporis *das Associações e do ECAD e condicionando o funcionamento de toda a engrenagem da gestão coletiva de direitos autorais à tutela estatal"*. Questiona ainda a incidência dita "*retroativa*" das novas regras sobre Associações já constituídas e sobre o ECAD, *"que se veem obrigados a modificar e adaptar seus atos constitutivos, adequando-se às normas da Lei recém-criada, sob pena de terem suas atividades compulsoriamente suspensas por ato do Estado"*.

Quanto ao art. 98, §2º, da Lei nº 9.610/1998, as requerentes afirmam que, *"a rigor, esse dispositivo é simplesmente inócuo"*, visto que *"as relações contratuais entre titulares de direitos autorais, representados pelas Associações que integram, e usuários de obras musicais deve se pautar pela generalidade dos princípios aplicáveis aos contratos"*. Não obstante isso, aduzem que, *"no contexto da Lei nº 12.853/2013, a eleição dos princípios da isonomia, eficiência e transparência está relacionada ao monitoramento estrito, pela autoridade estatal, da atuação das Associações na defesa dos direitos de natureza privada dos seus representados"*, o que caracterizaria *"estreita correlação com dispositivos inconstitucionais"*, a não justificar sua preservação isolada.

Em relação ao art. 98-B, incisos III, IV, V e VII, apontam que as regras *"estão no contexto do inconstitucional monitoramento, pela autoridade administrativa, da atuação das Associações"*. Afirmam que esses dispositivos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

se destacam *"por serem regras inócuas"*, uma vez que apenas determinam *"a adoção de princípios gerais de administração na gestão coletiva de direitos autorais"*. Na sequência, concluem que a vigência dos referidos incisos *"não se justifica ou se sustenta, isoladamente, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade dos demais preceitos legais introduzidos ou alterados pela Lei n° 12.853/2013"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC aduz que os dispositivos criam *"um regime de natureza cartorária"*, o qual, a seu ver, seria injustificável, porquanto *"as associações não atuam na esfera pública e foram constituídas por titulares de direitos autorais para exercício de direitos individuais estritamente privados"*. Afirma ser *"flagrante a violação aos termos do artigo 5º , XVIII, da CF"*.

> **Art. 98.** (…)
>
> §3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.
>
> §4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.
>
> (…)
>
> §10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo ser distribuídos à medida da sua identificação.
>
> §11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no §10 sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> (…)
> §15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no *caput* e no §3º deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da sua prática.

Os referidos dispositivos estabelecem regras para a negociação dos preços e formas de licenciamento aplicáveis à execução pública de obras musicais. As requerentes da ADI nº 5.062 sustentam que os dispositivos violam o direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e da livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV), ambos elevados à condição de fundamentos da Ordem Econômica (CRFB, art. 170). Ademais, afirmam que as regras vulneram *"os princípios da proporcionalidade e da realidade, ao estabelecer obrigação de cumprimento impossível, por ser incompatível com o sistema de gestão coletiva de direitos autorais"*.

Mais especificamente, a inicial da ADI nº 5.062 assevera que as normas impugnadas *"representam ingerência direta do Estado na forma de cobrança dos direitos patrimoniais referentes à execução pública das obras musicais"*. Porém, em razão das garantias constitucionais da propriedade privada e da livre iniciativa, *"cabe somente aos titulares dos direitos, de forma livre, definir o modo de aproveitamento econômico de suas obras* (…). *Ao Estado não dado limitar esse direito"*.

Apontam as requerentes que licenças do tipo "cobertor" (*blanket licenses*) são as mais adequadas para locais de frequência coletiva, bem como estações de rádio e emissoras de televisão que executam programação alheia. Isso porque, nestes casos, os usuários *"sequer têm conhecimento prévio de quais as obras serão por eles executadas publicamente"*. Afirmam então existir imperativo *fático* em prol da "licença cobertor", que permite ao usuário *"executar publicamente qualquer obra musical* [quantas vezes quiser durante o prazo da licença], *pagando previamente um preço que abrange esse licenciamento global"*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

Em seguida, afirmam ser "inexequível" a fixação de preços diretamente pelas Associações ou os titulares de direitos autorais individualmente. É que o aproveitamento econômico das obras musicais recai sobre diversos cotitulares, os quais, em virtude da respectiva liberdade associativa, são livres para integrar a Associação que desejarem. *"Assim, cada Associação tem como membros titulares de direitos autorais sobre diversas obras, mas não necessariamente tem entre seus quadros todos os titulares de direitos sobre uma determinada obra e muito menos sobre um repertório como um todo"*. Destarte, concluem que *"apenas o ECAD, na qualidade de 'associação de associações', reúne esse repertório e é por essa razão que a fixação de preços, atualmente, se dá nas assembleias do ECAD"*.

Quanto aos §§ 10 e 11, apontam sua contradição com os §§ 3º e 4º. Neste ponto, recorrem a parecer subscrito pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto no qual se sustenta que *"o recebimento de 'créditos e valores não identificados' e a sua distribuição 'dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados', são providências que só se coadunam com a sistemática da* blanket license *(…)"*, supostamente vedada pelos §§3º e 4º. Por fim, em relação ao §15, alegam existir *"mais uma violação ao princípio da liberdade de associação, eis que a fixação de prazos para comunicações entre Associações e associados é matéria que deve ser deliberada pelos próprios associados no âmbito das Associações por eles integradas"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC afirma que o conjunto de dispositivos impugnados, ao *"estabelecer a cobrança pela proporcionalidade ou o 'grau de utilização das obras e fonogramas', extermina com o sistema e transfere ao usuário e à administração pública estabelecer o preço do direito autoral, pois confere ao regulamento da administração pública a definição dos critérios de cobrança"*. Aduz que tais regras legais ofendem *"o direito exclusivo do autor, em especial o estabelecido pelo artigo 5º, XXVII, da Constituição Federal, que consagra ter o criador direito exclusivo para dispor e fruir sob sua obra"*. Defende a legitimidade do ECAD para representar as Associações e os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

titulares de direitos autorais, *"bem como sua habilitação legal para licenciar e fixar preço para execução pública de obras musicais e de fonogramas"*.

> **Art. 98**. (...)
>
> §6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras.
>
> §7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações.
>
> §8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento.

As requerentes da ADI nº 5.062 sustentam que o art. 98, §§6º, 7º e 8º da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.853/2013, *"torna de 'interesse público' e acessíveis a 'qualquer interessado' todas as informações referentes à participação de cada titular de direitos 'em cada obra e em cada fonograma', assegurando ao Ministério da Cultura 'acesso contínuo e integral a tais informações'; além de atribuir ao Ministério da Cultura o papel de árbitro em conflitos privados"*. Pedem a inconstitucionalidade das referidas regras por ofensa ao direito à privacidade (CRFB, art. 5º, X) e ao princípio da proporcionalidade.

Particularmente, as requerentes alegam que *"a proteção constitucional à intimidade* (…) *garante ao titular de direitos autorais a possibilidade de se opor*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

à divulgação pública de informações referentes à sua participação em determinada obra". Relembram que *"é prática absolutamente corrente em diversos tipos de manifestação artística o uso do pseudônimo"*, seja para a proteção do autor, seja para viabilizar a execução de suas obras. Nesse contexto, o dispositivo legal *"estatui um controle público e estatal sobre tais participações e viola o direito à intimidade dos autores"*.

Ressaltam ainda que *"os titulares de direitos autorais têm acesso, no âmbito das Associações de que participam e do próprio ECAD, às informações relevantes para o fim de acompanhamento e controle de seus respectivos direitos patrimoniais"*. Daí que *"a disposição legal ora comentada não guarda qualquer relação com esse direito do autor"*, limitando-se *"a criar um controle público e estatal sobre as obras musicais, a documentação e os contratos a elas relativos"*; controle este que, segundo a inicial, *"confere a órgão estatal poderes de avaliar essas informações e mandar retificá-las, se considerá-las inconsistentes"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC alega que *"a disponibilização de dados é prerrogativa exclusiva do titular de direitos autorais. Uma obra musical ou uma gravação sonora reúne um elenco de titulares e informações acerca do controle econômico da obra, os percentuais de remuneração, cujos dados são particulares e não podem ser disponibilizados para suprir curiosidade alheia"*. Aduz que tais informações estão abrigadas pelo "*direito da privacidade e do sigilo de dados, conforme definido na CF em seus incisos X e XII, do artigo 5º"*. E conclui: *"ainda que possam parecer passíveis de acesso, este só poderá ocorrer mediante autorização expressa do seu proprietário, sendo vedado às associações darem cumprimento ao determinado pela Lei, sob pena de violarem os direitos pessoais de seus associados"*.

> **Art. 98**. (…)
>
> §12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.
>
> (…)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> §16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% (vinte por cento) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva.
>
> **Art. 99.** (…)
>
> §4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores arrecadados.
>
> (…)
>
> §8° Sem prejuízo do disposto no §3° do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram.
>
> §9° O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3° e 4° do art. 98.

As requerentes da ADI nº 5.062 apontam as regras legais citadas *"criam tabelamento sobre a taxa de administração praticada pelas Associações e limitam o poder de os associados deliberarem sobre a utilização dos recursos arrecadados pelas Associações que integram"*. Postulam a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos por violação à liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII a XX), bem como ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e à livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV), ambos elevados à condição de fundamentos da Ordem Econômica (CRFB, art. 170).

Particularmente, aduzem as requerentes que, *"sob o aparente pretexto*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

de garantir aos titulares de direitos autorais o recebimento de um percentual mínimo calculado sobre a arrecadação, a Lei - na realidade - restringe o direito desses mesmos titulares de, como associados, dar a seus recursos a destinação que bem entenderem". Alegam a limitação legal caracteriza "expropriação" do direito de livre disposição dos recursos arrecadados pelos titulares de direitos autorais. Afirmam ainda que as taxas de administração cobradas pelo ECAD e pelas Associações não consubstanciam preços, *"mas custos (assim como as taxas condominiais representam a repartição das despesas dos condôminos)"*. Sustentam que *"o tabelamento da taxa de administração, além de incompatível com a natureza privada das Associações, é incompatível com próprio regime jurídico das entidades associativas"*.

Quanto aos §§ 8º e 9º do art. 99 já citado, as requerentes afirmam que *"a unificação do preço e da cobrança dos direitos autorais pelo ente arrecadador decorre do próprio sistema de gestão coletiva"*. Daí que, *"nessas condições, os dispositivos seriam inócuos (…). De todo o modo, o § 9° resta prejudicado, por referir-se ao §4° cuja inconstitucionalidade já se demonstrou acima"*.

Na ADI nº 5.065, a UBC afirma que a Lei nº 9.610/1998, em seu novo art. 98, §16, *"determina um percentual de um teto para destinação de seus recursos para ações de natureza cultural e social, em estranha interferência, na medida em que deliberação dessa ordem também é de competência exclusiva das respectivas assembleias das associações"*. Tal medida caracterizaria *"flagrante a ofensa ao artigo 5º , XVIII* [da CRFB]".

Quanto ao art. 99, §4º, da Lei nº 9.610/1988, articula ser *"surpreendente observar que a Lei ora guerreada apresente, sem critério legítimo ou base legal, o percentual que caberá às associações para administração de seus direitos"*. Sustenta que *"o que a lei fez foi definir o limite de gasto de uma entidade privada, de forma aleatória e retirando dos associados dessa associação a melhor forma para administração de seus direitos"*, ao que emenda: *"repete-se aqui a violação ao artigo 5º , XVIII e XXVII, da CF"*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> **Art. 99.** (…)
>
> §7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos.

Na ADI nº 5.062, as requerentes afirmam que o art. 99, §7º, da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.853/2013, *"expropria propriedade imaterial detidas pelas Associações e pelo ECAD"*. Isso porque *"os procedimentos desenvolvidos para realizar a arrecadação e a distribuição de direitos autorais é propriedade imaterial do ECAD e das Associações, da qual não podem ser compulsoriamente expropriados como vem de determinar a Lei inconstitucional, que torna obrigatória a transferência a terceiros, sem qualquer remuneração ou indenização"*. Pedem a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo por ofensa ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), bem como à garantia da propriedade imaterial e dos segredos do negócio (CRFB, art. 5º, XXIX).

> **Art. 98-C**. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados.
>
> §1º O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado.
>
> §2º Se as contas não forem prestadas na forma do §1º, o pedido do associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na forma do regulamento.

> **Art. 100-B**. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível.

Na ADI nº 5.062, as requerentes alegam que os arts. 98-C e 100-B da Lei n° 9.610/98, introduzidos pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013, *"atribuem ao Ministério da Cultura e a órgão da Administração Pública Federal, não identificado, o poder de arbitrar conflitos de natureza privada, a respeito de direitos disponíveis, entre associados e Associações e entre usuários e titulares de direitos autorais"*. Afirmam que *"tal mediação não se justifica"*, uma vez que, *"caso qualquer Associação deixe de cumprir seu dever, o caminho direto previsto no ordenamento jurídico é o recurso ao Poder Judiciário"*. Ademais, todos os temas indicados na Lei *"dizem respeito a direitos privados e disponíveis, em relação aos quais não há qualquer fundamento constitucional que autorize a interferência do Poder Executivo"*.

Postulam a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos ao fundamento de violação à livre iniciativa (CRFB, arts. 1º e 170), ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e à separação de Poderes (CRFB, art. 60, §4º, III).

Na ADI nº 5.065, a UBC sustenta, quanto ao citado art. 98-C, §2º, que *"as associações não atuam na esfera pública e foram constituídas por titulares de direitos autorais para exercício de direitos individuais estritamente privados"*. Daí que a intervenção estatal configuraria *"violação aos termos do artigo 5º , XVIII, da CF"*. Quanto ao mencionado art. 100-B, defende que *"pretende retirar, de forma discricionária, do Poder Judiciário o seu papel de moderador da lei e de solução conflitos"*. Aduz ainda que *"não há qualquer necessidade para que norma relativa à alteração da Lei de Direitos Autorais expressamente se refira à matéria concorrencial, cujo cabimento ou não se dará conforme a efetiva aplicação da Lei da Concorrência, caso a caso e não pelo fato de simplesmente*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

constar na Lei de Direitos Autorais". Aponta *"violação ao artigo 5º, XXVII, da CF"*.

> **Art. 99-A**. O ente arrecadador de que trata o *caput* do art. 99 deverá admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública Federal na forma do art. 98-A.

Na ADI nº 5.062, as requerentes alegam que o art. 99-A da Lei n° 9.610/98, introduzido pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013, *"autoriza órgão da Administração Pública Federal a tornar obrigatória a admissão de associados no ECAD"*. Segundo a inicial, *"é inerente ao princípio da liberdade de associação que ninguém pode ser compelido a se associar com terceiro"*. A norma questionada, porém, *"viola esse princípio ao tornar compulsória a admissão de associados ao ECAD, por decisão de 'Órgão da Administração Federal' que considere tais associados 'habilitados' à representação dos titulares de direitos autorais"*.

Asseveram ainda que *"a associação compulsória resulta - em última análise - na repartição obrigatória do patrimônio do ente arrecadador, em favor das novas associações admitidas em seu quadro social"*. Em consequência, *"dá-se mais uma forma de expropriação do direito de propriedade das associadas pré-existentes, que têm reduzida sua quota parte no acervo social"*. Defendem que o ECAD não poderá recusar um pretendente a associado por mero capricho, mas afirmam que "c*asos concretos de abusos, capricho ou malícia podem ser objeto de recurso ao Poder Judiciário"*, e não de interferência do Poder Executivo, sobretudo porque o ECAD é associação de direito privado *"que jamais recebeu qualquer aporte financeiro ou subvenção pública"*.

Pedem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal por violação à propriedade privada (CRFB, art. 5º, XXII), à liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII a XX) e ao princípio da proporcionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

Na ADI nº 5.065, a UBC sustenta, quanto ao dispositivo em referência, que *"as associações não atuam na esfera pública e foram constituídas por titulares de direitos autorais para exercício de direitos individuais estritamente privados"*. Daí que *"as associações de direitos autorais devem respeitar os ditames do Diploma Civil, em especial os seus artigos 53 a 61. Nada além"*, sendo a presente intervenção estatal *"violação aos termos do artigo 5º , XVIII, da CF"*.

Em 06/11/2013 e em 14/11/2013, determinei a aplicação do art. 12 da Lei nº 9.868/99 às ADIs nº 5.062 e 5.065 respectivamente, visando ao julgamento definitivo do mérito das demandas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Em ambas as ações diretas sob julgamento, o Senado Federal prestou informações atestando que a Lei nº 12.385/2013, fruto do PLS nº 129/2012, fora processada dentro dos estritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie, afirmando sua compatibilidade formal e material com a Constituição da República. A Câmara dos Deputados não prestou informações.

A Presidência da República, por intermédio da Consultoria-Geral da União, rebateu as arguições de inconstitucionalidade ventiladas nas ações diretas sob julgamento e pugnou pelo indeferimento dos pedidos. Segundo as informações prestadas pelo Poder Executivo, *"a relevância pública da atividade de gestão coletiva de direitos autorais (…) já é suficiente para espancar de vez qualquer tentativa de situar a atividade de arrecadação na esfera puramente privada, de interesses meramente pessoais disponíveis"*. Juntou-se ainda manifestação do Ministério da Cultura em defesa do ato normativo questionado.

A Advocacia-Geral da União, em cumprimento ao art. 103, §3º, da Constituição, apresentou manifestação em defesa da constitucionalidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

da Lei nº 12.853/2013. Eis a ementa dos pareceres em cada ação direta:

> **ADI nº 5.062**
>
> Constitucional. Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, que trata da gestão coletiva dos direitos autorais. Preliminar. Ausência de impugnação a todos os dispositivos da norma atacada. Conhecimento parcial. Mérito. Ausência de violação à livre iniciativa, à isonomia, ao direito de propriedade, à liberdade de associação, à intimidade, à proteção aos segredos de negócio e à propriedade imaterial, bem como aos princípios da separação de Poderes, da proporcionalidade, da subsidiariedade e da consensualidade (artigos 1º, 5º, *caput* e incisos X, XVII, XVIII. XIX, XXII, XXIX, e XXVIII; 60, §4º, inciso III; e 170, todos da Carta Republicana). Alterações normativas destinadas a conferir transparência e segurança jurídica aos autores, aos usuários e à própria sociedade. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.
>
> **ADI nº 5.065**
>
> Constitucional. Lei nº 12.853. de 14 de agosto de 2013, que trata da gestão coletiva dos direitos autorais. Preliminar. Ilegitimidade ativa *ad causam* da requerente. Mérito. Ausência de vício formal. Juízo de conveniência do Congresso Nacional em adotar regime de urgência na tramitação da proposta legislativa que originou a lei atacada. Mérito. Ausência de violação ao princípio da isonomia, à liberdade de associação, ao direito à intimidade, ao direito personalíssimo do autor de dispor de suas obras e à excepcionalidade de exploração de atividade econômica pelo Estado (artigos 5º, *caput* e incisos XVII, XVIII, X, XII e XXVII; e 173, todos da Carta Republicana). Alterações normativas destinadas a conferir transparência e segurança jurídica aos autores, aos usuários e à própria sociedade. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

A Procuradoria-Geral da República, na qualidade de fiscal da lei, pronunciou-se pelo conhecimento integral da ADI nº 5.062 e pelo não conhecimento da ADI nº 5.065. No mérito, opinou pela improcedência dos pedidos deduzidos em ambas as ações em julgamento. Confira-se a ementa da manifestação subscrita pelo *Parquet* federal em cada uma das ADIs:

> **ADI nº 5.062**
>
> Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 12.853, de 14 de agosto de 2013. Gestão coletiva de direitos autorais. Preliminar. Conhecimento integral da ação. Mérito. Função social dos direitos autorais. Regulamentação das atividades de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Distorções graves e crônicas no funcionamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), apontadas em comissões parlamentares de inquérito. Transparência, prestação de contas, eficiência, idoneidade, isonomia e segurança. Caráter não estritamente privado do regime jurídico aplicável. Legitimidade das normas que preveem maior atuação do poder público no funcionamento do sistema. Ausência de violação aos parâmetros constitucionais invocados. Parecer pelo indeferimento da medida cautelar e, em definitivo, pela improcedência do pedido.
>
> **ADI nº 5.065**
>
> Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 12.853, de 14 de agosto de 2013 (altera a Lei do Direito Autoral). Gestão coletiva de direitos autorais. Preliminares. Identidade de objeto com a ADI 5.062/DF. Apensamento dos feitos para julgamento conjunto. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. Inexistência de vícios formais de inconstitucionalidade. Aspecto material. Função social dos direitos autorais. Regulamentação das atividades de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Distorções graves e crônicas no funcionamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), apontadas em comissões parlamentares de inquérito. Transparência, prestação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

> de contas, eficiência, idoneidade, isonomia e segurança. Caráter não estritamente privado do regime jurídico aplicável. Legitimidade das normas que preveem maior atuação do poder público no funcionamento do sistema. Ausência de violação aos parâmetros constitucionais invocados. Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Em razão da complexidade teórica e prática que perpassa boa parte das arguições de inconstitucionalidade ventiladas nas presentes ações diretas, convoquei Audiência Pública no afã de receber esclarecimentos sobre o tema por parte de titulares de direito autoral, entidades estatais envolvidas com a matéria e representantes da sociedade civil diretamente encarregados da concepção e da aplicação da Lei nº 12.853/2013.

A Audiência foi realizada no dia de 17 de março de 2014, contando com a participação de vinte e quatro expositores, o que permitiu o aporte de valiosos subsídios técnicos para esta Suprema Corte, bem como viabilizou a ampla pluralização do debate jurídico em questão. Após a realização da Audiência, tanto as requerentes (Petição nº 15.603/2014 – ADI nº 5.062) quanto a Procuradoria-Geral da República apresentaram petições consolidando as contribuições dos expositores e reiterando as respectivas posições sobre o mérito da controvérsia constitucional.

Em 05/11/2015, admiti o ingresso no feito, na qualidade de *amici curiae*, da União Brasileira de Editoras de Músicas (UBEM) e da Associação Procure Saber (APS). Na sequência, solicitei data para julgamento das demandas.

É o relatório, cuja cópia deverá ser encaminhada aos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, na forma da lei (art. 9º, *caput*, da Lei nº 9.868/1999).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9818287.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):

I. Preliminar: admissibilidade das ações diretas

Assento, de plano, a admissibilidade de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade ora em julgamento, ajuizadas em face da Lei nº 12.853/2013, ato normativo evidentemente primário, geral e abstrato, que introduziu profundas alterações na disciplina jurídica brasileira da gestão coletiva de direitos autorais e conexos.

Na ADI nº 5.062, são **sete** as requerentes, todas elas devidamente caracterizadas como "entidade de classe de âmbito nacional", nos termos tanto do art. 103, IX, da CRFB, quanto da jurisprudência desta Corte. Ademais, a Lei questionada guarda estreita afinidade com os objetivos institucionais de cada uma das associações. Confira-se:

> 1) A **Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS)** congrega categoria econômica diferenciada (titulares de direitos autorais e conexos, cujas obras estão sujeitas à execução pública) presente em 26 estados da federação mais o Distrito Federal. O art. 2º de seu Estatuto dispõe ser finalidade da ABRAMUS representar os seus associados para a defesa e cobrança de direitos autorais, em especial "*defender os interesses dos associados perante os órgãos e entidades públicas, objetivando maior adequação aos seus objetivos dos dispositivos legais e regulamentares, pertinentes ao exercício da sua atividade, a produção musical* (...)" (art. 2º, alínea *e*).
>
> 2) A **Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes / Sociedade Musical Brasileira (AMAR–SOMBRÁS)** reúne, na forma do artigo 5º de seu Estatuto, "*compositores, autores, versionistas, editores musicais e produtores fonográficos que*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

publiquem obras sob qualquer formato, arranjadores, adaptadores e orquestradores, bem como criadores de obras intelectuais de qualquer natureza, além de intérpretes e executantes, como tais considerados os maestros, regentes, solistas vocais e instrumentais, músicos, coralistas, declamadores, orquestras, coros, conjuntos musicais e assemelhados" (categoria econômica diferenciada vinculada aos titulares de direitos autorais e conexos no setor musical, cujas obras estão sujeitas à execução pública). Apresenta representatividade em 26 estados da federação e no Distrito Federal. Segundo o art. 3º do Estatuto da entidade, sua finalidade é a defesa e a gestão dos direitos de seus associados.

3) A **Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM)** reúne músicos titulares de direitos autorais, estando presente em 25 estados da federação, além do Distrito Federal. Sua pertinência temática encontra-se satisfeita ante o objetivo da entidade em representar e defender os direitos de seus associados de forma moral e material, conforme dispõe o artigo 1º, *caput* e 2º, I, de seu Estatuto.

4) A **Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM)** congrega categoria econômica diferenciada composta por titulares de direitos autorais e conexos oriundos do ramo musical, presente em 25 estados da federação mais o Distrito Federal. O art. 2º, parágrafo único, de seu Estatuto dispõe ser sua finalidade defender moral e materialmente os direitos de seus associados.

5) A **Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM)** reúne, com base no artigo 8º de seu Estatuto, "titulares de direitos de obras musicais", categoria econômica diferenciada vinculada ao ramo da música, especificamente aos titulares de direitos autorais e conexos, cujas obras estão sujeitas à execução pública. A SICAM tem representatividade em 26 estados da federação e no Distrito Federal. Segundo o art. 5º de seu Estatuto, o propósito da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

entidade é defender, no âmbito moral e patrimonial, os direitos autorais e conexos de seus associados efetivos e administrados.

6) A **Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (SOCINPRO)** se amolda ao conceito constitucional de entidade de classe de âmbito nacional, uma vez que reúne titulares de direitos autorais e conexos, mantendo representatividade em 26 estados da federação além do Distrito Federal. A pertinência temática encontra-se satisfeita ante o objetivo da entidade em proteger os direitos de seus associados, conforme dispõe o artigo 4º e 5º de seu Estatuto.

7) O **Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)** congrega associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos relativos à execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, na forma do art. 99 da Lei nº 9.610/1998. O ECAD tem representação em 19 estados da federação mais o Distrito Federal. A Lei nº 12.853/2013 revela afinidade com os objetivos institucionais da requerente, sobretudo à luz do art. 1º de seu Estatuto, que dispõe ser sua finalidade defender os direitos de seus associados. Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI-AgR nº 3.153, rel. Min Sepúlveda Pertence, DJ de 09/09/2005, assentou, superando entendimento anterior, a legitimidade ativa *ad causam* de "associação de associações".

Na ADI nº 5.065, a **União Brasileira de Compositores (UBC)** também se caracteriza como entidade de classe de âmbito nacional nos termos do art. 103, IX, da CRFB. A associação congrega categoria econômica diferenciada (titulares de direitos autorais, propriedade artística e literária), com representatividade nacional, uma vez que presente em 26 estados da federação e no Distrito Federal. De outra banda, a Lei nº 12.853/2013 apresenta evidente pertinência com os objetivos institucionais da requerente, notadamente à luz do art. 2º, *a*, de seu Estatuto, que dispõe ser sua finalidade a defesa moral e material dos direitos de seus associados.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

Neste ponto, rejeito a questão preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República quanto à pretensa ilegitimidade ativa *ad causam* da UBC para deflagrar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal. Segundo sustentam a AGU e a PGR, a UBC não configura "entidade de classe" porquanto *heterogênea*, no sentido de possuir, entre seus associados, categorias profissionais distintas, reunindo, por exemplo, pessoas naturais titulares de direitos autorais e pessoas jurídicas que atuam na editoração musical. Não acolho estes fundamentos.

Como se sabe, a noção de "entidade de classe" para fins do art. 103, IX, da CRFB não está definida por critérios legais objetivos, sendo fruto de um esforço do Tribunal em racionalizar o acesso à jurisdição constitucional. Nesse sentido, a Corte passou a exigir, desde a ADI nº 42, julgada em setembro de 1992, a "homogeneidade" de tais entidades, assim concebidas aquelas que representam grupo de pessoas que exercem as mesmas atividades profissionais ou econômicas. Naquele julgado, o ministro Sepúlveda Pertence, procurando delimitar as balizas do critério, reputou caracterizada a homogeneidade sempre que existente *"identidade ou semelhança da atividade empresarial ou profissional ou do setor econômico em que empregados os seus integrantes"*. Já o Ministro Celso de Mello afirmou que o ponto central para a aferição da legitimidade é *"a existência de um vínculo jurídico ou de uma relação-base, que as congregue e lhes imprima caráter unitário na ação social em que se busque a colimação do interesse coletivo"*.

Na hipótese, acredito haver semelhança suficiente para caracterizar a homogeneidade da UBC. A rigor, as próprias noções de *homogeneidade* e *heterogeneidade* associativa carecem de maior precisão jurídica. A depender do ângulo pelo qual se enxergue a controvérsia, poderá haver um ou outro. Vista pelo enfoque *subjetivo*, como fazem a AGU e a PGR, a UBC, ao congregar pessoas naturais e jurídicas, autores de obras musicais e editoras de música, seria heterogênea por reunir categorias profissionais diferentes. Porém, analisada a matéria pelo enfoque *objetivo*, na linha do Min. Celso de Mello, visualizo nítida semelhança entre os integrantes da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

associação, na medida em que titulares de direitos autorais e conexos submetidos à execução pública e, portanto, pertencentes a uma das entidades atuantes na gestão coletiva, setor da vida social alvo de profundas transformações a partir da edição da Lei nº 12.853/2013.

Ante esse dilema de enfoque, um questionamento me soa natural: se as próprias entidades integrantes do sistema brasileiro de gestão coletiva de direitos autorais não ostentam legitimidade *ad causam* para questionar o novo marco regulatório do setor, quem mais poderia ter? Aliás, um dado prático não pode ser ignorado. Até o advento da nova Lei, a gestão coletiva de direitos autorais era exercida por nove associações, além do próprio ECAD. Destas nove, seis figuram como requerentes na ADI nº 5.062 (ao lado do Escritório Central) e uma outra, a UBC, é requerente da ADI nº 5.065. Portanto, **80%** das entidades de gestão coletiva brasileiras questionam o novo marco regulatório do setor, a revelar, para usar as palavras do Min. Celso de Mello, *"a existência de um vínculo jurídico ou de uma relação-base, que as congregue"*.

Reputo salutar a abertura, em alguma medida, da interpretação constitucional às demandas e às expectativas das entidades associativas afetadas diretamente pela nova disciplina legal. Oportuna, aqui, a advertência do professor Gustavo Binenbojm no sentido de que *"o argumento* ad terrorem *da proliferação incontrolável de causas não pode servir como pretexto para frustrar o acesso de grupos organizados, de elevada representatividade social, à participação nos processos constitucionais sobre leis de grande relevância para seus destinos"* (*A nova jurisdição constitucional*: legitimidade democrática e instrumentos de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª Edição, 2013, pp. 158-159).

Em decisão monocrática recente, proferida nos autos da ADI nº 5.291, o Ministro Marco Aurélio enfrentou o tema com a coragem e a sabedoria que lhe são características, aduzindo que posturas restritivas na interpretação do conceito de "entidade de classe" implicam *"reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil* [e] *amesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta de 1988"*. Tais razões são suficientes para reconhecer a legitimidade ativa da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

União Brasileira dos Compositores, assentando a homogeneidade da classe formada por seus membros, **titulares de direitos autorais e conexos, cujas obras estão submetidas à execução pública e sujeitas à gestão coletiva**.

Uma última observação sobre este tema se faz necessária. Ela revela a importância do presente julgamento **conjunto**. É que as mesmas razões apresentadas pela AGU e pela PGR, na ADI nº 5.065, quanto à suposta falta de legitimidade da UBC **não** foram arguidas por estes órgãos na ADI nº 5.062, muito embora algumas das requerentes nesta última ação direta apresentem composição de associados muito similar à da UBC. É o caso, por exemplo, da ABRAMUS. Tal omissão, porém, não configura lapso da AGU ou da PGR. Em verdade, não se questionou, na ADI nº 5.062, a legitimidade das associações que lá figuram como requerentes justamente porque elas estão regularmente legitimadas. Aplicam-se à UBC os exatos fundamentos apresentados na inicial da ADI nº 5.062 em defesa da legitimidade das respectivas requerentes:

> "Todos os integrantes das Associações, independentemente da categoria 'profissional' a que pertencem - como compositores, intérpretes, músicos - integram uma mesma e homogênea categoria, que se distingue pela titularidade de direitos autorais e conexos sobre a execução pública de obras musicais, e pelo exercício conjunto de tais direitos, através das Associações e do ECAD, no sistema de gestão coletiva objeto da Lei n° 9.610/98. Há entre todos os membros das Associações o 'vínculo jurídico' e a 'relação-base' que os une e que confere 'caráter unitário na ação social' em que se procura alcançar o interesse coletivo-próprio dessa categoria de pessoas delimitada e homogênea - que consiste na preservação do sistema de gestão coletiva dos direitos autorais".

Rejeito ainda a questão prévia suscitada pela AGU quanto ao conhecimento parcial da ADI nº 5.062 em razão de suposta ausência de impugnação específica de alguns dos dispositivos questionados. Como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

apontado pela PGR, *"a petição inicial fundamenta especificamente a impugnação a cada dispositivo apontado da lei"*. Nas páginas 38 a 80 da peça inaugural, as requerentes promovem o cotejo analítico entre as previsões legais questionadas e os preceitos constitucionais tidos como violados. O cuidado e a organização da exordial são dignos de nota.

Prosseguindo no exame preliminar, consigno o preenchimento de todos os demais requisitos de admissibilidade das presentes postulações, notadamente a presença de cópia do ato normativo impugnado e a existência de procurações com poderes especiais para o ajuizamento das ações diretas.

Conheço, portanto, das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 5.062 e 5.065. Passo ao exame de mérito.

II. Mérito

II.(a) – Inconstitucionalidade formal

A arguição de inconstitucionalidade formal da Lei nº 12.853/2013 está veiculada apenas na ADI nº 5.065. Os fundamentos articulados na ADI nº 5.062 são de índole estritamente material.

A União Brasileira de Compositores sustenta, de início, que a Lei nº 12.853/2013, resultante de substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 129/2012 apresentado pelo Senador Humberto Costa, padeceria de vício formal, porquanto teria tramitado *"em tempo recorde"*, ao longo de 14 dias, sem justificativa para o rito de urgência. Aduz que *"a significativa mudança provocada no texto original do PLS 129,* (…), *retiraria da questão qualquer possibilidade de aplicação do regime de tramitação sumário, violando o artigo 59 da Constituição"*. E conclui:

> "Flagrante, pois, o vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que foi obstado, sem justificativa, o curso pacífico da proposta legislativa aprovada, bem como introduzidos vários elementos novos se comparados ao texto originalmente revelado pelo PLS 129, alvo do substitutivo do Senador Humberto Costa".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

Os argumentos, porém, não convencem. Já tive a oportunidade de consignar nos autos da ADI nº 4.357 e da ADI nº 4.425, que a interferência judicial no âmago do processo político, para justificar-se, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto expresso das normas da Constituição da República. É que, do contrário, correr-se-ia o grave risco de sufocar e de engessar a dinâmica própria aos agentes políticos eleitos, aprisionando-a por força externa em fórmulas rígidas que não se ajustam bem à cambiante necessidade de acomodar uma ampla gama de anseios sociais divergentes no Parlamento.

Sob este pano de fundo, cabe indagar qual o amparo normativo em que se funda o argumento de vício formal da Lei nº 12.853/2013, para que assim se examine se ele é fruto, verdadeiramente, de um conflito claro e inequívoco entre a forma exigida pela Constituição e aquilo que levado a cabo pelo Congresso Nacional, ou se, ao contrário, decorre ele de uma construção um tanto quanto arrojada das regras constitucionais.

Pois bem. O PLS nº 129/2012 resultou dos trabalhos investigativos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Senado Federal em 2011 para apurar denúncias de irregularidades na sistemática brasileira de gestão coletiva de direitos autorais. Ao longo de dez meses (de 28/06/2011 a 26/04/2012), a CPI realizou um total de dezessete reuniões, sendo onze destinadas a oitivas, audiências públicas e diligências para ouvir artistas, produtores, especialistas, dirigentes e funcionários do ECAD. Consta do relatório final da CPI, recomendação para *"que o Congresso Nacional aprove, em regime de urgência, o projeto de lei que vai anexo a este relatório, que dispõe sobre o Novo Sistema de Gestão Coletiva de Direitos Autorais"*.

Em maio de 2012, o referido projeto foi protocolado no Senado Federal e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Perante a CCJ, o Senador Humberto Costa apresentou, em 26 de junho de 2013, substitutivo ao PLS original. Após emendas de outros senadores integrantes da Comissão, o substitutivo foi aprovado em 03 de julho de 2013. A Comissão ainda aprovou o Requerimento nº 30, de 2013-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

CCJ, para conferir urgência à tramitação da matéria. No mesmo dia, o projeto foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal.

Encaminhado à Câmara dos Deputados, o projeto foi autuado como PL nº 5.901/2013 e, por votação unânime do Plenário, passou tramitar em regime de urgência (Requerimento nº 8.178/2013). Em 09 de julho de 2013, a proposição foi aprovada, em sequência, pela Comissão de Cultura, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, por fim, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, sendo devolvida ao Senado Federal em 10 de julho de 2013. Enviado à Presidência da República, o Projeto foi sancionado sem vetos em 14 de agosto e entrou em vigor em 13 de dezembro de 2013.

À luz desse trâmite, não me parece que tenha havido qualquer ofensa ao devido processo legislativo. Em *primeiro* lugar, registro que a UBC não aponta nenhum dispositivo constitucional específico que tenha sido violado, invocando genericamente o art. 59 da CRFB, que apenas elenca as espécies legislativas existentes em nosso ordenamento jurídico. Em *segundo* lugar, a Constituição de 1988 não estabeleceu prazos mínimos para tramitação de projetos de lei, nem disciplinou o regime urgente de tramitação, circunstância que, a meu sentir, confere espaço suficiente para o legislador imprimir aos seus trabalhos a cadência que julgar adequada. Nesse sentido, também opinou a PGR:

> "A Constituição Federal não dispôs sobre o rito abreviado de tramitação aplicável às proposições legislativas de autoria de membros do Congresso Nacional, mas apenas tratou da hipótese do requerimento de urgência quando solicitado pelo Presidente da República, aos projetos de sua autoria. Além disso, a única vedação a tal regime encontra-se no §4º, parte final, do art. 64 da Constituição, que o proíbe aos projetos de código, hipótese em que não se enquadra o diploma sob exame.
>
> A mera relevância da matéria da Lei 12.853/2013 não caracteriza impedimento constitucional à adoção de regime de urgência para trâmite do respectivo projeto de lei. Tampouco induz inconstitucionalidade formal do diploma o fato de sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> redação final aprovada pelo Congresso Nacional ter-se dado na forma de substitutivo, o qual teria introduzido elementos novos na proposição legislativa original".

Rejeito o vício de forma imputado à Lei nº 12.853/2013.

II.(b) – Inconstitucionalidade material

Premissas Teóricas

II.(b).1. Direitos autorais e gestão coletiva: a racionalidade econômica

O direito autoral é um conjunto de prerrogativas que são conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que cria alguma obra intelectual (cf., por todos, ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito do autor e direitos conexos*. Coimbra: Coimbra Editora, 1992). Dentre tais prerrogativas, destaca-se, para os fins do presente julgamento, o direito *exclusivo* do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas obras, garantido expressamente pelo art. 5º, XXVII, da Constituição da República, *verbis*:

> **CRFB, Art. 5º** (...)
> XXVII - aos autores pertence o direito **exclusivo** de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
> (sem grifos no original)

Essa exclusividade se justifica como *mecanismo de incentivo* à criação intelectual: caso não fosse possível ao autor auferir, em caráter restrito e por período de tempo adequado, benefício superior ao custo de reprodução da obra, dificilmente alguém investiria recursos monetários e não monetários na produção intelectual (LANDES, William M., POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 21: "*Unless there is power to exclude, the incentive to create intellectual property in the first place may be impaired*"). À exclusividade do direito do autor corresponde, como face simétrica, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

necessidade de todo interessado obter autorização prévia do titular para poder utilizar a obra.

Aqui se iniciam as delicadezas da proteção da propriedade intelectual, em particular dos direitos autorais. Em primeiro lugar, a titularidade sobre determinada obra é, em geral, compartilhada por diversos indivíduos que participaram da sua criação, tais como artistas intérpretes ou executantes e produtores de fonogramas. Em segundo lugar, a ausência de suporte físico que delimite o domínio intelectual cria dificuldades de monitoramento da utilização da obra, sobretudo na execução pública. Ambas as características tornam o mercado de obras intelectuais refém de elevados *custos de transação.*

O termo "custos de transação" ganhou destaque nas ciências econômicas com o trabalho seminal de Ronald Coase, que posteriormente lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1991 ("The problem of social cost". *Journal of Law and Economics*, vol. 3, 1960, pp. 1-44). Quer-se, com essa ideia, designar os recursos sacrificados (i) na procura e na identificação da contraparte negocial, (ii) na barganha e na decisão quanto aos termos contratuais; (iii) na supervisão das condutas e na responsabilização das violações ao ajuste firmado. Custos de transação elevados comprometem o sistema de incentivos voltado a induzir a produção intelectual ao reduzirem o retorno esperado dos criadores. Daí a importância de mecanismos que, mitigando as aludidas dificuldades práticas, tornem atrativa a dedicação humana à criação intelectual. É o que faz a *gestão coletiva*.

Em linhas gerais, compreende-se por gestão coletiva de direitos autorais o exercício e a defesa das prerrogativas legais inerentes à criação intelectual através de associações formadas por titulares desses direitos. Esse modelo de gestão reduz as dificuldades operacionais geradas tanto pela cotitularidade das obras quanto pelos custos de monitoramento da sua execução. Ao reunir autores, torna-se mais simples a identificação e a negociação do licenciamento dos direitos. Ao mesmo tempo, viabiliza-se que uma mesma estrutura de fiscalização e cobrança seja utilizada por diferentes titulares, diluindo os custos de manutenção pela presença de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

economias de escala (HANDKE, Christian. "Collective administration". *Handbook of the Economics of Copyright*. Cheltenham: Edwar Elgar Publishing Inc., 2014, pp. 179-206). Por esse ângulo, a gestão coletiva tende a aperfeiçoar o mercado na direção socialmente eficiente.

Não obstante suas vantagens, a gestão coletiva também gera preocupações. É que a congregação de titulares acaba por lhes conferir relevante *poder de mercado*, assim compreendida a possibilidade de afetar o preço de equilíbrio por comportamento próprio, o que, *in casu*, se dá sobretudo pela fixação conjunta dos valores de repertórios (BESEN, Stanley M., KIRBY, Sheila N. e SALOP, Steven C. "An Economic Analysis of Copyright Collectives". *Virginia Law Review*, vol. 78, 1992, pp. 383-411). Na literatura econômica, a existência de poder de mercado resulta, via de regra, em alocações não eficientes do ponto de vista social. No caso do monopólio, isso se dá pelo fato de a oferta *efetiva* do bem transacionado ficar aquém da oferta (socialmente) *ótima* (cf. NICHOLSON, Walter; SNYDER, Christopher. *Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions*. Ohio: Thomson SouthWestern, 10th Edition, 2007, pp. 497-500). Tal circunstância implica desperdício de recursos escassos, caracterizados pela existência de oportunidades não exploradas de transações mutuamente benéficas. É o que se costuma chamar de "perda de peso morto" (*deadweight loss*). Por esse ângulo, a gestão coletiva tende a distorcer o mercado na direção oposta à socialmente eficiente.

Vê-se, portanto, que a gestão coletiva de direitos autorais envolve um *trade-off* socialmente relevante. Por um lado, ela viabiliza a própria existência do mercado ao reduzir os custos de transação decorrentes da cotitularidade e da imaterialidade da propriedade intelectual. Por outro, ela confere poder de mercado aos titulares de direito, em especial às entidades de gestão coletiva, ao induzir a precificação conjunta das obras intelectuais. Em um regime democrático, encontrar o ponto adequado de equilíbrio nesse dilema é um desafio que se apresenta de tempos em tempos a diferentes gerações.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

II.(b).2. Direitos autorais e gestão coletiva: a disciplina jurídica brasileira

No período republicano, todas as Constituições brasileiras, excetuando-se a Carta de 1937, consagraram expressamente o direito do autor à exclusividade da reprodução de suas obras. Foi assim com as Constituições de 1891 (art. 72, §26), 1934 (art. 113, §20), 1946 (art. 141, §19) e 1988 (art. 5º, XXVII). O traço particular da Carta de 1988 foi alçar, ao plano constitucional, a previsão da gestão coletiva dos direitos autorais. É o que dispõe o art. 5º, XXVIII, da CRFB, *verbis*:

> **CRFB, art. 5º** (...)
> XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
> a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
> b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

No plano infraconstitucional, porém, a gestão coletiva é objeto de disciplina jurídica desde 1973, quando promulgada a Lei nº 5.988. Neste arcabouço legal, três entidades merecem destaque: (i) o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), (ii) as associações de titulares direitos autorais e (iii) o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de direitos autorais (ECAD).

O Conselho Nacional de Direito Autoral foi previsto como *"órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos"* (art. 116). A ele cabia, dentre outras competências, *"determinar, orientar, coordenar e fiscalizar as providências necessárias à exata aplicação das leis, tratados e convenções internacionais*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

ratificados pelo Brasil sobre direitos do autor e direitos que lhes são conexos" (art. 117, I). Registre-se ainda a autoridade de fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de direitos autorais (art. 117, IV), além de funcionar como árbitro em questões que versassem sobre direitos autorais entre autores, intérpretes, ou executantes, e suas associações, tanto entre si, quanto entre uns e outras (art. 117, V).

Quanto ao regime das associações de titulares direitos autorais, a Lei nº 5.988/2013 previa que, para o exercício de seus direitos, poderiam os titulares de direitos autorais associarem-se, sem intuito de lucro (art. 103), vedando-se o pertencimento a mais de uma associação (art. 103, §1º). Com a filiação, a associação tornava-se, *ex lege*, mandatária dos associados para a defesa de seus direitos (art. 104), sem prejuízo de sua tutela pessoal por cada titular (art. 104, § único).

O funcionamento das associações dependia de autorização prévia do CNDA (art. 105). Para além das matérias obrigatórias que deveriam constar do estatuto (art. 106), a Lei nº 5.988 disciplinava ainda os órgãos da associação (art. 107), traçando regras fundamentais para sua atuação (arts. 108 a 112), como a composição de cada órgão, a periodicidade de reuniões, os critérios de votação e a remuneração de seus integrantes. Menciono ainda as obrigações das associações em relação ao CNDA (art. 114), no que tem destaque o dever de prestar informações sobre qualquer alteração no estatuto ou na relação de associados (art. 114, I) bem como a apresentação de relatórios, até trinta de março de cada ano, das atividades desenvolvidas (art. 114, III, a), cópia autêntica do balanço (art. 114, III, b) e relação das quantias distribuídas a seus associados ou representantes (art. 114, III, c). As associações também eram obrigadas a prestar as informações que o CNDA solicitasse, bem como exibir-lhe seus livros e documentos (art. 114, IV).

Quanto ao ECAD, a Lei nº 5.988/1973 previa um único dispositivo (art. 115), estabelecendo que as associações deveriam organizar, em prazo fixado pelo CNDA, um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos direitos relativos à *execução pública*, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, das composições musicais ou litero-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

musicais e de fonogramas. O ECAD não teria finalidade de lucro e reger-se-ia por estatuto aprovado pelo CNDA (art. 115, §1º), ao qual deveria enviar, bimensalmente, relatório de atividades e balancete (art. 115, §2º). Apesar de previsto em lei desde 1973, o ECAD só foi implantado em 1976 pela Resolução nº 1 do CNDA.

Em 1990, o CNDA foi extinto junto com o Ministério da Cultura (Medida Provisória nº 150/1990, art. 25, II, *l*). O ECAD passou então a ser administrado pelas suas associações, reunidas em assembleia geral, sem qualquer supervisão estatal. Essa circunstância foi mantida pela Lei nº 9.610/1998, que revogou expressamente a Lei nº 5.988/1973 (art. 115) para *"alterar, atualizar e consolidar a legislação sobre direitos autorais"* no Brasil.

Pela Lei n° 9.610/1998, a *gestão coletiva* de direitos autorais deixa de estar submetida a um órgão regulador estatal, como o era o CNDA, organizando-se em: (i) associações de classe representativas de titulares de direitos de autor e conexos, criada para o exercício e defesa desses direitos (art. 97) e (ii) ECAD, que congrega as associações anteriores, sendo responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a *execução pública* de obras intelectuais (art. 99). As disposições da Lei nº 9.610/1998 sobre o ECAD e sobre as associações de titulares de direitos autorais são, em essência, as mesmas da antiga Lei nº 5.988/1973.

Esse desenho legislativo foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.054 em razão do monopólio conferido pela lei ordinária ao ECAD, que violaria a garantia constitucional da liberdade de associação. No início de 2003, no entanto, a Corte rejeitou o pleito e placitou a validade constitucional do regime de monopólio legal da arrecadação e da distribuição de direitos autorais. Eis a ementa do julgado:

> I. Liberdade de associação. 1. Liberdade negativa de associação: sua existência, nos textos constitucionais anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance e inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei. 2. Direitos autorais e conexos: sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD (L 9610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5º, XVII e XX, da Constituição, cuja aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de conciliar-se com o disposto no art. 5º, XXVIII, b, da própria Lei Fundamental. 3. Liberdade de associação: garantia constitucional de duvidosa extensão às pessoas jurídicas. II. Ação direta de inconstitucionalidade: não a inviabiliza que à lei anterior, pré-constitucional, se pudesse atribuir a mesma incompatibilidade com a Constituição, se a lei nova, parcialmente questionada, expressamente a revogou por dispositivo não impugnado. III. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação de partido político não afetada pela perda superveniente de sua representação parlamentar, quando já iniciado o julgamento.
>
> (**ADI nº 2.054**, rel. Min. Ilmar Galvão, rel. p/ acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 02/04/2003, DJ 17-10-2003 – sem grifos no original)

II.(b).3. Poder de mercado e ausência de regulação: as distorções na gestão coletiva diagnosticadas por CPIs e pelo CADE

A partir da década de 1990, o Brasil passou a contar com um modelo peculiar de gestão coletiva de direitos autorais. A peculiaridade residia na convivência entre o regime de monopólio legal do ECAD e a ausência de regulação setorial, em especial a inexistência de um órgão fiscalizador nos moldes do extinto CNDA. Ocorre que, no âmbito do antitruste, esse arranjo é considerado, em si, perigoso. Como já apontado, os monopólios, pelo poder de mercado que conferem aos seus detentores, comprometem a eficiência alocativa que tende a ser obtida em ambientes de livre competição. Daí serem caracterizados na literatura especializada como um exemplo de *falha de mercado* a justificar intervenção estatal (VISCUSI, W. Kip; HARRINGTON JR, Joseph E.; VERNON, John M. *Economics of*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

regulation and antitrust. Cambridge: The MIT Press, 2005, pp. 82-92).

Nesse novo cenário, os problemas não demoraram a surgir. É o que aponta o relatório da já mencionada CPI instalada pelo Senado Federal em 2011, para, segundo o Requerimento nº 547, investigar *"irregularidades praticadas pelo ECAD na arrecadação e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo de gestão coletiva centralizada de direitos autorais de execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei 9.610/98"*:

> "É de registrar que, ao longo de sua história, o ECAD foi alvo de outras quatro CPIs: uma da Câmara dos Deputados (1995/96), e três das Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul (2005), São Paulo (2009) e Rio de Janeiro (2011). Todas apontaram graves irregularidades. O Relatório Final da CPI da Câmara dos Deputados aponta a ocorrência dos crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, formação de cartel e abuso do poder econômico.
>
> A conclusão da CPI do Mato Grosso do Sul é que o ECAD *'faz o que bem entende, cobra o que quer, distribui o que tem vontade, impõe condições ao seu bel prazer, estabelece critérios incompreensíveis e age com uma volúpia arrecadadora, motivando os reclamos da população e dos detentores de direitos autorais'*. O mesmo relatório concluiu também que *'torna-se imprescindível que a Lei nº 9.610/98 seja urgentemente revista pelo congresso nacional'*. A CPI realizada em São Paulo pela ALESP também aponta para a necessidade de *'formular as alterações que se fazem imperativas, de forma a criar um ambiente de segurança e clareza tais, que permitam aos músicos exercitarem o seu mister, sem que sejam obrigados a desperdiçar seus talentos na busca da Justiça, ou calar-se, perante as ameaças e o poderio econômico dos que se encastelaram em estruturas ineficazes e corruptas'*.
>
> A presente Comissão, instalada no Senado da República, consolida e aprofunda várias denúncias anteriores e traz novas luzes sobre os graves problemas que se abateu sobre a gestão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

coletiva dos direitos autorais no Brasil".

No âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a conduta do ECAD e das associações a ele vinculadas foram analisadas em processo administrativo em que ficou caracterizado, aos olhos da autoridade antitruste brasileira, abuso de poder dominante. Eis a ementa do acórdão:

> Processo Administrativo. Suposta prática de cartel, instigação ao cartel, limitar ou impedir o acesso ao mercado, criação de dificuldade no funcionamento ou constituição de concorrente, imposição de preços excessivos, elevadas barreiras à entrada. As práticas investigadas estão enquadradas no art. 20, incisos I a IV, e art. 21, incisos I, II, IV, V e XXIV. Elaboração de tabela de preços (cartel) e criação de barreiras à entrada. Formação de cartel entre o ECAD e as Associações efetivas que compõem e fixariam em conjunto o valor dos direitos relativos à execução pública das obras musicais, lítero-musicais e dos fonogramas; abuso de posição dominante por parte do Escritório Central por meio da criação de dificuldades à constituição e ao funcionamento de associações representativas de titulares de direitos autorais. Gestão coletiva de direitos autorais. Mercado relevante na dimensão do produto: direitos autorais e direitos conexos. Mercado relevante na dimensão geográfica nacional. A SDE, a ProCADE e a Comissão Parlamentar de Inquérito recomendaram a condenação dos Representados; o MPF manifestou-se pelo arquivamento do feito. Aplicação de multa (art. 23, III da Lei nº 8.884/94) e penalidades não pecuniárias. Condenação.
>
> (**PA n° 08012.00374512010-83**, rel. Conselheiro Elvino Mendonça, j. 06/03/2013).

O julgamento do CADE é relevante ao evidenciar, no plano empírico, aquilo que, no plano teórico, já era esperado: apesar de não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

haver monopólio legal em favor das associações de titulares de direitos autorais, o qual se restringe ao ECAD, a sistemática da gestão coletiva, ao induzir a precificação conjunta das obras, faz florescer significativo poder de mercado, uma vez que as decisões de preço tendem a ser tomadas em acordo entre as associações. Foi o que apontou o voto do Conselheiro Marcos Veríssimo:

> "(...) a impossibilidade de competição entre as Associações é uma inviabilidade de fato, que decorre da estrutura mesma do sistema brasileiro de proteção de direitos autorais e conexos (...).
>
> (...) a impossibilidade de concorrência, (...), não deriva no caso presente de eventual proibição em lei (que de fato não existe), mas sim da possibilidade, admitida pela lei, de as Associações reunirem diversos interessados em um mesmo repertório em entidades distintas, sendo, no regime brasileiro, a proteção do direito autoral não incide apenas sobre o autor intelectual da composição, mas também sobre o intérprete de cada uma de suas versões, sobre os executantes de cada uma de suas versões e sobre os produtores fonográficos de cada uma de suas versões.
>
> Dessa forma, no sistema brasileiro, é impossível, do ponto de vista prático, segregar repertórios em entidades distintas".

O poder de mercado do ECAD (pelo monopólio legal) e das entidades associativas a ele vinculadas (pela lógica da gestão coletiva) parece ser a fonte de boa parte das irregularidades apuradas. Novamente retomo trecho esclarecedor do voto do Conselheiro Marcos Veríssimo:

> "O problema do modelo brasileiro, a meu ver, não é a falta de competição entre as Associações que compõem o ECAD (competição essa que, como visto, me parece ser impossível no que respeita aos preços cobrados dos usuários de música), mas sim a falta de regulação estatal sobre as atividades em geral conduzidas pelo ECAD, nelas incluída a fixação de preços e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

condições de licenciamento.

(...)

Esse monopólio não regulado, em que a fixação de preços e condições de contratação está exclusivamente deixada ao talante não supervisionado de uma parte privada, é a infeliz peculiaridade do modelo brasileiro, que nos coloca no 'pior dos mundos': ausência simultânea de concorrência (que há, ao menos parcialmente, no modelo americano) e de regulação e supervisão (que há, de modo geral, no modelo europeu)".

II.(b).4. A Lei nº 12.853/2013 e a tentativa de equacionar os problemas.

A Lei nº 12.853/2013, fruto do PLS nº 129/2012, surge como produto final dos trabalhos da CPI criada pelo Senado Federal para apurar denúncias de irregularidades quanto à gestão coletiva de direitos autorais. A Comissão concluiu que os problemas diagnosticados não seriam meros episódios isolados, mas reais sintomas da falta de funcionalidade do modelo regulatório até então vigente. Alterar a disciplina jurídica do tema passou a ser prioridade.

De modo geral, a Lei nº 12.853/2013 aumenta a participação do Estado brasileiro, em especial do Ministério da Cultura, no setor. Suas diretrizes incluem medidas para coibir fraudes, regras de ampla transparência, política indutora de preços competitivos para o licenciamento de direitos autorais, além de procedimento administrativo para resolução de disputas entre entidades arrecadadoras e usuários. Na justificação do referido PLS, as mudanças propostas foram organizadas em cinco frentes, assim apresentadas:

"a) TRANSPARÊNCIA: o projeto de lei cria obrigações claras de transparência para gestão coletiva, por se tratar de atividade que afeta número difuso de pessoas, tanto na sociedade quanto no segmento de artistas, produtores e titulares de direitos.

b) EFICIÊNCIA: o projeto estabelece a eficiência como princípio, tanto técnico quanto econômico. Artistas terão direito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> a serem informados sobre seus direitos e créditos. Além disso, as regras de concorrência previstas na Constituição Federal aplicam-se à gestão coletiva.
>
> c) MODERNIZAÇÃO: o projeto reorganiza a gestão coletiva, racionalizando a estrutura das associações que a compõem. As associações passam a ser divididas por direitos específicos. Estabelece também o princípio da modernização tecnológica em favor do artista e dos titulares de direitos autorais.
>
> d) REGULAÇÃO: o projeto mantém a existência de um único Escritório Central; em contrapartida, este fica subordinado ao Ministério da Justiça, que funcionará como instância reguladora e supervisora.
>
> e) FISCALIZAÇÃO: o projeto atribui ao Ministério da Justiça a prerrogativa de fiscalizar a gestão coletiva, selecionando e homologando as entidades por ela responsáveis e prevenindo abusos, inclusive quanto ao arbitramento de preços".

A racionalidade dessas diretrizes foi apresentada pelo professor e pesquisador Ronaldo Lemos, o qual, à época à frente do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV Direito Rio, colaborou para a elaboração do anteprojeto que serviu de ponto de partida para os trabalhos legislativos:

> "A razão para que as associações de gestão coletiva se subordinem a esses princípios consiste no fato de que as mesmas são depositárias de vultosos recursos arrecadados com força de lei perante diversos estratos da sociedade brasileira. Esses recursos são recebidos não em seu próprio nome, mas em nome dos seus associados, artistas, compositores e demais titulares de direitos autorais. Dessa forma, o Ecad e as associações que o compõem, como depositários destes recursos, possuem deveres fiduciários com relação ao grupo difuso que a eles contribui, quanto ao grupo difuso que deles deve receber. Dessa relação fiduciária emerge a necessidade de regulação do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> sistema de gestão coletiva".
>
> (LEMOS, Ronaldo. "A gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil: a regulação do Ecad e sua reforma". In: GUERRA, Sérgio (Org.). *Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014, p. 347)

Praticamente todas as alterações específicas promovidas pela Lei 12.853/2013 foram impugnadas nas ADIs nº 5.062 e 5.065, como consta do relatório. Elas serão analisadas pontualmente mais adiante. Antes, porém, de finalizar estas premissas teóricas, proponho à Corte fixar diretrizes claras para a revisão judicial de marcos regulatórios setoriais.

II.(b).5. O papel do Poder Judiciário na revisão de marcos regulatórios setoriais: parâmetros de atuação.

Consoante o entendimento que já sustentei ao relatar as ADIs nº 4.679, 4.747, 4.756 e 4.923, proponho, agora em dois enunciados objetivos, uma orientação geral que conduza à racionalidade e à previsibilidade da atuação do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, na revisão de marcos regulatórios setoriais.

Os parâmetros propostos visam a estimular a efetiva prestação de contas (*accountability*) das autoridades estatais às instâncias de controle em um Estado Democrático de Direito, em particular ao povo, o real detentor do poder soberano. A ideia é conjugar a construção de incentivos corretos para o aperfeiçoamento do processo político decisório com as características institucionais do Poder Judiciário. Eis os parâmetros:

> 1) Quando as escolhas regulatórias (legislativa e administrativa) forem transparentes, no sentido de clara e minimamente justificadas, com a explicitação dos objetivos perseguidos e a identificação dos motivos determinantes, o exame judicial deve ser deferente, limitando-se a invalidar atos estatais nas hipóteses de erro manifesto, como a contrariedade frontal a regra constitucional ou a falta evidente de pertinência

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> entre os meios eleitos e fins visados;
>
> 2) Quando as escolhas regulatórias (legislativa ou administrativa) forem opacas, no sentido de omitirem os seus motivos determinantes ou de não identificarem os objetivos perseguidos, recai sobre a medida estatal caráter suspeito, o que justifica um exame judicial mais rigoroso (escrutínio estrito).

Havendo transparência na escolha regulatória, o primeiro parâmetro postula, para usar categoria apresentada pelo professor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, a *autorrestrição estrutural* em razão tanto da legitimidade político-democrática quanto da capacidade epistêmica dos órgãos reguladores, como, *in casu*, o Poder Legislativo (*Dimensões do ativismo judicial do STF*. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 180-181). Explico.

Em uma democracia, a Constituição é o documento fundante, mas não exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria dos dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na Lei Maior. Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos, disciplinar, com significativa margem de conformação, os conflitos intersubjetivos. Nesse cenário, toda inflação semântica dos enunciados constitucionais implica supressão de espaço de escolha das maiorias eleitas. Bem por isso já advertia o Chief Justice Marshall, da Suprema Corte Norte-americana, que *"We must never forget that it is a constitution we are expounding"* (McCulloch v. Maryland - 1819).

Reservo ainda dúvidas quanto à real capacidade de juízes, com formação intelectual, via de regra, estritamente legalista, procederem a um exame profundo sobre a correção técnica de marcos regulatórios específicos. À pouca expertise se somam as limitações de tempo e de informação típicas do processo judicial, o que tende a gerar uma perspectiva, senão equivocada, ao menos parcial do problema regulatório ("visão de túnel"). Tais contingências justificam cautela e prudência, rechaçando qualquer visão messiânica do Poder Judiciário como instância redentora da sociedade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

Ao mesmo tempo, porém, não se pode adotar uma visão romântica da autoridade estatal. O mito da benevolência dos governantes vem sendo desmistificado desde a segunda metade do século XX com os estudos da Teoria da Escolha Pública (*Public Choice Theory*). Trata-se de área do conhecimento que emprega a metodologia econômica para lidar com questões tradicionais de ciência política (cf., dentre outros, DOWNS, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper, 1957; BUCHANAN, James M., TULLOCK, Gordon. *The Calculus of Consent*: *Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962). Esse aporte teórico ajuda a identificar a estrutura de incentivos a que estão sujeitos legisladores e burocratas, nem sempre pautados pelo interesse público.

Dentre os problemas diagnosticados, destaca-se, pela sua especial relevância, a chamada *captura regulatória*, assim compreendida a manipulação do processo de decisão coletiva em favor de determinados grupos de interesse, geralmente mais organizados, e em detrimento de toda a sociedade (cf. BÓ, Ernesto Dal. "Regulatory capture: a review". *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 22, nº 2, 2006, pp. 203-225). A captura regulatória acaba muitas vezes por ocasionar vício há muito conhecido na doutrina juspublicista nacional: o *desvio de poder*, seja legislativo, seja administrativo (cf. TÁCITO, Caio. "Desvio de poder legislativo". *Revista Trimestral de Direito Público.* São Paulo, nº 1, 1993, pp. 62-68; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. "O desvio de poder". *Revista de Direito Administrativo.* Rio de Janeiro, nº 172, 1988, pp. 1-19).

Pois bem. A segunda diretriz acima pretende exatamente evitar que o processo de decisão política seja forjado para favorecer interesses específicos em detrimento de toda a coletividade. A *transparência* exigida cria um ambiente propício à consistência regulatória, na medida em que constrange os agentes decisórios a explicitar, com maior rigor analítico, os motivos causadores e fins perseguidos pela intervenção estatal. A falta de transparência, a seu turno, torna a medida *suspeita*, autorizando postura mais *particularista* do Poder Judiciário no exame da sua validade jurídica. Acredito que o insulamento de juízes e tribunais na estrutura do Estado,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

assegurado por um regime de independência e imparcialidade, permite que essa análise seja feita com mais neutralidade.

Em obra dedicada ao estudo da regulação jurídica, Carlos Ragazzo, professor da FGV Direito Rio, analisou com profundidade o tema, destacando o potencial do Poder Judiciário para aumentar a *accountability* das autoridades regulatórias, produzir mais transparência e viabilizar o questionamento popular informado das escolhas públicas. Nesse sentido, registra o professor:

> "(...) o Poder Judiciário exercerá uma dupla função na revisão de marcos regulatórios: (i) evita arbitrariedades e regulações que são resultados de influência indevida de grupos de interesse, impondo limites substantivos a serem observados pelo Poder Legislativo e demais órgãos reguladores; e (ii) estimula o Poder Legislativo e as agências reguladoras a desenvolverem uma capacidade analítica maior, com a imposição de requisitos procedimentais em hipóteses específicas, a fim de que os órgãos reguladores identifiquem claramente os objetivos regulatórios, bem como a alternativa que represente a melhor relação de custo e benefício, contribuindo para o aumento da transparência e, portanto, da participação democrática".
>
> (RAGAZZO, Carlos. *Regulação Jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico*. Renovar: Rio de Janeiro, 2011, pp. 255-256)

Em suma, os parâmetros propostos buscam conciliar os *riscos* do ativismo excessivo com as *deficiências* da deferência exagerada. Passo ao exame da Lei nº 12.853/2013.

Impugnações específicas à Lei nº 12.853/2013

Após analisar detidamente o processo de formação da Lei nº 12.853/2013, bem como os documentos e os relatos de interessados e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

especialistas ouvidos durante a audiência pública, convenci-me de que a presente escolha regulatória do legislador brasileiro encontra-se motivada com clareza e consistência, o que, à luz dos parâmetros acima delineados, recomenda *deferência* à opção formulada pelo legislador brasileiro. Vejamos.

1) Art. 68, §§ 6º e 8º; Art. 98-B, I, II, VI e parágrafo único; Art. 109-A

Como registrado no relatório, os dispositivos mencionados impõem a divulgação de informações concernentes à execução pública de obras intelectuais, notadamente músicas, e à arrecadação dos respectivos direitos (art. 68, §§ 6º e 8º, e art. 98-B, I, II e parágrafo único), além de vedar a pactuação de cláusulas de confidencialidade nos contratos de licenciamento (art. 98-B, VI), estabelecendo penalidades em caso de descumprimento (art. 109-A). Segundo a argumentação articulada, tais previsões violam o disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, bem como os arts. 1º e 170 da Lei Maior.

É complexo o desafio de compatibilizar *privacidade* dos titulares e *transparência* na gestão coletiva de direitos autorais. Dificilmente alguma acomodação será unânime. A questão fundamental na presente ADI diz respeito ao caráter excessivo (ou não) da medida regulatória ao promover a restrição de algum direito fundamental invocado pelas requerentes. Não está em debate se o modelo erigido pelo legislador é, de fato, a melhor a escolha, segundo algum critério ideal (e arbitrário) de gestão coletiva.

Dito isso, adianto que as razões apresentadas não são, a meu sentir, suficientes para conduzir à declaração de inconstitucionalidade dos artigos questionados, uma vez que expostos com clareza os fundamentos e os objetivos que orientaram a atuação do legislador, bem como a lógica interna das previsões normativas, pautada, a meu ver, por equilíbrio e moderação. Colho do relatório final da CPI do Senado Federal, o seguinte trecho relativos à necessidade de transparência das entidades de gestão coletiva:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

"1) Informação plena (1) – Aos usuários não são oferecidas justificativas ou parâmetros de que tenham derivado os valores arbitrados ou os critérios de seu cálculo. O próprio regulamento de arrecadação, onde seria possível oferecer ao usuário a mínima compreensão das aplicações dos critérios de cobrança, também não é oferecido sequer em versão parcial aos usuários.

2) Informação plena (2) – Os critérios de cálculo ou arbitramento de valores são decididos em reuniões da Assembleia Geral cujas atas são registradas em cartório somente meses após surtirem efeito. Dessa forma, é frequente que sequer haja validade legal em sua aplicação, dadas as imposições legais imputáveis a associações assim tipificadas.

3) Clareza – Os usuários são submetidos a critérios sujeitos a mais de uma interpretação, ou a dupla incidência, cuja opção de aplicação está sujeita a discricionariedade ampla e exclusiva do agente cobrador, ocasionando desnecessária incerteza aos usuários, por uma desmedida e injustificável posição predominante do Ecad nesta relação.

4) Publicidade – Admitindo-se que a gestão coletiva centralizada se justifique pela inviabilidade da gestão individual de direitos que são privados, o que nela estabelece uma dimensão pública, exposta pela própria criação do Ecad em lei federal, e que se materializa na presumível isonomia entre os contemplados pelo sistema, exacerba-se o caráter não razoável das cláusulas de sigilo tão comuns em contratos entre o Ecad e seus usuários regulares, não obstante existirem determinações legais que prescrevam postura contrária. Ainda, a exigência de requisições formais, sob critérios específicos, para que se revelem os contratos firmados entre o Ecad e seus usuários regulares (públicos ou privados), demonstra uma postura passiva diante da publicidade de seus dados. Administra-se o Ecad como se a relação obrigatória (pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

inviabilidade da gestão individual, o que justifica a manutenção do sistema) entre representante (Ecad) e representado (titular), através das sociedades que o integram, se sobrepusesse às demais relações havidas no contexto da atividade desse licenciamento, a ele igualmente necessárias, especialmente:

a) a relação entre usuários e titulares, que precisam garantir que o aproveitamento econômico sobre a circulação de sua criação não seja dificultada pela imposição de preços inadequados, ou pela ausência de um sistema que equacione tais inadequações. Estas, de tão grandes e frequentes, levam a recordes no número de ações judiciais que, justificadas por uma hipotética 'tendência à inadimplência', explicam-se com maior clareza pela ótica dos estímulos perversos contida em política perdulária de 'estímulo à arrecadação', em que premiações por soluções de litígios podem alcançar os que participam decisivamente de sua instalação;

b) a relação entre usuários, que amiúde dependem da relação comercial com o representante dos titulares, pela natureza de sua utilização, e a população, de quem os usuários dependem, por sua vez, para sua sobrevivência econômica. É através de seus préstimos que predominantemente esta população tem acesso a criações, objeto do seu entretenimento; às expressões da cultura (língua, arte, tradições), que lhe fornecem o sentido de integração, e nelas a identifica; e à parcela significativa e indissociável do necessariamente diversificado sistema de informações, que é a única forma de manter os pilares democráticos na nação;

c) a relação entre o titular de obras e a população, que não pode ter no conjunto de intermediários – representantes e usuários – processos desviantes ou impeditivos de um processo natural de legitimação artística, que deve ser determinado apenas pelo jogo contínuo de interpretações 'especiais' da realidade, estas a que convencionamos classificar como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> artísticas que, formatadas em gêneros, estilos, linguagens e performances, conduzem os apelos necessários à sua aceitação e, por isso, tornam-se aptas a transformá-la, quando reiniciará o mesmo ciclo. Quando o Ecad perde a regulação do poder público, submete-se às tendências dos grupos que o controlam, favorecendo gêneros e origens a eles relacionados. Quando o 'jabá' se impõe, artificialmente legitima os vieses que vão consagrar a criação não (só) por seus atributos, mas pelo que conduzem de interesses acoplados. Fossem ainda legítimos, através da saudável disputa concorrencial, vá lá, mas no Brasil só podem ocorrer (em seu principal mercado) associados a concessões públicas, de posse dos usuários, e aos grupos que controlam o Ecad, que é detentor de uma exclusividade legal sob o caráter sui generis de empresa privada criada em lei".

Sob o prisma jurídico, é claro que uma das finalidades da Lei nº 12.853/2013 foi criar obrigações precisas de *transparência* para a gestão coletiva, a qual, como apontado acima, relaciona-se com direitos difusos (dos usuários) e coletivos (dos titulares) à informação adequada. Sob o enfoque econômico, o propósito da medida é eliminar a possibilidade de que as entidades intermediárias do setor (associações e ECAD) possam, a partir da *vantagem informacional* de que dispõem, obter rendas extraordinárias, subvertendo seu papel instrumental em detrimento tanto de usuários quanto de titulares de direitos autorais. Explico este último ponto.

De fato, como apontado no item II.(b).1 *supra*, as entidades de gestão coletiva servem, em essência, como *intermediárias* entre usuários e criadores de obras intelectuais, em particular quando se trata de execução pública. As interações entre oferta e demanda são, em regra, indiretas, ao contrário do contato direto que se estabelece entre as aludidas entidades e os usuários/titulares. É aqui que surge o espaço para ganhos oportunistas em virtude da assimetria de informação. Na presença de *opacidade*, é natural que os poucos intermediários consigam extrair o máximo de recursos de ambos os lados do mercado (usuários e autores).

Intuitivamente, não é difícil perceber que a divulgação intempestiva

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

de critérios pouco claros de arrecadação e distribuição só pode beneficiar quem distribui e arrecada valores em nome de terceiros. No jargão econômico, a pouca transparência estimulava a busca e a obtenção de "rendas econômicas", assim compreendidos *"os pagamentos a um fator de produção que ultrapassam o pagamento mínimo necessário para ter o fator ofertado"* (VARIAN, Hal. *Microeconomia*: princípios básicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 449).

Esse raciocínio abstrato ganha eco no quadro fático delineado pela CPI do Senado Federal e pelo CADE. Quando confrontados com alegações de irregularidades na gestão coletiva de direitos autorais, ambos os órgãos identificaram práticas indiciárias de comportamento oportunista pelos entes intermediários. Exemplos dessa estratégia eram o licenciamento exclusivamente baseado no repertório global (*blanket license*), que permitia a apropriação de boa parte do bem-estar do consumidor, e os valores de taxas de administração cobrados dos titulares, os quais, comparativamente ao cenário internacional, deixavam de se beneficiar dos ganhos de eficiência obtidos pelo sistema. Esses pontos serão analisados em detalhes mais à frente (itens 5 e 7 *infra*).

Por ora, é suficiente compreender que a Lei nº 12.583/2013 procura romper com esse quadro e impedir que o intermediário do sistema de gestão coletiva se torne o seu principal beneficiário. Daí que a maior transparência da gestão coletiva de direitos autorais consubstancia, a meu ver, finalidade legítima segundo a ordem constitucional brasileira, na medida em que busca eliminar o viés rentista do sistema anterior e, com isso, promover, de forma imediata, os interesses tanto de titulares de direitos autorais (CRFB, art. 5º, XXVII) quanto de usuários (CRFB, art. 5º, XXXII) e, de forma mediata, bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual como a educação e o entretenimento (CRFB, art. 6º), o acesso à cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB, art. 5º, XIV).

Assentada a validade do fim pretendido pelo legislador, resta investigar se os meios empregados observam o postulado constitucional da proporcionalidade. O meio específico é a obrigação, imposta a variados atores do mercado de direitos autorais, de ampla publicidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

quanto aos valores arrecadados de cada usuário (art. 68, §§ 6º e 8º), às formas de cálculo, bem como aos critérios de cobrança e de distribuição dos valores arrecadados (art. 98-B, I, II e parágrafo único), ressalvando-se apenas a divulgação de valores distribuídos aos titulares individualmente (art. 98-B, I, *in fine*). A Lei proíbe também a celebração de contratos de licenciamento com cláusula de confidencialidade (art. 98-B, IV).

Na dogmática jurídica, o dever de proporcionalidade constitui autêntica pauta de moderação e prudência a orientar toda a atuação do Poder Público. Sua *função* é permitir a harmonia axiológica do sistema normativo. Seu *fundamento* é a própria noção de princípios jurídicos como *mandamentos de otimização* em face de restrições fáticas e jurídicas, na esteira do magistério de Robert Alexy (*Teoria dos direitos fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 116). Sua *operacionalização* é metodologicamente desdobrada em três etapas ou fases: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

Na primeira etapa, a análise de *adequação* investiga-se a aptidão da medida estatal para atingir a finalidade almejada. Trata-se, aqui, de um cotejo entre meio e fim, a exigir que a medida eleita seja idônea à promoção do objetivo visado. Na segunda etapa, a análise da *necessidade* do ato estatal procede a um contraste entre meios alternativos de promover o fim buscado. O objetivo é perquirir a existência (ou não) de meios substitutos àquele originalmente escolhido pelo Estado e, em seguida, compará-los tanto em relação ao grau de adequação à finalidade pública, quanto ao impacto sobre bens jurídicos contrapostos. Por fim, na última etapa do itinerário metodológico, a *proporcionalidade em sentido estrito* impõe a comparação dos custos e dos benefícios da medida restritiva. Consoante a lição de Robert Alexy: *"quanto mais alto é o grau de não-cumprimento ou restrição de um princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro"* (ALEXY, Robert. "On balancing and subsumption: a structural comparison". *Ratio Juris*, vol. 16, nº 14, Oxford, dezembro-2003, p. 436 - tradução livre do original).

Na hipótese, as obrigações de publicidade são evidentemente idôneas ao fim a que se destinam, uma vez que a divulgação dos dados já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

indicados (valores pagos por usuários, bem como critérios de arrecadação e cobrança por associações) promove a transparência na gestão coletiva. Isso também pode ser dito em relação à proibição de contratos de confidencialidade entre usuários de direitos autorais e entidades de gestão coletiva, que até bem pouco tempo serviam de obstáculo significativo para os titulares exercerem o pleno direito à fiscalização do aproveitamento econômico da sua obra (CRFB, art. 5º, XVIII, *b*). Ademais, a penalidade prevista pelo não cumprimento das obrigações de transparência apenas reforça a adequação da medida, uma vez que cria mecanismo sancionatório indutor, ao menos em tese, de romper com a postura passiva que marcava a publicidade de dados no regime anterior.

A necessidade da medida também resta comprovada. Neste ponto, poder-se-ia arguir que os mesmos deveres informacionais, se restritos aos usuários e titulares de direitos autorais (e não abertos ao público em geral), imporiam sacrifício menor à intimidade dos atores envolvidos. Ainda que eu conceda este ponto, tal mecanismo não me soa eficaz para a promoção do fim visado. É que a publicidade do sistema de gestão coletiva é de interesse não só dos usuários efetivos, como também dos usuários *potenciais*, que esperam conhecer os critérios de cobrança a que estarão sujeitos, bem como os valores historicamente cobrados de usuários de perfil semelhante ao seu. Não se pode ignorar a forte tendência à *discriminação de preços* presente no setor, prática pela qual o agente detentor de poder de mercado diferencia o valor cobrado de seu produto em função da disponibilidade a pagar do comprador em busca de capturar todo o bem-estar gerado pela transação econômica.

Por fim, no sopesamento dos bens em jogo, o alegado sacrifício à intimidade dos autores encontra-se devidamente compensado pelos benefícios decorrentes da transparência na gestão coletiva. Os benefícios já foram indicados acima. Quanto ao sacrifício, qualifico-o como "alegado" pois não estou certo de que sua ameaça seja crível. Há duas razões para isso. A primeira é que a nova Lei veda a divulgação dos *"valores distribuídos aos titulares individualmente"* (art. 98-B, I, *in fine*). Parece-me pouco verossímil que os valores individuais sejam perseguidos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

por alguém a partir das informações públicas. Dado o volume de usuários de direitos autorais, é tarefa excessivamente onerosa para qualquer pessoa reunir a quantidade de informações disponíveis e, ao final, obter apenas uma vaga ideia das cifras percebidas por determinado titular. Como adverte o Min. Marco Aurélio, *"não se pode presumir o excepcional"*, sobretudo quando o excepcional é o móvel da *causa petendi* em que se funda a postulação.

A segunda razão é que a falta de transparência, como consta do relatório final da CPI do ECAD, era um histórico problema denunciado pelos próprios autores contra o Escritório Central e algumas das associações a ele vinculadas. Cuida-se aqui de um típico *dilema de agência*, que põe em evidência os conflitos de interesse que surgem em cenários gerais de *delegação* (cf. EISENHARDT, Kathleen M. "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management Review*. Vol. 14, nº 1, 1989, pp. 57-74). Na hipótese, os titulares delegam às entidades de gestão coletivas as tarefas de arrecadar e distribuir seus direitos autorais. Como já registrado acima, a falta de transparência pode incentivar condutas das associações dissociadas dos verdadeiros interesses dos titulares. Nesse contexto, é preciso cautela do Poder Judiciário para que, em nome da intimidade dos usuários, aqui invocada por quem até então se beneficiava da opacidade pretérita, não promova um retrocesso na tutela dos direitos em jogo.

Não vislumbro, nas razões apresentadas pelas requerentes de ambas as ADIs, consistência jurídica suficiente para justificar essa drástica medida que é a invalidação judicial de uma lei recém aprovada pelo Poder Legislativo brasileiro.

2) Art. 97, §1º

A regra do art. 97, §1º, da Lei nº 9.610/1998, com a redação dada pela Lei nº 12.853/2013, estabelece que as associações de titulares de direitos autorais exercem atividade de interesse público e devem atender a sua função social. As requerentes sustentam que o dispositivo em referência

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

viola os arts. 1º; 5º, XXII, XXVII, XXVIII; e 170, todos da Constituição da República.

Os argumentos não merecem prosperar. Consta do Substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a justificativa para a nova redação do art. 97, §1º, da Lei nº 9.610/1998:

> "Nossa posição encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF. Em precedente envolvendo uma das associações integrantes do Ecad, a Corte Suprema consolidou entendimento de que *'as associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal'*."

O julgamento a que se refere o legislador ordinário foi o do RE nº 201.819, em que a Segunda Turma desta Corte, capitaneada pelo voto do Min. Gilmar Mendes, assentou o seguinte:

> EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. (…)
>
> III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. **As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> **denominar de espaço público, ainda que não-estatal.** A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. **O caráter público da atividade exercida pela sociedade** e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
>
> (**RE nº 201.819**, rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2005, DJ 27-10-2006 – sem grifos no original)

É nítido que a Lei nº 12.853/2013 simplesmente explicitou, no plano jurídico-positivo, entendimento que já havia sido sufragado, no plano jurisprudencial, por órgão colegiado deste Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que a questão principal naquele julgamento não era propriamente a natureza das associações de direitos autorais, mas sim a eficácia dita "horizontal" dos direitos fundamentais. Não obstante isso, acredito que aquelas razões deem suporte à validade do citado preceito.

Como já destacado neste voto, as entidades de gestão coletiva possuem evidente natureza *instrumental*: viabilizar trocas voluntárias envolvendo propriedade intelectual, dadas as dificuldades operacionais que marcam o setor. Isso significa que tanto a *produção* de cultura (pelos autores) quanto o *acesso* à cultura (pelos usuários) dependem, em boa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

medida, do hígido funcionamento das associações arrecadadoras e distribuidoras de direitos autorais. Não fossem os elevados *custos de transação*, não haveria por que titulares e usuários optassem por negociar utilizando um *intermediário* quando pudessem fazê-lo diretamente.

Esse relevante papel *econômico* é traduzido juridicamente como a *função social* das associações participantes da gestão coletiva de direitos autorais. E mais: a *importância social* dessa função (ao permitir a existência do mercado e, *a fortiori*, o aumento de bem-estar de autores e usuários, bem como incremento da oferta e do consumo de cultura) revela a natureza transindividual de tais associações, a justificar o interesse público na sua existência e no seu adequado funcionamento. Nesse sentido também se manifestou a PGR:

> "Tais atividades não se classificam como tipicamente associativas, porquanto essas entidades, além de administrar recursos de terceiros, com natureza alimentar, exercem a relevante função social de concretizar outros valores constitucionalmente protegidos que transcendem os interesses meramente privados dos envolvidos, tais como a justa remuneração dos autores, a liberdade de expressão artística, intelectual e de comunicação e a valorização e a difusão das manifestações culturais (objeto dos arts. 5º, IX e XXVII, e 215 da Constituição da República)".

Esclareço, por oportuno, que a Lei nº 12.853/2013 não cuidou de toda e qualquer associação de autores, senão apenas daquelas encarregadas da gestão coletiva de direitos autorais. Isso foi expressamente registrado no Substitutivo apresentado ao PLS nº 129/2011: *"importante notar que o Substitutivo não cuida de toda e qualquer associação de autores, mas somente daquelas constituídas para arrecadar e distribuir direitos do autor no campo da execução pública musical"*. Destarte, apenas uma fração de associações privadas são consideradas de interesse público; fração essa de indiscutível relevância social na medida em que salutar para a exploração econômica eficiente das criações intelectuais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

À luz dessas razões, não identifico fundamentos suficientes para infirmar a validade constitucional do dispositivo impugnado.

3) Art. 5º, XIV; Art. 97, §§ 5º e 6º; Art. 98, §§ 13 e 14; Art. 99, §1º; Art. 99-A, parágrafo único

Os dispositivos citados limitam aos titulares originários (art. 5º, XIV) o direito de voto (art. 97, §5º) e a assunção de cargos de direção nas associações (art. 97, §6º); criam regras sobre a eleição de dirigentes das associações (art. 98, §§13 e 14) e estabelecem critério de voto unitário no ECAD (art. 99, §1º e art. 99-A, parágrafo único). Segundo as requerentes, tais previsões violam a liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII, XVIII e XIX), a garantia da transmissibilidade dos direitos autorais (CRFB, art. 5º, XXVII), o princípio da isonomia (CRFB, art. 5º, *caput*), bem como a propriedade privada como princípio geral da Ordem Econômica (CRFB, art. 5º, XXII e art. 170, II).

Como se observa, a Lei nº 12.853/2013 criou regras distintas de participação na gestão coletiva para titulares originários e titulares não originários (ou derivados) de obras intelectuais. Integram esta última categoria, por exemplo, as editoras musicais. Apesar dos fundamentos apresentados, não verifico, por diferentes razões, ofensa à Constituição da República na escolha do legislador quanto ao critério de discrímen nem quanto ao tratamento jurídico aplicável.

Em *primeiro* lugar, verifico que o art. 5º, XXVIII, *b*, da CRFB não prevê expressamente a participação de titulares derivados na gestão coletiva de direitos autorais. O dispositivo cita apenas criadores e intérpretes, além das respectivas representações sindicais e associativas. Ao mesmo tempo, a regra constitucional atribui ao legislador ordinário o papel de desenhar as instituições responsáveis pela fiscalização do aproveitamento econômico de obras intelectuais. Ante esse quadro normativo, não existe qualquer direito constitucional expresso à participação política ou administrativa de titulares derivados na gestão coletiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

Em *segundo* lugar, as regras impugnadas não impactam os direitos patrimoniais dos titulares derivados, que continuam a gozar das mesmas prerrogativas dominiais de que desfrutavam até então. Descabe cogitar de ofensa ao direito de propriedade. A nova Lei apenas limitou a participação destes titulares na administração associativa, privando-os das prerrogativas de votar e de dirigir tais entidade, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo econômico dos seus direitos. Entendo que as aludidas regras dizem respeito aos efeitos jurídicos do contrato de licenciamento de direitos autorais, matéria sujeita à autoridade do legislador ordinário.

Em *terceiro* lugar, a finalidade última da gestão coletiva é incentivar a criação intelectual. São os titulares originários que desempenham esse papel. Ainda que relevante, a função desempenhada pelos titulares derivados não é a primordial. O legislador, após apurar dados empíricos, constatou que gravadoras e editoras multinacionais possuem catálogo de obras de um grande número de autores, o que lhes confere maior poder decisório do que aquele dos próprios músicos e compositores. Para recuperar a centralidade natural dos criadores, a Lei nº 12.853/2013 prevê a exclusividade da participação política dos titulares originários. Não vejo vício nessa escolha legislativa, inclusive sob ângulo da isonomia, ante a importância relativa distinta de cada categoria de titulares para a criação intelectual.

Nesse exato sentido, aponto trecho esclarecedor da Informação 350/2013/Conjur-MinC/CGU/AGU, elaborada pelo Coordenador-Geral de Direito da Cultura Substituto, da Advocacia-Geral da União:

> "Não é correto inferir, todavia, que destas inovações legislativas resulte tratamento anti-isonômico entre detentores de direitos ou qualquer violação ao princípio constitucional da igualdade, pois não há como se reclamar tratamento jurídico isonômico entre indivíduos que não se encontrem em situação isonômica.
>
> Há um claro propósito na nova legislação em dar aos titulares originários de direitos autorais maior poder de decisão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> na condução das atividades das associações que representam seus interesses, e esta tendência se justifica na medida em que estes titulares são os que efetivamente participam da produção do conteúdo imaterial que compõe esta modalidade de propriedade intelectual. Sem estes, sequer haveria propriedade intelectual dos demais. Logo, não havendo isonomia de fato entre estas categorias de indivíduos, não há inconstitucionalidade na sua discriminação, desde que, obviamente, o regime jurídico distinto seja instituído pelas formas constitucionalmente admitidas, quais sejam, pela reserva de lei ou pela autonomia contratual, onde a lei é lacunosa. O que ocorre, aqui, é uma mudança de um regime contratual para um regime legal no processo decisório destas associações; se ele é mais ou menos justo com esta ou aquela categoria de associados, trata-se de questão inerente ao processo legislativo, uma vez que não esteja caracterizada a inconstitucionalidade do modelo".

Por fim, em *quarto* lugar, rejeito a arguição de ultraje à liberdade associativa. É que, como apontado no tópico anterior, as associações de gestão coletiva estão imbuídas de evidente interesse público. Cuida-se de verdadeiras associações "*não expressivas*", para utilizar a expressão do professor Paulo Gustavo Gonet Branco, registrada em obra conjunta com o Ministro Gilmar Mendes:

> "Tem-se traçado uma classificação das associações com vistas a mensurar o grau de interferência do Estado em certos aspectos da sua economia interna. Às sociedades *expressivas* (de cunho espiritual, ideológico) contrapõem-se as *não expressivas* (de finalidades profissionais ou comerciais). Neste último grupo, incluem-se as associações que se dedicam a viabilizar certas atividades essenciais aos associados, sobretudo quando atuam de forma monopolizadora. São também *não expressivas* as associações que exercem, com marcado predomínio na sociedade, uma função social ou econômica relevante. Essas associações, ao contrário das *expressivas*, estão sujeitas a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> imposições estatais relacionadas com o seu modo de existir, em virtude da pertinência a elas de outros valores constitucionais concorrentes".
>
> (MENDES, Gilmar Ferreira, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 10ª Edição, 2015, p. 308 – grifos no original)

Como já ressaltado ao longo do voto, entendo que as associações de gestão coletiva são exemplos eloquentes de *"associações que se dedicam a viabilizar certas atividades essenciais aos associados"*, de modo que existem razões consistentes a autorizar maior intervenção estatal sobre a criação, a organização e o funcionamento de tais associações. Em particular, é justificável, neste contexto, a existência de regras voltadas a minimizar a assimetria de poder econômico entre editoras musicais, muitas delas concentradoras de número significativo de obras, e autores individuais, os verdadeiros criadores intelectuais.

Rejeito as impugnações dirigidas aos artigos em referência.

4) Art. 98, §1º; Art. 98-A; e Arts. 4º , 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 12.853/2013

Os dispositivos questionados exigem a habilitação prévia das associações de gestão coletiva em órgão da Administração Pública federal para a cobrança de direitos autorais (art. 98, §1º), segundo procedimento fixado pela Lei (art. 98-A); consideram-se habilitadas as associações existentes na entrada em vigor da Lei (art. 4º e 6º), as quais devem adaptar seus estatutos em prazo determinado (art. 5º); e atribuem ao Ministério da Cultura o poder de regulamentar a gestão coletiva (art. 7º e 8º).

As requerentes alegam que as aludidas regras violam a liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII a XX), o princípio da proporcionalidade, bem como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (CRFB, art. 5º, XXXVI), na medida em que condicionam o exercício da cobrança de direitos autorais das associações preexistentes a prévia habilitação em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

órgão público federal.

As impugnações não merecem prosperar. Reitero, de início, que as normas não se aplicam a toda e qualquer associação formada por titulares de direitos autorais, mas apenas àquelas que desejam exercer a atividade específica de *cobrança* e *distribuição* de direitos autorais. Ora, a relevância transindividual da gestão coletiva, ao envolver interesses de usuários e titulares, justifica uma presença regulatória maior do Estado na criação, na organização e no funcionamento das entidades que operam no setor. Não por outra razão a Constituição da República remeteu à lei ordinária a disciplina da gestão coletiva (CRFB, art. 5º, XXVIII, *b*), de modo que é franqueado à disciplina infraconstitucional estabelecer requisitos para o exercício de cobrança e distribuição pelas associações.

Ora, se existem requisitos legais necessários para que alguém possa realizar alguma atividade, é consequência lógica imediata que exista algum órgão responsável por aferir o seu preenchimento, sob pena de, na prática, não existir requisito nenhum. Está-se aqui diante de exercício típico do poder de polícia preventivo do Estado, ou, como preferem doutrinadores mais modernos, do direito administrativo ordenador (cf. SUNDFELD, Carlos Ari. *Direito administrativo ordenador*. São Paulo: Malheiros, 2003), o qual tem no consentimento prévio da Administração Pública etapa necessária para o exercício regular de certas liberdades, como as aqui discutidas (*i.e.*, a cobrança e a distribuição de direitos autorais).

O caráter preventivo ou repressivo da fiscalização tem que ver com o momento de exigibilidade da obrigação legal. Quando ela se configura antes mesmo do início das atividades privadas, a atuação prévia da Administração Pública é justificável. É o que ocorre com algumas das imposições feitas às associações de gestão coletiva. Tome-se, por exemplo, as regras de votação e direção chanceladas no item anterior do voto. Assentada a constitucionalidade desta exigência, a sistemática deverá constar dos estatutos das associações. É natural, portanto, que o Ministério da Cultura zele pelo cumprimento da lei desde o primeiro momento possível, qual seja, após criada a entidade e antes mesmo de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

iniciada a sua atuação. Tal etapa de consentimento só existe porque antes existe uma obrigação material a ser cumprida. Válida esta última, válida será, em consequência, aquela primeira.

Ressalto que não há razão para temer que o Ministério da Cultura fixe critérios arbitrários para a habilitação de associações integrantes da gestão coletiva. O órgão encontra-se subordinado à Constituição e à Lei, não lhe sendo franqueado poder de condicionar a atividade para além do que delimitado, proporcionalmente, pelo legislador constitucional e ordinário, seja por regras específicas, seja por princípios setoriais. Em todo caso, qualquer subversão dos comandos constitucionais e legais sempre se abre ao controle pelo Poder Judiciário. Destarte, os requisitos para a habilitação prévia devem guardar íntima conexão com as obrigações materiais criadas pela Lei.

Também não vislumbro ofensa à segurança jurídica. Como se sabe, não existe, na ordem constitucional brasileira, direito adquirido a regime jurídico. Qualquer associação que atue na gestão coletiva deverá conformar-se à disciplina legal vigente, sujeitando-se às alterações supervenientes à sua criação e entrada em operação. Neste pormenor, a Lei nº 12.853/2013 foi ainda parcimoniosa ao fixar regras de transição razoáveis, como a garantia de habilitação imediata a toda associação constituída antes da sua vigência (art. 4º), além do respeito ao mandato de dirigentes em curso quando da sua entrada em vigor (art. 5º).

5) Art. 98, §§ 3º, 4º, 10, 11 e 15

Os dispositivos estabelecem regras para a negociação de preços e formas de licenciamento de direitos autorais (art. 98, §§ 3º e 4º), bem como disciplinam a destinação de créditos e valores não identificados (art. 98, §§10 e 11). Além disso, fixam prazo mínimo para que os titulares comuniquem às respectivas associações a intenção em arrecadar pessoalmente os seus direitos (art. 98, §15). As requerentes sustentam que os dispositivos violam o direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e a livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV), ambos elevados à condição de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

fundamentos da Ordem Econômica (CRFB, art. 170). Ademais, afirmam que as regras vulneram os princípios da proporcionalidade e da realidade, ao estabelecerem obrigação de cumprimento impossível e incompatível com o sistema de gestão coletiva de direitos autorais.

Os argumentos não convencem. Note-se que, diferentemente do que alegam as requerentes, a Lei nº 12.853/2013 não estipulou tabelamento de preços, limitando-se a fixar parâmetros genéricos (razoabilidade, boa fé e usos do local de utilização das obras) para o licenciamento de direitos autorais. A finalidade básica da norma foi abrir outras modalidades de negócio jurídico, até então restrito à denominada "licença-cobertor" (*blanket license*). Por tal avença, o usuário adquire, a um preço fixo, o direito a reproduzir, quantas vezes desejar e por tempo especificado, toda e qualquer obra que conste do repertório da associação contratante. A cobrança não é proporcional à utilização do conteúdo.

Para alguns usuários, esse modelo de contrato é, de fato, o mais adequado, como ocorre em locais de frequência coletiva, bem como estações de rádio e emissoras de televisão que executam programação alheia. Nestes casos, os usuários *"sequer têm conhecimento prévio de quais as obras serão por eles executadas publicamente"*, como apontam as requerentes. Não obstante isso, o licenciamento global como **única** opção de negócio é *ineficiente*, uma vez que reduz a quantidade de transações (mutuamente benéficas) realizadas no mercado e gera diversos efeitos econômicos adversos. É o que aponta a Nota Técnica subscrita pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) vinculada ao Ministério da Justiça, apresentada no aludido processo administrativo instaurado perante o CADE:

> "• **Consumidores de serviços de radiodifusão e de distribuição de conteúdos áudio-visuais**: o cartel promove um aumento de preços de insumos da cadeia produtiva de distribuição de conteúdos áudio-visuais, que são repassados - em maior ou menor grau - ao consumidor final. Isto implica valores mais elevados de assinatura, para os casos de conteúdos pagos pelo consumidor tais como televisão a cabo, ou maior necessidade de financiamento via publicidade ou menor

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

diversidade de conteúdo, no caso dos meios abertos, tais como rádio e televisão aberta. Em todo caso, o mecanismo de transmissão ao consumidor final, seja via preços seja via diminuição da variedade e qualidade de conteúdos, opera-se em relação à elevação de preços de insumos dentro da cadeia produtiva;

• **Consumidores de direitos autorais (eventos, festas, etc.)**: a elevação de preços derivada de um cartel é direta, pois ocorre no último elo da cadeia produtiva. É digno de nota, ainda, que o sistema linear de preços operado pelo cartel promove perda de diversidade e variedade de eventos, pois eventos em que seriam exibidas obras em domínio público ou de artistas que necessitam de divulgação (e, portanto, cobrariam menos pela exibição pública) teriam seus custos de realização minorados não fosse a conduta perpetrada pelo ECAD e demais investigados;

• **Empresas de radiodifusão e distribuição de conteúdos áudio-visuais**: a elevação artificial de preços de insumos derivada de um cartel gera elevação de custos de produção. O equilíbrio de mercado decorrente encontra-se em patamares menores em termos de quantidade consumida e maiores em termos de preço, se comparado ao equilíbrio do ambiente competitivo sem cartel. O cartel possivelmente impacta os lucros da indústria a jusante na cadeia produtiva, porém, outro possível efeito, derivado inclusive da diminuição artificial do mercado, é a menor quantidade de empresas, sobretudo nos segmentos em que a escala é menor. Em outras palavras, um cartel em segmento da cadeia o áudio-visual implica menor quantidade de empresas, o que seria mais esperado no segmento de radiodifusão (transmissoras de rádio). Novamente, a perda de diversidade de conteúdo é esperada, pois - de forma similar ao que se espera quanto aos efeitos da conduta sobre o segmento de eventos - poderiam surgir maior quantidade de rádios especializadas em obras em domínio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> público ou de artistas que necessitam de divulgação, não fosse o método linear e cartelizado de fixação de preços que se verificada no segmento da indústria ora investigado. Dessa forma, pode-se afirmar que o modo como opera o ECAD funciona como uma barreira à entrada a empresas no mercado de distribuição de conteúdos áudio-visuais, na medida que a obrigação de pagar uma taxa ao ECAD mesmo não utilizando nenhuma obra musical protegida por direitos autorais no Brasil desincentiva a entrada, por exemplo, de empresas especializadas em músicas internacionais ou em domínio público;" (grifos no original)

À luz desses fundamentos, a autoridade antitruste brasileira reconheceu o abuso de poder dominante do ECAD e das associações a ele vinculadas em razão do oferecimento da licença cobertor (*blanket license*) como modalidade **única** de licenciamento de direitos autorais. Segundo o voto condutor do acórdão, lavrado pelo Conselheiro Elvino Mendonça, *"a livre negociação de preços impossibilitaria, ou ao menos, dificultaria uma eventual prática de abuso de poder de mercado, haja vista que a precificação estaria mais sensível às necessidades do usuário, bem como seria mais eficiente em termos econômicos"*.

Vale ressaltar que, na oportunidade, o CADE rejeitou também os argumentos quanto à inviabilidade material de precificação proporcional ao uso das obras. Isso porque a distribuição dos valores arrecadados já é baseada em critérios de proporcionalidade. Ora, se é possível *distribuir* proporcionalmente, é também possível *arrecadar* proporcionalmente, conforme destacou o relator Conselheiro Elvino Mendonça:

> "Ora se o ECAD já possui meios suficientes para identificar e controlar o quanto exatamente de seu repertório foi utilizado, sendo que esses recursos já são utilizados para a distribuição dos valores devidos a cada Associação, resta claro que ele também possui meios suficientes para identificar e controlar o quanto exatamente de seu repertório foi utilizado. Assim sendo, seria possível a utilização de mecanismo similar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> ao utilizado na distribuição para que o ECAD proceda à Arrecadação proporcional ao efetivamente utilizado pelo usuário e em valores diferenciados, não restando um valor único a ser utilizado para cada um dos casos (Televisão, Rádio, dentre outros)"

Destarte, o que pretendeu a Lei nº 12.853/2013 foi corrigir o conjunto de distorções propiciado pelo poder de mercado das associações gestoras de direitos autorais, sem, contudo, retirar dos próprios autores e titulares a prerrogativa de estabelecer o preço de suas obras. Não há, pois, que se cogitar de violação à propriedade privada ou à livre iniciativa. Vedou-se apenas a prática *abusiva* de licenciamento **exclusivo** pelo formato cobertor. Aliás, a *blanket license* permanece lícita, desde que não seja a única modalidade de negócio disponível, como esclarece o Ministério da Cultura, posteriormente referendado pela Advocacia-Geral da União:

> "Portanto, a constitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 98 evidencia-se justamente por se tratar de medida que contribui para a efetiva proporcionalidade na fixação de preços para fruição de obras protegidas por direitos de autor sem viabilizar nem representar qualquer ameaça a métodos assemelhados às *blanket licenses*, desde que razoáveis. Ou seja, **sua utilização permanece possível sob a égide da nova legislação**, tendo em vista a multiplicidade de modalidades de fruição, as diferentes características econômicas dos potenciais usuários, princípio de economia de escala etc. desde que não atente contra direitos básicos do consumidor". (sem grifos no original)

Por esses fundamentos, rejeito a impugnação dirigida aos §§ 3º e 4º do art. 98 da Lei nº 9.610/1998 com redação dada pela Lei nº 12.853/2013. Melhor sorte não assiste às requerentes quanto aos questionamentos dos §§ 10, 11 e 15 da Lei nº 9.610/1998.

Segundo a inicial da ADI nº 5.062, os §§ 10 e 11 do art. 98 seriam incompatíveis com os §§ 3º e 4º da mesma Lei nº 9.8610/1998, porquanto, a expressão *"créditos e valores e não identificados"* e a distribuição *"dentro da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

mesma rubrica em que foram arrecadados" somente seriam compatíveis com a sistemática da licença cobertor, *"enquanto que a pretendida arrecadação proporcional à execução,* (…), *faria com que todos os créditos e valores fossem identificados e, portanto, tornariam ocioso o próprio conceito de arrecadação"*.

O equívoco do argumento está em supor que a Lei nº 12.853/2013 teria dado fim à licença cobertor. Como apontado linhas atrás, a nova disciplina legal aboliu apenas a **exclusividade** da *blanket license*, mas não a sua **existência** ao lado de outras modalidades de licenciamento, a serem negociadas pelas partes. Destarte, o dispositivo, ao contrário do arguido, apresenta nítida razoabilidade interna, uma vez que se aplica aos casos em que a licença cobertor for utilizada. Não vejo qualquer vício de validade.

Por fim, o §15 do mesmo art. 98 simplesmente estabelece prazo de antecedência mínima para que os titulares de direito autoral comuniquem as associações que integrem quanto à intenção de arrecadar pessoalmente os seus direitos. Segundo as requerentes, a regra *"representa mais uma violação ao princípio da liberdade de associação, eis que a fixação de prazos para comunicações entre Associações e associados é matéria que deve ser deliberada pelos próprios associados no âmbito das Associações por eles integradas"*.

Não endosso essas razões. De fato, existem, na espécie, interesses externos à relação entre associação e associado a justificar a previsão legal. Cuida-se da *racionalização* da atividade arrecadatória, bem como da *proteção* do usuário de obras intelectuais. Ao fixar um prazo mínimo para a comunicação, a Lei age com prudência, permitindo que a associação, ao proceder à cobrança de seu repertório, possa excluir os valores referentes ao titular que atue pessoalmente. O prazo legal minimiza as chances de que falhas de comunicação propiciem duplicidade de cobrança, tumultuando a gestão coletiva e onerando o usuário. Não verifico inconstitucionalidade.

6) Art. 98, §§ 6º, 7º e 8º

As normas exigem que as associações mantenham e disponibilizem,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

por meio eletrônico, cadastro centralizado de dados relativos aos direitos autorais (art. 98, §6º), assegurando ao Ministério da Cultura acesso contínuo e integral a tais informações (art. 98, §7º); atribuem ainda ao Ministério da Cultura o papel de arbitrar eventuais conflitos e retificar as informações necessárias (art. 98, §8º). Segundo as requerentes, essas previsões violariam o direito constitucional à privacidade (CRFB, art. 5º, X) e o princípio da proporcionalidade.

Os argumentos novamente não convencem. Conforme consta do substitutivo ao PLS nº 129/2012 apresentado perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o novo marco regulatório do setor previu *"um cadastro unificado de obras, que será administrado de forma a prevenir o falseamento de dados e promover a desambiguação de títulos similares de obras, dando-se publicidade aos dados que são de interesse público, mas preservando-se as informações de cunho somente individual como valores distribuídos a titular"*.

O interesse público na existência deste cadastro unificado de obras explica-se, portanto, a partir de duas *finalidades* básicas: (i) prevenir a prática de fraudes e (ii) evitar a ocorrência de ambiguidades quanto à participação individual em obras com títulos similares. Essas finalidades decorrem de diagnóstico fático quanto à fragilidade do sistema anterior. O "caso Milton Coitinho", apurado pela CPI do ECAD, talvez tenha sido o de maior repercussão na imprensa. Coitinho, motorista de ônibus em Bagé, cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul, foi registrado como coautor de Glauber Rocha, José Mojica Marins e Anselmo Duarte em importantes de trilhas sonoras para o cinema. Perante a CPI, Coitinho negou ter qualquer conhecimento do ECAD e afirmou que seus dados haviam sido utilizados indevidamente.

A par de qualquer discussão quanto à responsabilidade pelo ilícito, o caso revela como a pouca transparência quanto à gestão coletiva pode ameaçar a proteção efetiva do direito autoral e expor usuários a cobranças indevidas. O problema foi apontado pelo cantor e compositor Roberto Frejat, durante a audiência pública organizada neste Supremo Tribunal Federal, como fonte de sérias preocupações dos artistas. Confira-se:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> "A forma de cadastro do ECAD é precária. Se eu resolver que tenho uma música com um nome 'tal', eu simplesmente mando para o ECAD e digo que tenho uma música com o nome 'tal'. Não preciso apresentar nenhuma prova concreta de que essa música exista. Não preciso apresentar um fonograma, uma partitura de uma editora que chancele que essa música exista. Então vemos casos, por exemplo, em que uma música da Marisa Monte, do Roberto Carlos ou minha tem o mesmo nome de uma música de outro autor completamente desconhecido. No momento da distribuição, enganos podem acontecer".

Ante esse quadro fático, não considero que a Lei nº 12.853/2013, ao criar o cadastro público centralizado, tenha extrapolado os limites conferidos ao legislador para a conformação e o equacionamento de conflitos existentes entre direitos fundamentais. Com efeito, embora haja impacto sobre o direito à privacidade dos titulares, é de interesse de qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter conhecimento acerca das participações individuais nas obras, sobretudo porque o modelo regulatório admite a atuação pessoal de cada titular na arrecadação de seus direitos (art. 98, §15). Reitero que o legislador ordinário também interpreta a Constituição e, nesta empreitada, realiza ponderações em caso de tensão entre bens jurídicos igualmente dignos de tutela. A acomodação promovida pelos §§ 6º, 7º e 8º do art. 98 da Lei nº 9.610/1998 não revela nenhum excesso evidente, senão apenas uma justificável reação a vulnerabilidades identificadas no sistema anterior.

Descabe ainda afirmar que o cadastro criado pela lei impediria o uso de pseudônimos. É o que registra com precisão a Procuradoria-Geral da República:

> "A sistemática dos parágrafos impugnados não impede a possibilidade de uso de pseudônimos e heterônimos, ao contrário do que afirma a petição inicial. Mecanismos técnicos e administrativos podem compatibilizar o desejo soberano de qualquer autor de ocultar sua identidade com o cadastro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> preconizado nos dispositivos.
>
> Se algum autor desejar utilizar pseudônimo ou heterônimo e, ao mesmo tempo, fazer valer seus direitos autorais, carecerá, em alguma medida, de identificar-se ou valer-se de representantes, pois não é possível pagar os valores deles decorrentes a pessoa fictícia, a criação intelectual abstrata. Do mesmo modo poderá fazer diante do cadastro previsto no art. 98".

Por fim, reputo válida a possibilidade de retificação das informações constantes do cadastro pelo Ministério da Cultura, evitando a prematura judicialização de eventuais embates. Além disso, a solução de tais controvérsias no âmbito administrativo, por órgão especializado, tende a permitir o enfrentamento das questões a partir de perspectiva técnica. Destaco ainda que a Lei foi cuidadosa ao prever expressamente a comunicação dos interessados e o direito ao contraditório antes de qualquer intervenção do Ministério da Cultura sobre o aludido cadastro. De qualquer modo, o acesso ao Poder Judiciário (CRFB, art. 5º, XXXV) sempre estará aberto a quem se sentir prejudicado.

Destarte, verifico que foram explicitados com clareza e consistência os motivos ensejadores e os fins visados pela intervenção regulatória. Soma-se a isso o fato de que não vislumbro, na espécie, nenhum erro manifesto do legislador ordinário, seja pela contrariedade frontal a regra constitucional, seja falta evidente de pertinência entre os meios eleitos e os objetivos perseguidos. Consoante as balizas teóricas já delineadas no início deste voto, rejeito as impugnações aqui narradas.

7) Art. 98, §§ 12 e 16; Art. 99, §§ 4º, 8º e 9º

As regras estabelecem critérios para a fixação da taxa de administração praticada pelas associações (art. 98, §12) bem como para a distribuição aos autores dos valores arrecadados (art. 99, §4º), além de limitar o poder de os associados deliberarem sobre a utilização dos recursos recolhidos pelas entidades que integram (art. 98, §16). Pede-se a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos por violação à liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII a XX), bem como ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e à livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV), ambos elevados à condição de fundamentos da Ordem Econômica (CRFB, art. 170).

Os fundamentos da impugnação não merecem prosperar. Como já assentado, as associações integrantes da gestão coletiva possuem essência *instrumental*, servindo precipuamente de intermediárias entre usuários e criadores de obras intelectuais. Ocorre que, ao longo do tempo, a presença de poder de mercado aliada à ausência de regulação setorial geraram um ambiente de descontentamento de ambos os lados do mercado quanto ao desempenho intermediário dessas entidades. Foi o que registrou o relatório da CPI do ECAD:

> "A falta de concorrência, sobretudo quando aliada a outros desmandos, pode gerar estruturas ultrapassadas. O Ecad e suas associações se tornaram uma imensa burocracia, ineficiente e cara. Sugam 25% de tudo o que é arrecadado a título de direitos autorais. Há anos o ECAD comemora recordes de arrecadação, mas nem por isso reduz sua taxa de administração, atualmente em 17%. Somada às das sociedades (7,5%), representa uma das mais altas taxas do mundo. Quem paga direito autoral acha que paga muito. Mas quem recebe acha que recebe pouco".

A Lei nº 12.853/2013 procurou corrigir essa distorção, reconduzindo as entidades de gestão coletiva ao papel instrumental que justifica sua existência. Daí ter estabelecido que a taxa de administração praticada *"deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada um delas"* (art. 98, §12). Isso porque, como consta do relatório da CPI, *"arrecadar direitos em uma grande emissora de rádio na capital, que encaminha planilhas detalhadas e um volume considerável de recursos, não exige da sociedade de titulares o mesmo esforço do que o necessário para arrecadar direitos de um pequeno restaurante no interior e, ainda que haja espaço para alguma compensação sistêmica, a manutenção de um só percentual*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

para todas as categorias é inaceitável para o autor".

A justificativa da intervenção estatal é explicada pela estrutura econômica do setor, que se aproxima de um monopólio natural, em que o custo médio de atuação fiscalizatória é decrescente em relação à extensão do repertório mantido pela entidade (cf. KAHN, Alfred E. *The economics of regulation*: principles and institutions. Cambridge: The MIT Press, 1988, vol. II, p. 119: *"The critical and – if properly defined – all-embracing characteristic of natural monopoly is an inherent tendency to decreasing unit costs over the entire extent of the market"*). Nesse ambiente, é comum a presença de poucas associações como tentativa de explorar os ganhos de escala disponíveis. Ocorre que, como não são um fim em si, tais ganhos deveriam ser repassados aos autores na forma, por exemplo, de taxas de administração mais baixas. Isso, porém, não ocorria em momento anterior à Lei nº 12.853/2013. Os impactos sobre autores foram indicados pela SDE em nota técnica apresentada ao CADE, que caracterizou a atuação concertada das associações como "cartel":

> "• **Artistas (músicos, compositores, etc.):** o sistema linear e coordenado de preços empreendido pelo cartel possivelmente é mais pernicioso para este segmento da indústria. Deve-se notar que a distribuição de conteúdos áudio-visuais, no caso obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, caracteriza-se por ser um indústria ou mercado de dois lados (em inglês, *two-sided market*, estudado na literatura econômica). Os lados desse mercado são os artistas e os consumidores de suas músicas (seus fãs), sendo os meios de comunicação bem como o próprio ECAD as plataformas de intermediação. Segundo a literatura especializada, a regra de precificação em um mercado de dois lados, em geral, é relacionada ao grau de elasticidade-preço da demanda de cada mercado: cobra-se mais do segmento menos elástico e menos do segmento mais elástico. No caso dos músicos, é de se esperar que aqueles em começo de carreira sejam os mais dependentes dos meios de transmissão e comunicação (rádio, TV, eventos, etc.) para divulgação de sua obra (são, no dizer econômico, o lado menos elástico, ou mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> dependente, e de onde é extraída proporcionalmente mais renda segundo o método de precificação aqui exposto). Isto explicaria o fato de o ECAD repassar pouco ou nada a este grupo de artistas: por ser o grupo mais dependente (de menor elasticidade), são mais 'cobrados' pelo serviço de divulgação, em termos relativos ao grupo menos dependente e sobre o qual o cartel possui mais poder para extrair proporcionalmente mais renda. Por outro lado, o grupo dos artistas mais consolidados no mercado é menos afetado, pois possuem maior poder de barganha frente a gravadoras, associações e ao próprio ECAD (possuem mais alternativas de divulgação). O repasse dos preços mais elevados fixados pelo cartel, em relação às obras deste grupo de artistas, ocorre justamente para seus fãs, que são os consumidores de suas músicas. Estes consumidores são o segmento mais dependente (menos elástico) do mercado de dois lados formado por artistas de renome e fãs, tendo em vista o apelo popular, gostos e preferências que tornam tais consumidores propensos a arcar com custos maiores para ter acesso às obras daqueles. Se considerarmos os diversos grupos de artistas e fãs como um mercado de múltiplos lados (*multi-sided market*) é possível imaginar um cenário em que artistas em início de carreira 'financiem' artistas de maior renome. Porém, dado os efeitos deletérios de um cartel, boa parte do mecanismo de financiamento cruzado deve ser absorvido pelas ineficiências derivadas do cartel, devendo-se esperar que todos os grupos de artistas e consumidores tenham ganhos com o seu término". (sem grifos no original)

Diante desses fatos, o Conselheiro do CADE Ricardo Ruiz levantou relevante questionamentos acerca da dissociação entre *teoria* e *prática* no papel desempenhado pelas associações de gestão coletiva de direitos autorais. Transcrevo o trecho pertinente ao tópico pelo seu relevante teor informativo:

> "Um primeiro aspecto que gostaria de ponderar é se o ECAD e as Associações estão minimizando custos de transação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> O Conselheiro-Relator reporta, no parágrafo 319, que do total arrecadado aproximadamente 24% é retido como taxa de arrecadação, ficando o ECAD com 17% e as Associações com 7,5%. A justificativa para esta surpreende 'taxa de retenção de renda' é o custeio dos mecanismos de monitoramento e de cobrança, ou seja, é o custo da estrutura de governança necessária para minimizar os custos de transação.
>
> Ora, como explicar uma margem de retenção de renda ou taxa de arrecadação de 24% que custos de transação, que ampliação de marcados, que possibilidades de acesso, que massificação do consumo esta instituição está patrocinando e apoiando? Uma taxa de arrecadação de 24% não sugere uma minimização de custos de transação, mas sim uma extração de renda derivada de uma posição monopolística com forte presença de barreiras à entrada de rivais ou concorrentes".

Em razão desse quadro fático, não verifico vício constitucional nos arts. 98, §12 e 99, §4º da Lei nº 9.610/1998 com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.853/2013. Trata-se de instrumento de regulação jurídica lastreado em sólidas premissas empíricas e em tudo compatível com o papel instrumental das entidades de gestão de coletiva. Em verdade, é curioso que associações que alegam representar os autores estejam questionando regra jurídica nitidamente benéfica a estes últimos.

Também não verifico qualquer mácula no art. 98, §16, da Lei nº 9.610/1998, que fixa limite máximo de despesa pelas associações com *"ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva"*. A medida leva em conta a tensão latente entre interesses individuais e coletivos na oferta de obras intelectuais. Como a gestão associada surge, em geral, por necessidade prática, os autores não têm ampla margem de autonomia para se desvincularem de toda e qualquer associação. A regra em comento representa, pois, uma garantia *individual* de *cada* autor em face de *quaisquer* maiorias associativas, uma vez que limita a disposição *coletiva* de direitos que são intrinsecamente *subjetivos*.

A rigor, a prudência sobressai como a tônica da Lei nº 12.853/2013 ao harmonizar os interesses em jogo. De um lado, permitiu-se que maiorias

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

de associados pudessem, na forma de seus estatutos, conferir destinação coletiva aos recursos arrecadados, ainda que com oposição de alguns poucos titulares. Prestigia-se aqui a dimensão *social* da gestão coletiva. Por outro lado, garante-se que, para além de certo patamar, nenhum titular será obrigado a suportar a disposição de seus direitos de autor. Promove-se aqui a dimensão *individual* da criação artística. O limite de 20% foi o ponto ótimo fixado pelo legislador. Não vislumbro qualquer deficiência ou excesso neste montante.

Uma ressalva final é digna de nota. A Lei não impede, em definitivo, que os associados deliberem sobre a destinação dos recursos arrecadados. Basta notar que, após a distribuição dos valores, todo associado é livre para empregar como quiser a sua fração, inclusive em *"ações de natureza cultural e social"* que beneficiem seus coassociados de forma coletiva. Maiorias suficientemente amplas poderão então manter seus planos originais de investimento social. Só não poderão fazê-lo, uma vez ultrapassada a barreira dos 20%, às custas de quem se opuser. Forte nestas razões, rejeito as impugnações articuladas nas ações diretas.

8) Art. 99, §7º

O art. 99, §7º, da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.853/2013, impõe um dever de cooperação às associações que percam a respectiva habilitação para atuar na gestão coletiva de direitos autorais, as quais deverão transferir *"todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos"*. As requerentes alegam que o dispositivo ofende o direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), bem como a garantia da propriedade imaterial e dos segredos do negócio (CRFB, art. 5º, XXIX).

As razões apresentadas não são suficientes para infirmar a previsão legal. Reitero: as associações integrantes da gestão coletiva possuem essência *instrumental*, servindo precipuamente de intermediárias entre usuários e criadores de obras intelectuais. Nesse contexto, a propriedade associativa assume o mesmo caráter instrumental. Em particular, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

previsão legal evita soluções de continuidade na tutela dos direitos autorais em virtude de perda superveniente de habilitação por alguma entidade do segmento. As associações surgem para viabilizar o mercado. Não devem, pois, interromper seu hígido funcionamento, inclusive no momento em deixam de operar no setor. A Lei nº 12.853/2013 apenas zelou pela transição razoável e menos traumática para usuários e titulares.

Considero ainda inadequada a argumentação apresentada pelas requerentes quanto ao art. 5º, XXIX, da CRFB, que assegura *"aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País"*. Isso porque as associações de gestão coletiva não exercem empresa em sentido jurídico. Não à toa sempre lhes foi vedado pela legislação apresentar intuito de lucro. Ocorre que o parâmetro constitucional invocado é nitidamente voltado a explorações comerciais. Daí a impertinência, como registrado pela PGR:

> "Sabe-se que a argumentação em ação direta de inconstitucionalidade deve, de ordinário, prender-se à ordem jurídica constitucional, não à infraconstitucional. Sem embargo, importa a referência à Lei da Propriedade Industrial para constatar-se que as rotinas e métodos usados pelo Ecad para a arrecadação e a distribuição de direitos autorais claramente não são objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade nem de registro de desenho industrial ou de marca. Não há nem mesmo inadequação da nova norma legal com o regime da Lei 9.279/96, muito menos com a Constituição da República.
>
> Na verdade, a argumentação, de tom claramente empresarial, que as autoras desenvolvem na petição inicial a esse propósito, demonstra a visão que o Ecad dedica ao processo de arrecadação e distribuição dos direitos autorais, a confirmar que não parece verdadeiramente preocupado com a eficiência do sistema de repartição de direitos autorais, em prol dos respectivos titulares, mas com seus próprios interesses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> Confirma a avaliação da CPI do Senado Federal, no trecho transcrito acima, segundo a qual, *'de instituição que deveria ser meio pelo qual os titulares de direitos autorais perceberiam o que lhe é devido, o Ecad tornou-se um fim em si mesmo'*.
>
> A nova lei busca tão somente preservar a continuidade da arrecadação e da distribuição dos direitos autorais em respeito aos respectivos titulares, que devem ser o centro da proteção legal. Toda a estrutura de gestão coletiva desses direitos deve privilegiar os autores e os usuários, não as associações e o próprio Ecad. Dessa maneira, inexiste inconstitucionalidade".

Não verifico substrato constitucional suficiente para a invalidação judicial do art. 99, §7º, da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.853/2013. Rejeito a impugnação.

9) Art. 98-C e Art. 100-B

Os artigos estabelecem que as associações de gestão coletiva deverão prestar contas dos valores recebidos aos seus associados (art. 98-C, *caput*), os quais, embora ostentem legitimidade para exercer a fiscalização diretamente (art. 98-C, §1º), podem provocar o Ministério da Cultura em sua defesa caso não sejam atendidos de plano (art. 98-C, §2º). Além disso, estabelecem que compete a órgão da Administração Pública Federal o poder de arbitrar conflitos entre usuários e titulares de direitos autorais bem como entre titulares e suas associações a respeito de direitos disponíveis (art. 100-B).

As requerentes postulam a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos ao fundamento de violação à livre iniciativa (CRFB, art. 1º e 170), ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) e à separação de Poderes (CRFB, art. 60, §4º, III). Em particular, a impugnação dirigida ao art. 98-C tem como foco o §2º. Consoante as requerentes, a intervenção do Estado não se justifica, já que a omissão de qualquer entidade deve ser questionada junto ao Poder Judiciário, e não perante o Poder Executivo. Analogamente, o art. 100-B representaria interferência estatal indevida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

sobre direitos privados e disponíveis, *"em relação aos quais não há qualquer fundamento constitucional que autorize a interferência do Poder Executivo"*.

Não há como concordar com os argumentos. Como aponta a PGR, *"a mediação e a arbitragem têm sido crescentemente recomendadas como via mais célere e menos custosa de composição de litígios, ante as imensas dificuldades operacionais que acometem o Poder Judiciário"*. Nesse sentido, os dispositivos em comento promovem duas finalidades constitucionalmente legítimas: (i) minimizam a demanda do Poder Judiciário, já abarrotado de causas a espera de solução; (ii) propiciam a análise do conflito por especialistas no tema, o que gera decisões mais adequadas para a efetiva composição da lide material.

As previsões legais vão ainda ao encontro das iniciativas conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em racionalizar o acesso ao Poder Judiciário, tais como a Semana Nacional da Conciliação, o Prêmio "Conciliar é Legal" e os diversos cursos de formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário em métodos consensuais de solução de conflitos. A propósito, cabe transcrever trecho da última edição do Manual de Mediação editado pelo CNJ:

> "Segundo o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, a cada ano, para cada dez novas demandas propostas no Poder Judiciário brasileiro, apenas três demandas antigas são resolvidas. Some-se a este preocupante dado que se encontram pendentes cerca de 93 milhões de feitos. Sem dúvida, vivemos sério problema de déficit operacional.
>
> Algumas das atuais soluções para esta delicada situação deficitária envolvem preocupação essencial com o uso racional e eficiente da máquina estatal. Isto porque frequentemente, constatamos partes que, após longos períodos de litígio, recebem integralmente o pedido posto na inicial, mas ainda assim não sentem que 'venceram o conflito'. Ainda mais quando a vitória é parcial. Certamente se pode afirmar que, se uma parte vence – parcial ou integralmente – uma disputa, mas ainda se encontra insatisfeita ao final do processo, há algo no uso da máquina estatal a ser questionado".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). *Manual de Mediação Judicial*, 5ª Edição. Brasília: CNJ, 2015)

Não há que se cogitar de violação à livre iniciativa, ao direito de propriedade ou à separação de Poderes. A prerrogativa contida no artigo 98-C, §2º, evita a judicialização de questões jurídicas simples, como as relativas à prestação de contas por associações a associados. Vale lembrar que as associações de gestão coletiva administram recursos alheios, sendo inquestionável o dever de transparência para com os titulares de direitos autorais. Induvidoso o dever, tanto melhor que eventual recalcitrância em cumpri-lo seja solucionada sem a necessidade da intervenção judicial. Foi o que fez a Lei nº 12.853/2013.

Quanto à mediação e à arbitragem prevista no art. 100-B, a própria Lei ressalvou, como não poderia deixar de ser, a autoridade do Poder Judiciário, cuja tutela é assegurada constitucionalmente (CRFB, art. 5º, XXXV). Em verdade, a disciplina legal apenas possibilita a solução por vias alternativas às judiciais, sem impedir, por qualquer modo, o acesso à justiça. Obviamente, a submissão das partes à mediação ou à arbitragem dependerá sempre de **anuência expressa e mútua**, como ressalvou o Supremo Tribunal Federal ao julgar, incidentalmente, válida a Lei de Arbitragem brasileira (Lei nº 9.307/1996) nos autos da Sentença Estrangeira nº 5.206:

> "EMENTA: (…) 3. **Lei de Arbitragem (L. 9.307/96)**: constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> manifestação de vontade da parte na **cláusula compromissória**, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF".
>
> (**SE nº 5.206 AgR**, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 12/12/2001, DJ 30-04-2004 – grifos no original)

A ressalva quanto a apreciação judicial também está prevista expressamente no art. 25 do Decreto nº 8.469/2015, que regulamentou a gestão coletiva. Ademais, a Instrução Normativa nº 4, de 7 de julho de 2015, que aprova o regulamento de mediação e arbitragem no âmbito do Ministério da Cultura, é clara ao reconhecer que *"a solução de controvérsias, no âmbito da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, somente será possível mediante* ***acordo expresso entre as partes***" (art. 2º).

Sobressai, a toda evidência, o caráter *voluntário* da submissão de eventuais conflitos decorrentes da gestão coletiva à solução por mediação ou arbitragem perante órgão da Administração Pública federal. Essa voluntariedade decorre diretamente da Constituição da República (CRFB, art. 5º, XXXV), como reconhecido pelo STF (SE nº 5.206) e devidamente respeitado pelo legislador ordinário (Lei nº 9.610/1998, art. 100-B), pelo Chefe do Poder Executivo federal (Decreto nº 8.469/2015, art. 25) e pelo Ministério da Cultura (IN nº 4/2015, art. 2º). Tal atributo impede que se cogite, na hipótese, de ofensa à livre iniciativa, ao direito de propriedade ou à separação de Poderes.

10) Art. 99-A, *caput*

O art. 99-A da Lei n° 9.610/98, introduzido pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013, autoriza órgão da Administração Pública federal a tornar obrigatória a admissão de associados no ECAD, desde que sejam habilitados previamente para desempenhar a gestão coletiva e haja pertinência entre as áreas de atuação. As requerentes pedem a declaração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

de inconstitucionalidade do dispositivo legal por violação à propriedade privada (CRFB, art. 5º, XXII), à liberdade de associação (CRFB, art. 5º, XVII a XX) e ao princípio da proporcionalidade.

Tenho dificuldades de sufragar os argumentos apresentados nestas ações diretas por uma singela razão: o ECAD ostenta, **por força de lei**, o monopólio da arrecadação e da distribuição de direitos relativos à execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas (Lei nº 9.610/1998, art. 99). Ora, sendo o único escritório regular, nenhuma associação eventualmente barrada ou excluída do ECAD terá meios de fiscalizar e cobrar pela execução pública das obras pertencentes ao seu repertório. É evidente, neste caso, a fragilização da tutela jurídica dos direitos do autor, assegurada expressamente pelo art. 5º, XXVII, da CRFB.

A previsão legal ora questionada pretende evitar que as associações já estabelecidas na gestão coletiva possam asfixiar a criação de novas associações mediante políticas de alijamento junto ao ECAD. Nesse sentido também opina a PGR:

> "Sendo o Ecad o único ente central do sistema para arrecadação e distribuição - tanto sob a égide da redação original da Lei 9.610/98 quanto na vigência da Lei 12.853/2013 -, é necessário que as associações de titulares possam nele ingressar, desde que habilitadas nos termos da própria lei. Isso evita subjetivismos e criação de nichos de poder na condução dos negócios da entidade, justamente por sua natureza peculiar e pelo interesse público existente na sua atividade".

Esse receio quanto a práticas excludentes tem sólido lastro empírico. Com efeito, a já citada condenação por *abuso de poder dominante* imposta pelo CADE às entidades de gestão coletiva se baseou, dentre outros fundamentos, em práticas limitadoras da constituição e do funcionamento de outras associações, caracterizando *elevadas barreiras à entrada*. Ao analisar os requisitos fixados no estatuto do ECAD para o ingresso de novas associações, assim se manifestou o Conselheiro relator Elvino Mendonça, no que foi acompanhado pelos demais:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

"(...) o ingresso de uma associação administrada exige a comprovação da titularidade *sobre bens intelectuais publicados em quantidade equivalente ou superior a 10% (dez por cento) da medida administrada por sociedades componentes do ECAD* (Art. 8 item e.), ao passo o ingresso de uma associação efetiva exige a comprovação da *titularidade sobre bens intelectuais publicados em quantidade equivalente ou superior a 20% (dez por cento) da medida administrada por sociedades componentes do ECAD*. (Art. 9 item j.), além de *ter quadro social igual ou superior a 20% (vinte por cento) da média de filiados das associações efetivas integrantes do ECAD* (Art. 9 item l).

Os requisitos quantitativos são extremamente difíceis de serem alcançados, tendo em vista que o ECAD somente distribui os valores arrecadados para as Associações que dele fazem parte. Disso decorre a grande dificuldade de uma Associação possuir, *a priori*, a titularidade de bens intelectuais em quantidade equivalente ou superior a l0% para se tornar uma Associação Administrada e equivalente ou superior a 20% para se tomar uma Associação Efetiva.

Os critérios acima elencados são tão restritivos que a última Associação Efetiva a ingressar no ECAD foi a ABRAMUS (Associação Brasileira de Música) no ano de 1982, o que significar dizer mais de 30 anos atrás.

Outra cláusula de relevante interesse para a análise de barreiras à entrada refere-se àquela estipulada no Art. 8°, 'd', §1º do referido Estatuto, que impõe: *A admissão. ou manutenção de entidade como associação administrada dependerá de decisão da Assembléia Geral, nos termos da alínea 'o' do artigo 28, deste estatuto*.

Tal critério é abusivo, na medida em que permite que as Associações existentes controlem, juntamente com o ECAD, o ingresso de novas associações no mercado de direitos autorais. No entanto, a competência para determinar a entrada no Mercado não foi outorgada ao Escritório Central ou as Associações em nenhum mandamento normativo. Sendo assim, tal cláusula aponta inversão lógica do sistema da gestão coletiva

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

> dos Direitos Autorais, vez que permite o bloqueio, por parte dos concorrentes, a entrada de novas Associações.
>
> Sendo assim, considerando que (i) os requisitos quantitativos para ingresso de novas associações são extremamente restritivos e que (ii) a aprovação para o ingresso de novas associações depende da aprovação da Assembleia Geral do ECAD, a entrada de uma associação neste mercado não é provável".

A dificuldade de acesso de novas associações ao ECAD gera ainda efeitos deletérios sobre o esquema de *incentivos* imposto às associações gestoras. Em nota técnica já mencionada, a SDE apontou que a criação de novas entidades coletivas impõe pressão competitiva sobre as associações já estabelecidas, que tenderão a ser mais eficientes, oferecendo serviço de qualidade e com maior retorno financeiro para seus associados. *"Do contrário, os associados poderiam trocá-las por associações mais sensíveis aos seus interesses ou mesmo procurar constituir novas associações para melhor representá-los"*. Destarte, a facilidade de ingresso junto ao ECAD é fator diretamente relacionado à maior proteção dos autores, os verdadeiros responsáveis pela criação intelectual.

Não enxergo, na regra legal, qualquer ofensa à propriedade privada, à liberdade de associação ou ao princípio da proporcionalidade. Descabe falar de *"expropriação do direito de propriedade das associadas pré-existentes"* em razão da *"redução de sua quota parte no acervo social"*. A prevalecer este argumento, somente poderia ingressar no ECAD quem fosse admitido pelas associações já existentes, o que, em um regime de monopólio legal, enseja ampla margem para abusos, como os constatados pelo órgão antitruste brasileiro. A objeção suscitada pelas requerentes somente teria lugar em um modelo de livre criação de escritórios de arrecadação, o que não ocorre no Brasil, como aliás chancelado pelo STF desde 2003 (ADI nº 2.054).

A liberdade de associação também não permite invalidar a disciplina legal. Como apontado pelo Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI nº 2.054, *"o ECAD, em sua moldura legal, é uma associação de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

associações, isto é, de pessoas jurídicas. Na melhor das hipóteses, é mais duvidosa a aplicação sem temperamento às pessoas jurídicas das normas constitucionais da liberdade de associação". Acrescento a este ponto um outro: o ECAD é uma entidade sem fins lucrativos criada, em regime de monopólio legal, para servir à gestão coletiva e, assim, aos próprios autores. Tal monopólio concedido pelo Estado autoriza maior intervenção do Poder Público sobre a dinâmica de funcionamento da entidade, a qual, deixada por si, já provou desvirtuar-se dos propósitos que justificam as suas prerrogativas.

Por fim, o argumento de violação à proporcionalidade não se encontra minimamente fundamentado. Na ADI nº 5.062, as requerentes limitam-se a afirmar que *"a associação compulsória por determinação da administração pública (…) afigura-se desproporcional, inadequada e inconstitucional. Isso porque não cabe, em qualquer hipótese, a órgão do Poder Executivo estabelecer os critérios aplicáveis à admissão de associados em qualquer associação de natureza privada"*. Não houve cuidado analítico em demonstrar quais etapas do dever de proporcionalidade não teriam sido atendidas. A meu sentir, porém, a medida revela-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

A idoneidade é evidente, porquanto a regra legal reduz as chances de que as associações já existentes criem barreiras à criação de novas entidades, justamente a finalidade do preceito. A exigibilidade também é clara. Não imagino qualquer meio alternativo capaz de, com a mesma intensidade, promover a finalidade pretendida. O acesso ao Escritório Central era um instrumento poderoso de controle da gestão coletiva pelas associações já estabelecidas. A regra legal quebra essa hegemonia ao franquear acesso amplo ao ECAD. No sopesamento de bens, também não visualizo qualquer vício. Os bens supostamente restringidos, como a propriedade privada e a liberdade de associação, não desfrutam, em razão do monopólio legal, de proteção tão categórica como fazem crer as requerentes.

Rejeito a arguição de inconstitucionalidade dirigida ao art. 99-A da Lei n° 9.610/98, introduzido pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

III. Conclusão e Dispositivo

Concluo o voto com uma observação. Em hermenêutica constitucional, é preciso cuidado para que a interpretação ampliativa de princípios considerados fundamentais não se convole em veto judicial absoluto à atuação do legislador, que também é um intérprete legítimo da Lei Maior. Garantias gerais como *liberdade de iniciativa*, *propriedade privada* e *liberdade de associação* não são, por si, incompatíveis com a presença de regulação estatal. Aliás, o próprio monopólio do ECAD é produto de intervenção do Estado, tendo sido chancelado por este STF sob aplausos das associações requerentes. Daí a necessária cautela para que a retórica dos direitos fundamentais não se torne *insaciável*, devoradora do espaço político de deliberação coletiva (PINTORE, Anna. *I diritti della democrazia*. Laterza: Editori Laterza, 2003).

A propósito, ressalto que, na experiência internacional, em diferentes democracias constitucionais, é variado o grau de participação do Estado na gestão coletiva de direitos autorais (GERVAIS, Daniel (org.) *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Alphen aan Den Rijn: Kluwer Law International, 2nd Edition, 2010). A pluralidade de regimes sugere que não existe um modelo único, perfeito e acabado de atuação estatal neste campo. O maior ou o menor protagonismo do Poder Público depende das escolhas políticas das maiorias eleitas. No Brasil, em 1973, a Lei nº 5.988 previu um modelo regulatório com ampla supervisão estatal. Em 1998, com a Lei nº 9.610, optou-se por não haver supervisão pública. Em 2013, a Lei nº 12.853 retomou, com prudência e cautela, como pude constatar, o monitoramento, agora exercido pelo Ministério da Cultura. Essa experimentação de diferentes modelos ao longo dos tempos é a essência do jogo democrático.

Por essas razões, voto no sentido de, em sede preliminar, **conhecer** integralmente as postulações deduzidas nas ADIs nº 5.062 e nº 5.065 e, no mérito, **julgar improcedentes** todos os pedidos articulados em ambas as ações diretas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384512.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, eminentes Pares, inicialmente, permito-me cumprimentar Sua Excelência, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, pelo zelo, cuidado e acutíssimo voto como sói ocorrer com Sua Excelência. Quero também cumprimentar todos os Advogados que ocuparam a Tribuna para contribuir com o desate desta matéria.

E, com esses cumprimentos, Senhor Presidente, registro que examinei o vasto material que compõe o conjunto de temas que debatem, o que poderíamos denominar de escolha regulatória do legislador brasileiro sobre a gestão coletiva e aproveitamento econômico dos direitos autorais, vale dizer, a Lei 12.853/2013. E, da análise que fiz, cheguei precisamente às mesmas conclusões de Sua Excelência, o eminente Relator.

Portanto, estou minudenciando essas conclusões numa declaração de voto, que juntarei ao feito, a fim de prestar contas da fundamentação desse posicionamento.

Para ser breve e objetivo, do ponto de vista da conclusão, reportando-me ao que consta dessa declaração de voto, que, em termos gerais, vai ao encontro dos argumentos, das premissas do desenvolvimento e evidentemente das conclusões a que chegou o Ministro Luiz Fux, Relator, para, acompanhando Sua Excelência, conhecer das ações diretas de inconstitucionalidade e também julgar improcedentes os pedidos, todos os pedidos aduzidos em ambas.

Nessa declaração, concluo, a intervenção - e a ela fazendo referência -, estou ressalvando, Senhor Presidente, que se, do exercício concreto dos direitos e deveres impostos pela Lei 12.853, resultar práticas que afrontem as normas constitucionais protetivas das liberdades, ora invocadas, certamente as portas do Poder Judiciário e desta Suprema Corte estarão abertas para garantir, por meio dos mecanismos processuais,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10931990.

constitucionalmente adequados, a legítima tutela jurisdicional.

No estágio e do modo que as pretensões foram deduzidas, outro caminho não me parece haver senão aquele apontado por Sua Excelência, o Relator.

É como voto, acompanhando integralmente a posição do Ministro Luiz Fux.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10931990.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Como bem destacado no acutíssimo voto do Ministro Relator, as presentes ações diretas de inconstitucionalidade impugnam uma escolha regulatória do legislador brasileiro, a qual diz respeito à gestão coletiva e aproveitamento econômico de direitos autorais previstos na Lei 12.853/2013.

Devo desde já declarar que acompanho integralmente o voto do Ministro Luiz Fux, seja quanto ao conhecimento das duas ações diretas de inconstitucionalidade – ADI 5.062 e ADI 5.065 –, seja quanto ao mérito, abrangendo os dois aspectos aduzidos: i) a alegação de inconstitucionalidade formal – por também não vislumbrar afronta direta às normas constitucionais relativas ao processo legislativo que deu origem à norma impugnada –; ii) bem como as alegações de ofensa material às normas constitucionais invocadas.

Os argumentos centrais das duas ações diretas convergem na afirmação de que a escolha regulatória feita na Lei 12.853/2013 é incompatível com os princípios constitucionais que protegem a livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência, a propriedade imaterial e os direitos fundamentais de autor, a ordem econômica, a intimidade e a vida privada, a liberdade de associação e a separação de poderes.

Da leitura do vasto material que compõe o acervo disponível para a análise das presentes ações diretas de inconstitucionalidade, convenci-me, na mesma esteira do que propõe o voto do Ministro Luiz Fux, que, no caso, a opção do legislador infraconstitucional foi transparente, suficientemente motivada e compatível com a função constitucional que lhe é destinada.

Em um Estado Constitucional e Democrático de Direito, a concretização das normas constitucionais, especialmente aquelas que definem direitos fundamentais, constitui tarefa compartilhada pelos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203205.

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, de modo que não vislumbro, na proposta regulatória materializada na Lei 12.853/2013, intervenção estatal desproporcional, a ferir o exercício de direitos autorais, nem a liberdade de associação ou a livre iniciativa e concorrência, próprias dessa esfera de regulação.

Tal como exaustivamente pontuado no voto do Ministro Relator e também no cuidadoso e percuciente parecer da Procuradoria-Geral da República, a Lei 12.853/2013 buscou corrigir algumas distorções encontradas no sistema regulatório anterior, com o objetivo de expurgar distorções históricas evidenciadas em Comissões Parlamentares de Inquérito e também pelo CADE, tais como: i) ausência de transparência da arrecadação e distribuição dos valores, ii) preços abusivos no licenciamento, iii) taxas elevadas de administração, iv) indevido controle de ingresso de novas associações no mercado de gestão coletiva de direitos autorais, v) fraudes e obscuridades no registro de obras, vi) além de litigiosidade excessiva no setor.

Conforme pude verificar, a Lei 12.853/2013 deu aos titulares de direitos autorais e aos usuários/consumidores de suas obras protagonismo jurídico, ou seja, ao prever regras de publicidade, fim do licenciamento exclusivo por valores globais (*blanket license*), ao estabelecer limites máximos para taxas de administração, bem como a liberdade de criação de novas associações, exigência de maior transparência e supervisão do Ministério da Cultura sobre o registro e aproveitamento econômico das obras, e a previsão de mecanismos de autocomposição de eventuais litígios no setor, a Lei 12.853/2013 convocou também os titulares dos direitos autorais para atuarem na direção de uma maior eficiência, idoneidade, isonomia, transparência e devida prestação de contas para o setor.

Assim, para não me tornar redundante em relação ao que já foi brilhantemente exposto pelo Ministro Relator, devo concluir afirmando que não vislumbro aqui a necessidade da intervenção aperfeiçoadora do Poder Judiciário, especialmente deste Supremo Tribunal Federal, na opção regulatória do legislador infraconstitucional quanto à gestão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203205.

coletiva dos direitos de autor, pois da análise dos argumentos trazidos em todo o material analisado – inclusive os ilustres pareceres de especialistas da área –, convenci-me de que as garantias constitucionais da liberdade de iniciativa, da propriedade privada, da liberdade de associação e da livre concorrência foram observadas e concretizadas no marco regulatório que ora se analisa.

Não obstante, venho ressalvar que, se do exercício concreto dos direitos e deveres impostos pela Lei 12.853/2013 resultar práticas que afrontem as normas constitucionais protetivas das liberdades ora invocadas, certamente as portas do Poder Judiciário – e eventualmente desta Suprema Corte – estarão abertas para garantir, por meio dos mecanismos processuais constitucionalmente adequados, a sua legítima tutela jurisdicional.

Ante o exposto, acompanho integralmente o Ministro Luiz Fux, para **conhecer as ações diretas de inconstitucionalidade** (ADI 5.062 e ADI 5.065), e, no mérito, **julgar improcedentes os pedidos aduzidos em ambas**.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203205.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, eu cumprimento, em primeiro lugar, os eminentes advogados que estiveram na tribuna desenvolvendo um excelente trabalho. A simples possibilidade de ouvi-los já foi extremamente ilustrativa de quais são as questões que estão em jogo. Tanto o Doutor Pedro Paulo Cristófaro, Doutor Roberto Corrêa de Mello, Doutor Carlos Fernando Mathias de Souza, Doutor Sydney Sanches, Doutora Grace Maria, pela AGU, e Doutor Rodrigo Brandão, os cumprimentos - meus, pessoais e de todo o Tribunal - pela contribuição que prestaram na compreensão da matéria.

E cumprimento, sobretudo, o eminente Ministro Luiz Fux. O voto de Sua Excelência é, sem favor, um minicurso de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, de Direito Regulatório, de Direito Econômico e, portanto, há um conjunto vasto de questões ali tratadas com grande proficiência e profundidade.

Eu concordo com Sua Excelência em relação às preliminares e concordo igualmente que não há inconstitucionalidade formal. E concordo, sobretudo - e esse eu penso que seja o ponto central -, com a visão de qual deva ser o papel do Poder Judiciário na discussão de questões de altíssima complexidade técnica, como as que estão envolvidas aqui. E, portanto, não acho que o Judiciário deva desempenhar o papel de rever o mérito de determinadas decisões políticas. Acho que a nós cabe controlar vícios de procedimentos, se tiverem ocorrido; evidentemente, vícios de confronto ostensivo da norma infraconstitucional com a Constituição ou de manifesta irrazoabilidade intrínseca do conteúdo dessas normas. E penso que esses vícios não se revelam de maneira nítida aqui.

O que se pode fazer, eventualmente, são críticas de natureza política quanto ao grau de intervenção, a conveniência da intervenção. E eu compreendo as muitas manifestações feitas da tribuna, mas não acho que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12369658.

o papel do Judiciário seja o de um revisor de juízos políticos feitos pelo Legislativo para que nós possamos sobrepor as nossas preferência àquelas que foram manifestadas pelos representantes políticos.

De modo que, tendo em vista esta limitação, Presidente...

Eu tenho um voto mais ou menos da mesma extensão do do Ministro Luiz Fux, mas eu não vou lê-lo, e tenho um brevíssimo resumo em quatro proposições que expressam, em concordância com o Relator, a minha visão nessa matéria. E as proposições são as seguintes:

As entidades de gestão coletiva exercem importante função social ao facilitar trocas voluntárias de mercado envolvendo direitos de propriedade, o que justifica o interesse público pelo seu correto funcionamento.

Portanto, não acho que haja invasão indevida do Poder Público em atividade estritamente privada, pelas razões que foram, a meu ver, adequadamente expostas pelo eminente Relator.

A Lei nº 12.853, de 2013, surge como uma tentativa de equacionar os problemas do modelo anterior de gestão coletiva dos direitos autorais, que apresentaram diversas falhas. E essas falhas se encontram amplamente documentadas nos autos, tanto por decisões do CAD, como por decisões ou manifestações das CPI's, como manifestações colhidas nas audiências públicas. Portanto, que havia problemas graves com o modelo anterior, é fora de dúvida, e acho que havia um reconhecimento geral nesse sentido a justificar uma intervenção do legislador.

E penso, com todas as vênias dos entendimentos diversos, que as alterações promovidas garantem maior transparência, eficiência, modernização e fiscalização na gestão de direitos coletivos.

Eu, por convicção filosófica, entendo que monopólios, sejam estatais, sejam privados, são, por definição, problemáticos e tendem a produzir ineficiência e abuso de poder.

Em quarto lugar, penso que a Lei, ao impor obrigações de transparência na gestão coletiva de direitos autorais de forma proporcional, ela, em lugar de violar, a meu ver, protege os interesses dos titulares de direitos autorais e também dos usuários ao mesmo tempo em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12369658.

que preserva e promove bens jurídicos socialmente relevantes relacionados à propriedade intelectual, tais como educação, entretenimento, acesso à cultura e à informação.

E, por fim, Presidente e eminente Relator, a quem... Não quero ser redundante, mas um trabalho verdadeiramente primoroso de análise da matéria.

As restrições criadas pela Lei nº 12.853, de 2013, buscam reconduzir as entidades de gestão coletiva à sua função meramente instrumental, servindo como intermediárias entre usuários e criadores de obras intelectuais.

De modo que, de novo reiterando que não é papel do Judiciário aferir se havia alternativas melhores, mas apenas invalidar o que seja incompatível com a Constituição, também julgo inteiramente improcedente o pedido.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12369658.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o Ministro-Relator produziu um exaustivo e denso voto, a cujos fundamentos, com as devidas loas, eu me reporto para acompanhar Sua Excelência, rejeitando as preliminares e julgando improcedente todos os pedidos.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11983246.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, estas ações direta de constitucionalidade – ADIs nºs 5.062 e 5.065 – estão a propiciar, no seio desta Corte, exame de tema que se revela da mais alta complexidade. Foi realizada uma audiência pública extremamente produtiva, foram apresentados memoriais, foram produzidas excelentes sustentações orais, que em muito contribuíram para o debate. Não tenho a menor dúvida com relação a isso.

Mas, assim como o eminente Relator, e pedindo vênia às compreensões contrárias, não visualizo, na Lei nº 12.853, de 2013, qualquer violência à Constituição Federal. Destinou-se ela, isto sim, a meu juízo, na minha avaliação, a uma necessária correção de rumos para o aperfeiçoamento do modelo de gestão coletiva dos direitos autorais e conexos, justamente no resguardo dos seus titulares quanto ao aproveitamento econômico da execução pública das obras.

Em jogo atividade privada de interesse público, não visualizo – repito – intervencionismo estatal em contrariedade à nossa Lei Fundamental, e sim uma atuação fiscalizadora, no exercício de legítimo poder de polícia – bem destacado pelo Procurador-Geral da República – e autorizado pelo constituinte originário (CF, art. 5ª, XXVIII, "b").

O desenho do modelo de gestão coletiva dos direitos autorais, afeto, em suas nuances, ao legislador ordinário, e que se alterou ao longo do tempo em nosso país – conforme muito bem historiado pela Doutora Grace em sua sustentação oral –, na verdade, resulta de uma escolha política que não cabe ao Poder Judiciário. Espera-se apenas que haja de fato um aperfeiçoamento, para que os direitos autorais e conexos, sobretudo no que diz com a arrecadação e a distribuição, se tornem cada vez mais efetivos, cada vez mais revestidos de efetividade.

Então, reportando-me, Senhor Presidente, aos fundamentos preciosos e, como sempre, muitíssimo bem-lançados pelo eminente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12824709.

Relator, Ministro Luiz Fux, no seu voto, eu também rejeito as preliminares e julgo improcedentes os pedidos deduzidos nas duas ações autorais diretas de inconstitucionalidade.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12824709.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também não posso deixar de começar sem fazer referência tanto ao voto do Ministro Fux - que é primoroso, tendo nele se tratado de todos os assuntos abordados na ação e que nos veio antes -, quanto também à participação dos Senhores Advogados, tanto nos memoriais, quanto aqui. Cumprimentarei a todos na pessoa da Doutora Grace, que tanto tem honrado, assim como todos os Advogados dessa tribuna, e que é uma mineira a prestigiar as melhores tradições das Minas e dos nossos Gerais. Quero que cada um se sinta individualmente cumprimentado por mim na pessoa da doutora Grace.

Tal como o Ministro Barroso, provavelmente pelo tema, fiz voto …

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Nós, no fim de semana, teremos grande prazer em receber os votos e lê-los até o final.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, mas realmente eu não vou fazer ...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -cancelar

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, como vogal, gostaria de ter tempo pra redigir esses votos tão longos!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, e achamos tempo, Ministro, no meu caso, até pelo gosto. Mas, claro, nem voto meu eu leio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173631.

na íntegra. E menos ainda neste caso, em que eu estou acompanhando na conclusão o relator.

Queria apenas fazer referências brevíssimas. Como já foi posto aqui, os modelos de gestão coletiva de direitos autorais em todo mundo são vários - o Procurador-Geral citou alguns. Temos convenções, convenção universal sobre o direito do autor, convenções que foram internalizadas no Brasil, tratando exatamente da necessidade, e é expressa a norma de que os Estados contratantes comprometem-se a tomar todas as disposições para assegurar a proteção suficiente e eficaz dos direitos dos autores e de quaisquer outros titulares dos mesmos direitos sobre obras. Portanto, temos até obrigação de honrar o Estado, com a proporcionalidade e a razoabilidade que o Ministro Fux deixou de maneira tão clara, atuar exatamente para garantir a proteção dos direitos dos autores em área extremamente cara aos interesses públicos e à própria nacionalidade.

Neste caso, a regulação estatal, que tem natureza protetiva, somente poderia ser objeto de impugnação válida se fosse demarcando em que haveria alguma exacerbação, o que não se demonstrou ter havido.

Assim, Senhor Presidente, ponho a me lembrar aqui não de um jurista, mas basicamente de uns versos do Chico Buarque, que, em 81, falando exatamente sobre o direito à voz cantava em, "A voz do dono e o dono da voz", numa gravação da Ariola:

"[...]
Enfim, a voz firmou contrato
E foi morar com novo algoz
Queria-se pensar
[...]
Foi revelada na assembléia - atéia
Aquela situação atroz
A voz foi infiel trocando de traquéia
E o dono foi perdendo a voz
E o dono foi perdendo a linha - que tinha

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173631.

E foi perdendo a luz e além
E disse: Minha voz, se vós não sereis minha
Vós não sereis de mais ninguém."

É um pouco isso o que se tem a resguardar, quer dizer, quem é dono da voz, quem é dono da obra; é um pouco isso que se tem neste processo, quer dizer, quem é o autor - é ele e sua obra que a Constituição protege, no art. 5º, inciso XXI, alínea "b" -, é exatamente a possibilidade de o autor poder produzir livremente e ter a proteção dos direitos decorrentes de sua obra, porque é disso que ele vive.

Então, se havia desvirtuamento, as opções dos legisladores, se não contrariarem a Constituição, não têm porque receber,do Poder Judiciário medida censória no sentido de declarar a sua invalidade.

Por isso, Senhor Presidente, faço a juntada de voto e acompanhando o Ministro-Relator julgo improcedente as duas ações.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173631.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A Ministra Cármen Lúcia (vogal):

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de mediada cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira de Música e Artes e outros objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 12.853/2013 na parte em que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A ,100-B e 109-A da Lei n. 9.610/1998.

2. Os Autores argumentam que as normas impugnadas contrariam os arts. 1º, 5º, *caput*, incs. X, XVII a XX, XXII e XXVII a XXIX, 60, § 4º, inc. III, e 170 da Constituição da República.

Asseveram, em síntese, como destacado pelo Ministro Relator Luiz Fux que:

> *"os dispositivos impugnados impõem uma 'tutela estatal direta e permanente sobre o aproveitamento econômico dos direitos autorais, cuja natureza é eminentemente privada' e 'introduz no ordenamento jurídico normas desproporcionais e ineficazes para os fins a que se destinam, além de violar diretamente princípios e regras constitucionais concernentes ao exercício de direitos eminente privados e à liberdade de associação'. Afirmam que 'a necessidade de gestão coletiva desses direitos não os transforma em direitos de interesse público, a demandar tutela estatal'. Nessa linha, aduzem que 'quaisquer limitações - decorrentes de lei ou de atos administrativos – à prerrogativa constitucional de livremente usar, fruir e dispor de tais direitos somente se admite quando fundada na própria Constituição ou no legítimo exercício do poder de polícia pelo Estado. Qualquer outra restrição será incompatível com a proteção à propriedade imaterial sobre as obras musicais, com a garantia constitucional à propriedade privada e com a Ordem Econômica eleita pelo legislador*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *constitucional, baseada na liberdade dos agentes econômicos e na não interferência do Estado nas atividades privadas'. Dessa forma, concluem que os dispositivos impugnados são inconstitucionais por: 'i) introduzir tutela estatal inadmissível sobre o uso, gozo e fruição de direitos de natureza privada, restringindo indevida e desproporcionalmente a liberdade de seus respectivos titulares: (ii) limitar o direito de associação, subordinando as associações formadas por titulares de direitos autorais a controle prévio e permanente por parte do Ministério da Cultura e de órgão da Administração pública Federal não identificado, restringindo o direito de auto regulação dos associados e atribuindo ao Poder Executivo a prerrogativa de suspender as atividades de associações formadas para fins lícitos; (iii) tornar publicas informações de natureza eminentemente privada, em violação ao direito à intimidade assegurado a todos; e (iv) violar os princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da consensualidade, ao estabelecer restrições às liberdades individuais que se mostram inadequadas, desnecessárias e desproporcionais aos fins preditos na Lei e que resultam em intervenção intrusiva e preponderante do Estado sobre interesses patrimoniais privados".*

3. Em 6.11.2013, o Ministro Luiz Fux adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

4. A Presidente da República manifestou-se pela constitucionalidade da norma ponderando que *"um dos principais propósitos das alterações destinadas a conferir maior segurança e previsibilidade ao regramento de gestão coletiva foi o de induzir a circulação de obras com efeitos positivos para toda a coletividade, ampliando o acesso ao público e garantindo a percepção da remuneração dos autores por suas criações"*.

5. O Congresso Nacional também defendeu a constitucionalidade da norma aduzindo que o sistema instituído pela lei *"estabeleceu princípios para a atividade de gestão coletiva de direitos autorais no país, visando imprimir uma administração ética, equitativa, autônoma e eficiente aos vários segmentos da criação intelectual, pautada na ampla e tempestiva publicidade de todos os*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

atos da via institucional, especialmente em relação ao regime de arrecadação e distribuição dos valores cobrados".

6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento parcial da ação dada a ausência de impugnação de todos os dispositivos da Lei n. 12.853/2013 e, no mérito, pela improcedência do pedido ao argumento de

> *"ausência de violação à livre iniciativa, à isonomia, ao direito de propriedade, à liberdade de associação, à intimidade, à proteção aos segredos de negócio e à propriedade imaterial, bem como aos princípios da separação de Poderes, da proporcionalidade, da subsidiariedade e da consensualidade (artigos 1°, 5º, caput e incisos X, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIX, e XXVIII; 60, § 4º, inciso III, e 170 todos da Carta Republicana). Alterações normativas destinadas a conferir transparência e segurança jurídica aos autores, aos usuários e à própria sociedade".*

7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência do pedido:

> *"Função social dos direitos autorais. Regulamentação das atividades de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Distorções graves e crônicas no funcionamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), apontadas em comissões parlamentares de inquérito. Transparência, prestação de contas, eficiência, idoneidade, isonomia e segurança. Caráter não estritamente privado do regime jurídico aplicável. Legitimidade das normas que preveem maior atuação do poder público no funcionamento do sistema. Ausência de violação aos parâmetros constitucionais invocados".*

8. A União Brasileira de Editoras de Músicas - UBEM e a Associação Procure Saber – APS foram admitidas como *amici curiae.*

9. Em 17.12.2013, foi convocada audiência pública pelo Ministro Relator, realizada em 17.3.2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Preliminar de conhecimento

10. Em sua manifestação, a Advocacia-Geral da União apontou preliminar de não conhecimento da ação por ausência de impugnação de todo o complexo normativo.

Da leitura da extensa petição inicial é possível extrair os argumentos das Autoras que justificariam a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas.

11. Conheço, pois, da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Mérito

12. As normas impugnadas estabelecem:

> *"Art. 2º Os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> *'Art. 5º .....*
>
> *XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão." (NR)*
>
> *'Art. 68. .....*
>
> *§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede.*
>
> *.....*
>
> *§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior.' (NR)*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

'Art. 97. .....

§ 1º As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função social.

§ 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza.

§ 3º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de origem.

§ 4º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.

§ 5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo.

§ 6ºo Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo." (NR)

'Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.

§ 2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma.

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.

§ 5º As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual.

§ 6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras.

§ 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindose ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações.

§ 8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento.

§ 9º As associações deverão disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de direitos, dos valores arrecadados e distribuídos.

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo ser distribuídos à medida da sua identificação.

§ 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim.

§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.

§ 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

de 3 (três) anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição.

§ 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros.

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e no § 3o deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da sua prática.

§ 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% (vinte por cento) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva." (NR)

'Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra.

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário.

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação desta Lei, ela não seja

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores arrecadados.

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis.

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos.

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram.

§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 98." (NR)

'Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, 1 (uma) vez por ano, às suas expensas, após notificação, com 8 (oito) dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa associação autoral a seus representados.' (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.610, de 1998, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A:

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará:

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição;

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações:

a) cadastros das obras e titulares que representam;

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios, quando aplicável;

c) estatutos e respectivas alterações;

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias;

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes;

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável;

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável;

h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável;

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de 1 (um) ano e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos do art. 100;

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica dos associados;

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados;

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte.

§ 1º Os documentos e informações a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura.

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e por seu regulamento e não precisará ser renovada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei, assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público.

§ 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se concederá prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente.

§ 4º A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora.

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente, ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as informações previstos nos incisos II e III deste artigo."

"Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão:

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

próprios, às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;

II - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua retenção;

III - buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos;

IV - oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço dos seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica;

V - aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição;

VI - garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade;

VII - garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas.

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser atualizadas periodicamente, em intervalo nunca superior a 6 (seis) meses."

"Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados.

§ 1º O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado.

§ 2º Se as contas não forem prestadas na forma do § 1º, o pedido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

do associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na forma do regulamento."

"Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput do art. 99 deverá admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública Federal na forma do art. 98-A.

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador."

"Art. 99-B. As associações referidas neste Título estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em legislação específica que trate da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica."

"Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais respondem solidariamente, com seus bens particulares, por desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os associados, por dolo ou culpa."

"Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível."

"Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no § 6º do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos termos do regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos.

Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

referidas neste Título."

13. O que se põe em foco na presente ação direta de inconstitucionalidade é se a Lei n. 12.853/20013, ao *"altera[r] os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais"* contraria os arts. 1º, 5º, caput, incs. X, XVII a XX, XXII e XXVII a XXIX, 60, § 4º, inc. III, e 170 da Constituição da República.

14. Para os Autores as normas impugnadas importaram em contrariedade à separação dos Poderes, à livre iniciativa, à isonomia, ao direito de propriedade, à liberdade de associação, ao direito à intimidade, à proteção à propriedade imaterial e os segredos de negócio, aos princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da consensualidade previstos na Constituição da República.

15. Inicialmente cumpre afastar a premissa jurídica da qual parte as Autoras que em 86 laudas afirmam a impossibilidade de atuação do Estado em matéria que lhes parece típica da seara privada. Ao contrário do que defendem, as atividades promovidas pelo ECAD em matéria de aproveitamento econômico dos direitos autorais não têm natureza privada.

16. A discussão sobre a possibilidade do Estado regular e instituir a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autoriais pelo ECAD não é nova neste Supremo Tribunal Federal.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.054/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou:

"EMENTA: I. Liberdade de associação. 1. Liberdade negativa de associação: sua existência, nos textos constitucionais anteriores, como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance e inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei. 2. Direitos autorais e conexos: sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD (L 9610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5º, XVII e XX, da Constituição, cuja aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de conciliar-se com o disposto no art. 5º, XXVIII, b, da própria Lei Fundamental. 3. Liberdade de associação: garantia constitucional de duvidosa extensão às pessoas jurídicas. II. Ação direta de inconstitucionalidade: não a inviabiliza que à lei anterior, pré-constitucional, se pudesse atribuir a mesma incompatibilidade com a Constituição, se a lei nova, parcialmente questionada, expressamente a revogou por dispositivo não impugnado. III. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação de partido político não afetada pela perda superveniente de sua representação parlamentar, quando já iniciado o julgamento" (DJ 17.10.2003).

Consta do voto do Ministro Sepúlveda Pertence:

"Leio das informações, nesse ponto incontestáveis como a unificação do processo arrecadador e distribuidor pelo ECAD é de suma importância para manutenção do sistema de gestão coletiva dos direitos autorais:

"A idéia de Gestão Coletiva de direitos autorais data da França do Século XVIII, mas se iniciou no Brasil em XVII, com o surgimento da sociedade brasileira de autores teatrais – SBAT – criada para promover, com exclusividade, a administração dos direitos autorais dos autores teatrais, relativos à apresentação de obras dramáticas e de caráter assemelhado.

Entretanto, com relação aos direitos autorais decorrentes da execução públicas de obras musicais, o processo de unificação foi mais complexo em virtude da existência de várias associações de titulares, fato que dificultava um consenso e promovia inúmeros problemas e descontentamentos. Assim, com a arrecadação descentralizada, surgiram graves problemas no controle da concessão de autorizações,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

para que fossem utilizadas em público, obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, posto que com a pluralidade de associações arrecadadoras, cada uma defendia os interesses de seus associados, dificultando o controle dos valores arrecadados, permitindo que diversos usuários fossem cobrados, duas ou mais vezes, em face de uma única utilização das obras administradas.

Objetivando melhorar e unificar o sistema de arrecadação, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais — SBAT, a União Brasileira de Compositores —, UBC, a sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil — SADEMBRA e a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música — SBACEM se lançaram na formação de uma única instituição arrecadadora, controlada por elas, dessa idéia surgiu o Serviço de Defesa do Direito Autoral — SDDA, dessa associação de fato, não participaram todas as sociedades, fator que contribuiu para a continuação e aumento dos problemas de arrecadação dos valores devidos pois uma obra musical quase sempre era, de autoria ou titularidade de autores filiados à qualquer das entidades existentes e todas elas poderiam cobrar daqueles que utilizassem publicamente essas obras intelectuais.

Com a regulamentação dos direitos conexos em 1967, surgiu mais uma entidade, a Sociedade de Intérpretes e Produtores de Fonogramas — SOCINPRO, para atuar na cobrança de direitos conexos e as dificuldades não terminavam.

Diante desses fatos, diversos usuários, sejam eles estabelecimentos comerciais, promotores de eventos musicais, emissoras de radiodifusão, eram cobrados por todas as associações de titulares de Direitos Autorais e, por enfrentar a Dúvida de a qual instituição pagar, preferiam continuar a utilizar as referidas obras intelectuais sem efetuar qualquer pagamento, visto que o pagamento a qualquer uma não implicava em quitação e permitia a cobrança por outra associação pelo simples motivo de uma obra musical possuir vários detentores de direito cada qual filiado a uma das referidas entidades.

O problema somente foi sanado, com a edição da Lei nº 5.988/73, que em seu art. 115, determinou às associações de titulares que criassem o ECAD para promover, com exclusividade, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

arrecadação daqueles direitos. O ECAD é até hoje o único escritório com legitimidade para conceder autorização pública de obras musicais, exigindo o respectivo pagamento dos direitos autorais, e dando quitação dos valores efetivamente recebidos.

Parece-nos pertinente invocar as sábias palavras de Nehemias Gueiros Jr., que fazendo uma avaliação histórica da necessidade da Gestão Coletiva, explica:

"O sistema de arrecadação de direitos autorais de execução pública de obras lítero-musicais no Brasil é fundamentado pelo conceito de gestão coletiva, já que o ECAD foi criado justamente para dirimir o caos em que se encontrava a situação na década de 60, com mais de 10 (dez) associações arrecadando e recolhendo, confundindo o entendimento dos usuários de música. A gestão coletiva, hoje praticada e prevista na maioria das leis autorais dos países do mundo, é um elemento agregador e organizador do mercado de execução pública e confere mais credibilidade à distribuição dos direitos, (...). Sua existência só se materializou em função da balbúrdia em que se encontrava o sistema em nosso país, como mais de 10 sociedades disputando a confusão reinante entre usuários, que acabavam por deixar de pagar. (in, Direito Autoral no Show Business, Ed. Gryphus. Volume I — A música, 1999, pág. 437/438) (grifo nosso)

A coordenação de Direito autoral entende sensata a unificação do processo de arrecadação e distribuição de direitos autorais decorrentes da execução pública musical. Esta foi uma conquista dos autores nacionais quando da edição da Lei nº 5.988/73 e que deveria ser mantida, evitando um possível caos, caso prevalecesse o entendimento de uma pluralidade de sociedades arrecadadoras em todo o país, o que poderia confundir o usuário pelo fato de que sobre a obra musical concorre uma pluralidade de titulares de direitos que nem sempre estão na mesma associação autoral.

Faz-se necessário estabelecer, ademais, que a gestão coletiva de direitos autorais realizada em nosso país por 10 associações é ímpar, ou seja, inexiste em qualquer país do mundo número tão expressivo de associações sendo a regra a existência de apenas uma associação em cada país.

A gestão coletiva de direitos centralizada é tendência mundial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

que vem em benefício do próprio titular de direito, ainda mais agora, em face das mútiplas formas de reprodução, armazenamento, distribuição e comunicação ao público por meio das redes eletrônicas (via Internet), tornando completamente inviável que o titular de direito acompanhe o curso que seguirão suas obras, por todos os continentes interligados digitalmente, senão mediante sua associação."

Já se observou, com os artigos 97, caput, e 98, § 1º, que a LDA, com relação aos próprios titulares de direitos autorais e conexos, nem lhes impõe associar-se nem os priva de sua faculdade de defesa individual, judicial ou extrajudicial, dos próprios direitos.

A liberdade de associação ferida seria, pois, não a dos titulares dos direitos autorais, mas, sim, as de suas associações.

Afora a dúvida posta, conforme a lição de Pontes de Miranda, sobre se as garantias constitucionais da liberdade de associação se estendem às pessoas creio que se fazem necessárias algumas outras considerações, a partir da leitura de todo o capítulo da Lei: (...)

Não vejo, neste caso, sequer com relação às associações, uma regra de associação compulsória.

O memorial desenvolve com felicidade a tese da assimilação do ECAD aos grupos de direito público: seria ele uma associação para desempenhar um serviço público por expressa delegação da lei, similar, por exemplo, ao caso das autarquias coorporativas, a partir da Ordem dos Advogados.

Invoca-se Diogo Figueiredo Moreira Neto – Mutações do Direito Administrativo -, para quem é indiscutível que os entes públicos possam criar pessoas jurídicas de direito privado para fins de interesse público, recordando, então, o chamado SISTEMA S, nos moldes do SESI e do SENAI.

O ECAD seria, então, um prestador de serviço público por delegação legislativa.

O raciocínio é altamente ponderável. Assim, na Constituição da República Portuguesa, art. 267, III, prevêem-se as associações públicas, como forma de participação dos interessados na gestão e na administração de serviços públicos.

Mas não assumo compromissos definitivos com essa visão, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

não é necessária à conclusão da constitucionalidade da lei questionada.

Não vejo de logo no ECAD – repito – um tipo de associação compulsória, que se possa assimilar, por exemplo, à Ordem dos Advogados do Brasil. Quem não se inscreve na OAB, advogado não é, para todos os fins legais. Não é o que sucede com as associações de titulares, que não se filiem ao ECAD.

(...)

De tudo, Sr. Presidente, com todas as vênias do eminente Ministro-Relator, julgo improcedente a ação direta e declaro a constitucionalidade do art. 99 e § 1º, da Lei nº 9.610/98: é o meu voto".

17. Sobre o ponto, a Procuradoria-Geral da República asseverou:

"33. Toda a argumentação funda-se na premissa equivocada de que as atividades exercidas pelas entidades de gestão coletiva de direitos autorais possuiriam natureza estritamente privada. Essa concepção não se sustenta. Tais atividades não se classificam como tipicamente associativas, porquanto essas entidades, além de administrar recursos de terceiros, com natureza alimentar, exercem a relevante função social de concretizar outros valores constitucionalmente protegidos que transcendem os interesses meramente privados dos envolvidos, tais como a justa remuneração dos autores, a liberdade de expressão artística, intelectual e de comunicação e a valorização e a difusão das manifestações culturais (objeto dos arts. 5º, IX e XXVII, e 215 da Constituição da República).

34. Ao tratar precisamente de uma das entidades ligadas ao sistema de gestão de direitos autorais, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e assentou que as "associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relação de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal".

35. Por isso mesmo, a própria existência do Ecad não deriva da reunião tradicional de pessoas que deliberaram criar ente para a defesa de seus interesses. O Escritório foi criado pelo art. 115 da Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (a anterior Lei do Direito Autoral, revogada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *pela Lei 9.610/98), justamente por causa do interesse público subjacente à sua atividade. O que fez a Lei 12.853/2013 foi reforçar a relação estatal com esse ente verdadeiramente semipúblico, a fim de aperfeiçoar sistema que se revelou profundamente inadequado ao longo do tempo. (...)*
>
> *37. Portanto, o § 1º do art. 97 da lei apenas reconhece o relevante interesse público inerente ao sistema de gestão coletiva de direitos autorais"*.

18. O ECAD consiste, portanto, em uma associação de associações que arregimenta não apenas interesses particulares imediatos, mas, mediatamente, interesse público afeto ao patrimônio cultural brasileiro, em função do qual (e com maior relevo) sujeita-se à dinâmica dos princípios republicano e democrático.

19. É que, como anunciado pela Advocacia-Geral da União, *"as informações das associações de gestão coletiva, que administram direitos de terceiros e cobram de todos aqueles que utilizam obras musicais e fonogramas, atrelam-se aos direitos difusos (dos usuários) e coletivos (dos titulares), razão pela qual, conforme demonstrado, constituem interesse público"*.

20. Ante inúmeras denúncias de que, na prática, a gestão promovida pelo ECAD ao longo dos anos estava se distanciando de seus propósitos originários foram deflagradas operações que culminaram, como noticiado nos autos, na instauração de pelo menos cinco de comissões parlamentares de inquérito, conhecidas como CPIs do ECAD. Como lembrado Procuradoria-Geral da República:

> *"A última delas, constituída no Senado Federal e concluída em 2012, traçou eloquente quadro dessas distorções. A Procuradoria-Geral da República pede vênia para fazer transcrição excepcionalmente longa de parte das conclusões da CPI do Senado, por entender que examinar ao menos esse trecho de seu relatório final importa para a adequada compreensão das normas jurídicas atacadas, não só em face da Constituição da República, mas também do sistema,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

da prática e da história da gestão coletiva de direitos autorais no país. Veja-se:

Parte IV - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao longo de um ano de trabalho e depois de reunir milhares de páginas de documentos e depoimentos de titulares de direitos autorais, de usuários e de autoridades públicas, a Comissão formou a robusta convicção de que o surgimento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais - Ecad, em 1973, representou uma grande conquista dos autores brasileiros. Mas, em seus 40 anos de existência, o Ecad se degenerou. De órgão meramente executivo de arrecadação e distribuição, tornou-se uma instituição poderosa, que está a desafiar alguns princípios elementares do Estado Democrático de Direito. De instituição, que deveria ser um meio pelo qual os titulares de direitos autorais perceberiam o que lhe é devido, o Ecad tornou-se um fim em si mesmo. Voltado para seu próprio umbigo - e para os interesses de seus controladores e dirigentes - o Ecad transmudou-se em cartel, pernicioso para a ordem econômica brasileira, e muito distante do que reivindica a classe artística, protagonizando toda sorte de desvios e ilícitos.

Formado por nove associações, sendo sete associações efetivas (UBC, ABRAMUS, AMAR, ASSIM, SBACEM, SICAM, e SOCINPRO) e duas associações administrada[s] (ABRAC e SADEMBRA), o Ecad arrecadou R$ 540,5 milhões e[m] 2011. Esses recursos são recebidos não em seu próprio nome, mas em nome dos associados das sociedades que compõem o ECAD (artistas, compositores e demais titulares de direitos autorais). O ECAD e as associações, como depositárias destes recursos, possuem deveres fiduciários tanto com relação ao grupo difuso que a elas contribui, quanto com o grupo difuso que dela devem receber. Dessa relação fiduciária emerge a necessidade de regulação do sistema de gestão coletiva. Esta é principal conclusão desta CPI.

É de registrar que, ao longo de sua história, o ECAD foi alvo de outras quatro CPIs: uma da Câmara dos Deputados (1995/96), e três das Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (2005), São Paulo (2009) e Rio de Janeiro (2011). Todas apontaram graves irregularidades. O Relatório Final da CPI da Câmara dos Deputados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

aponta a ocorrência dos crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, formação de cartel e abuso do poder econômico. A lista de indiciados foi encabeçada por José Antônio Perdomo. O Sr. Perdomo continua atuando no sistema, mas agora como superintendente da UBC. Três meses antes da eleição que levou o músico Fernando Brant à presidência da entidade, o Sr. Perdomo efetuou uma mudança em seus estatutos, transferindo para a superintendência as principais funções exercidas antes pela presidência, inclusive o departamento financeiro e a representação judicial e extrajudicial da entidade.

A conclusão da CPI do Mato Grosso do Sul é que o ECAD "faz o que bem entende, cobra o que quer, di[s]tribui o que tem vontade, impõe condições ao seu bel prazer, estabelece critérios incompreensíveis e age com uma volúpia arrecadadora, motivando os reclamos da população e dos detentores de direitos autorais" O me[s]mo relatório concluiu também que "torna-se imprescindível que a Lei nº 9.610/98 seja urgentemente revista pelo congresso nacional" A CPI realizada em São Paulo pela ALESP também aponta para a necessidade de "formular as alterações que se fazem imperativas, de forma a criar um ambiente de segurança e clareza tais, que permitam aos músicos exercitarem o seu mister, sem que sejam obrigados a desperdiçar seus talentos na busca da Justiça, ou calar-se, perante as ameaças e o poderio econômico dos que se encastelaram em estruturas ineficazes e corruptas."

[...]

À guisa de diagnóstico sobre o Ecad, foi emblemático o depoimento do maestro Tim Rescala a esta CPI, na audiência pública realizada no Rio de Janeiro em 30/09/2011, Ele assevera que:

O ECAD foi criado por lei e exerce um monopólio concedido pelo estado, ou seja, o estado esteve presente na questão desde a criação do órgão. E a sua ausência como instância reguladora e fiscalizadora, a partir do governo Collor, aprofundou as distorções e injustiças que já existiam no sistema.

O que vemos hoje é uma gestão que beneficia poucos em detrimento de muitos. Não há dialogo com os compositores e aquele que levanta a voz para fazer criticas é considerado inimigo. Como no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

meu caso, há situações bizarras, onde o órgão, que existe para defender o interesse dos autores, usa o dinheiro dos próprios autores para processá-los criminalmente.

O maestro faz o seguinte questionamento: "afinal, o que é o ECAD? Ou melhor, quem está por trás do ECAD?" Em seguida, responde:

Das 9 sociedades que o compõe[m] atualmente, apenas seis têm direito a voto nas assembleias. Dentre essas 6, duas são responsáveis, sozinhas, por 80% da arrecadação: UBC e ABRAMUS.

Na arrecadação de 2010, por exemplo, num total de 315 milhões distribuídos, 240 foram para as duas entidades, 120 milhões para cada uma. E por quê? Por quê elas têm mais autores? Por que seus repertórios são mais representativos?

Não. Porque nelas estão as editoras multinacionais. Na UBC, cuja metade do repertório é de musica estrangeira, estão a EMI e a Sony, Na ABRAMUS estão a Universal/BMG e a Warner.

O ECAD divulga regularmente um ranking dos maiores arreca[da]dores, mas só inclui autores, como se estes fossem verdadeiramente os que mais arrecadam. Não são. Em 2010, por exemplo, a maior arrecadação foi da Warner, seguida por Universal, EMI e Sony. O primeiro autor só aparece na sexta posição do ranking.

Por que o ECAD não divulga isso? Para não tornar público o que para nós está mais do que claro. O interesse dessas editoras multinacionais é o que prevalece.

No histórico depoimento, Tim Rescala desnudou a força das editoras, especialmente as multinacionais, no sistema de gestão coletiva de direitos autorais brasileiro:

Desde 1989, a União Brasileira de Compositores é presidida, indiretamente, por uma multinacional. De janeiro de 1989 a dezembro de 1994, a presidência foi exercida pela EMI MUSIC LTDA. - DIVISÃO ITAIPU, representada por um contador. De janeiro de 1995 a março de 2002, pela EDIÇÕES MUSICAIS TAPAJÓS LTDA., também editora do grupo EMI, representada pelo mesmo contador. De abril de 2002 a 2006, pela EMI SONGS DO BRASIL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, representada também pelo mesmo contador. Em 2006 a presidência passou a ser exercida pelo compositor Fernando

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Brant, aqui presente. Porém, o contador passou a ser o superintendente, mas sempre representando alguma editora do grupo EMI.

De 2006 a 2010, a superintendência foi exercida pela EMI SONGS DO BRASIL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, representada novamente pelo mesmo contador. E, finalmente, de abril de 2010 a março de 2014, pela EDIÇÕES MUSICAIS TAPAJÓS LTDA., como sempre, representada por este mesmo contador.

Isso é o que se passa na UBC, mas na ABRAMUS, que duela, literalmente, com a UBC pelo poder na assembleia, não é muito diferente. Basta dizer que o presidente da entidade, que não é contador, mas advogado, é o mesmo há 29 anos, desde sua fundação. Na diretoria estão representantes da Associação Brasileira de Produtores de Discos, da Editora Universal, da Sony e da Warner Chapell. Que interesses vão prevalecer?

O contador referido pelo maestro é José Antônio Perdomo Corrêa, o homem mais poderoso da UBC. Na Abramus, o controle é exercido pelo advogado Roberto Corrêa Mello. Essas duas eminências pardas do sistema brasileiro de gestão coletiva são os reais controladores das decisões do Ecad. Qualquer mudança eficaz no sistema passa pela elaboração de um arranjo institucional que diminua a força do poder econômico das editoras, e de pessoas como Perdomo e Mello, nas decisões do ECAD.

O maestro Tim Rescala prossegue seu depoimento demonstrando a ineficiência do Ecad na distribuição justa dos direitos autorais:

O ECAD declara que possui 542 mil autores cadastrados e que em 2010 distribuiu 346,5 milhões para 88 mil autores, ou seja, 254 mil autores não receberam nada. Segundo o ECAD, simplesmente porque a música desses autores não tocou em lugar nenhum. Será que foi por isso mesmo?

Observando o regulamento de distribuição, que apresenta alguns critérios absurdos, começamos a vislumbrar uma razão para que tanta gente não receba nada. Um músico da noite que toca suas próprias composições nunca consegue receber seus direitos autorais. Isso porque o ECAD se baseia na realidade de outro segmento para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

pagar a este, considerando a proporção de 95% do que toca em rádio e 5% do que toca na TV da rubrica Direitos Gerais, como se isso pudesse se aplicar a tudo. Obviamente, a música que toca na noite não é necessariamente a que toca no rádio e muito menos a que toca na TV. O que se quer então com essa lógica? Beneficiar sempre os mesmos compositores e, sobretudo, os mesmos editores.

A música mecânica ou ambiente, segunda maior parcela na arrecadação do ECAD, aquela tocada em bares, restaurantes, academias de ginástica, consultórios médicos, assim como a música ao vivo, é apurada por amostragem. Por qual razão? Qual é a dificuldade de se obter do usuário uma lista do que foi tocado? Este é um segmento que pode muito bem fornecer dados precisos. Mas o que faz o ECAD? Usa a amostragem, baseando-se novamente nos tais 95% do que toca na rádio e 5% do que toca na TV para fazer a distribuição. Quem se ben[e]ficia com isso mais uma vez? Os mesmos compositores e editores. E os outros, que efetivamente foram tocados? São simplesmente ignorados.

A constatação apresentada nesse depoimento foi corroborada por vários outros depoimentos e documentos colhidos por esta CPI. Com os avanços existentes nas tecno[lo]gias de informação e comunicação, é difícil acreditar que a distribuição dos direitos autorais no Brasil deva continuar valendo-se praticamente apenas do recurso da amostragem. Ainda que seja necessária, dada a complexidade e extensão do Brasil, a amostragem não pode ser eternizada como a fonte principal da informação. [...]

Por se tratar a gestão coletiva de monopólio legal, o Estado brasileiro tem o poder-dever de regular a atividade de fixação de preço, arrecadação e distribuição de direitos autorais. Essa é uma atividade precípua do Poder Legislativo, como depositário direto da soberania popular. A regulação desse monopólio legal deve visar abrir a caixa preta do Ecad e assegurar transparência nos métodos da entidade.

Todos sabemos que a transparência tornou-se a "força motriz" das mudanças que estão a moldar o mundo contemporâneo. Regra geral, em qualquer órgão publico ou privado, a falta de transparência degenera para a corrupção ou para o totalitarismo, além de gerar desconfiança de tudo em todos. As instituições que lidam com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

interesse público não podem se ocultar. O ECAD, todavia, tornou-se uma entidade alheia à transparência de suas ações e ao controle social de seus associados. Recentemente a entidade diminuiu a opacidade absoluta de informações que constavam de seu site. Mas estes pequenos reparos, extraídos pela crescente indignação da sociedade brasileira, estão a quilômetros de representar o que deseja [m] os titulares e usuários de direitos autorais no Brasil.

Todas as denúncias contra o Ecad apuradas por esta CPI apontam para uma direção única: é preciso promover uma profunda reforma no sistema de gestão coletiva de direitos autorais. Somente a mudança estrutural do sistema pro[pi]ciará a superação de fraudes, como a ocorrida no caso Milton Coitinho, tratada no item 1 da parte III. Em geral, essas fraudes causam grandes prejuízos aos autores.

É preciso democratizar o Ecad e submetê-lo à lei e, sobretudo, à Constituição. Há traços de autoritarismo nas práticas do órgão que não podem mais ser toleradas.

[...]

Dirigir o ECAD se tornou um negócio rentoso. A entidade criou três modalidades de Plano de Participação nos Resultados (PPR), as quais beneficiam sobretudo os gerentes. O ECAD é uma associação civil que, em tese, não deveria dar lucros (nem, por óbvio distribui-los a seus diretores). O uso abusivo dos PPRs drenam, especialmente para a gerência, recursos que deveriam ser destinados aos titulares de direitos autorais. Até em ano em que o ECAD apresenta déficit financeiro há distribuição de PPR. Aliás, ao converter os créditos retidos em receita corrente para cobrir o déficit financeiro no exercido de 2004, os representantes das associações que votaram a favor dessa decisão, e outros que a ratificaram, incorreram em conduta que aponta para crime de apropriação indébita.

É preciso desmontar o cartel Ecad. O Ecad exerce monopólio legal apenas para arrecadação e distribuição de direitos autorais; a lei não lhe conferiu o monopólio da fixação de preço no campo dos direitos autorais de música. Aplica-se, portanto, a Constituição da República, que assegura a livre iniciativa. Os preços a serem pagos pela fruição da produção artística devem ser fixados pelos titulares de direitos autorais e sua associações, individualmente, em regime de plena

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

liberdade.

Por essa razão, esta CPI ratifica o entendimento da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça que concluiu ter o ECAD e suas associações devem submete [r] -se a legislação que coíbe infração à ordem econômica. Mais que isso, que a concertação de preços que vem sendo praticada por elas representa cartel, para todos os efeitos legais.

É incompreensível que todas as sociedades que compõem o ECAD fixem o mesmo valor a título de taxa administrativa (7,5%). Ora, cada sociedade possui administração, sede, pessoal, história e estrutura de custos distintos. Não faz sentido, nem tem guarida na lei, o fato de que todas adotem uniformemente o mesmo percentual. É preciso abrir mais esta caixa-preta e desnudar a curiosa composição destes preços.

A falta de concorrência, sobretudo quando aliada a outros desmandos, pode gerar estruturas ultrapassadas. O Ecad e suas associações se tornaram uma imensa burocracia, ineficiente e cara. Sugam 25% de tudo o que é arrecadado a titulo de direitos autorais. Há anos o ECAD comemora recordes de arrecadação, mas nem por isso reduz sua taxa de administração, atualmente em 17%. Somada às das sociedades (7,5%), representa uma das mais altas taxas do mundo. Quem paga direito autoral acha que paga muito. Mas quem recebe acha que recebe pouco.

Aliás, registre-se, não deixa de ser muito respresentativo que o ECAD volta e meia jacte-se de ser eleito "uma das melhores empresas para se trabalhar" - quando, repise-se sempre, trata-se de associação, e uma que existe apenas para arrecadar e distribuir dinheiro que pertence a terceiros - enquanto a imensa maioria dos compositores brasileiros recebe parcos reais de suas associações, quando recebe alguma coisa. Privilégio de poucos, malgrado os imensos valores que circulam pelo sistema ECAD.

Além da degeneração na atuação do ECAD, há problemas também que derivam do próprio desenho legal previsto em 1973 - como seria de se esperar em norma tão vetusta. Na área do audiovisual, por exemplo, que responde em média por 25% de tudo o que o ECAD arrecada, apenas os músicos são beneficiados, pois a lei

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *vigente deixa de fora os co-autores das obras: diretores, roteiristas, atores e dubladores, que nunca receberam nada. Por isso é tão importante que a Presidenta da República encaminhe, com urgência constitucional, o anteprojeto de Lei de Direitos Autorais em tramitação na Casa Civil, que busca atualizar tais questões, face à timidez das mudanças promovidas em 1998 pelo legislador.*
>
> *Dos usuários de audiovisual, o ECAD cobra 2,5% de seus faturamentos brutos, só para pagar música, enquanto que em países como França e Espanha cobra-se 2% do faturamento líquido, e ainda beneficiando todos os segmentos. O que justifica essa discrepância?"*

A resposta a essa pergunta parece óbvia: o interesse de gestores que, pouco atentos aos princípios constitucionais orientadores da interpretação de todos os direitos e deveres nela contidos, pretendem na presente ação direta de inconstitucionalidade sejam restabelecidas regras autorizadoras de práticas pouco republicanas.

21. Atento à circunstância de que a *"temática versada nestas ações* [ADI n. 5.062 e ADI n. 5.065] *reclama apreciação que ultrapassa os limites do estritamente jurídico, porquanto demanda abordagem técnica e interdisciplinar da matéria"* o Ministro Luiz Fux convocou audiência pública, realizada em 17.3.2014, da qual se extrai, por exemplo, importantes argumentos:

> *"O SENHOR HUMBERTO COSTA (SENADO FEDERAL) - (…) Conclusões de que havia pessoas que não detinham os direitos autorais e que, em algum momento, foram indevidamente beneficiadas; associações que foram excluídas da participação, dentro do ECAD, segundo a CPI, de forma arbitrária; a criação de prêmios e participações a gerentes e dirigentes do ECAD, na visão da CPI, contra a lei; e ilegalidade na utilização de créditos retidos. (…) E, aí, eu quero chamar a atenção a um dos pontos que foi muito questionado: "Não, mas você tá se intrometendo no campo da liberdade de organização e de associação". E, aí, eu respondia: "Não, nós não estamos interferindo nisso, os autores, os músicos, os compositores podem instituir quantas sociedades quiserem para os mais diversos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

fins. No entanto, com relação a essa atividade específica, que é de arrecadar e distribuir tudo aquilo que foi objeto de execução e transmitir isso aos seus reais detentores de direito, é algo necessário e fundamental". São duas coisas absolutamente diferentes. Como também era importante garantir ao usuário, que está na outra ponta, a cobrança de um preço justo pela execução daquelas músicas, daqueles fonogramas. E havia uma queixa geral de que isso não acontecia efetivamente.

Além disso, assim como é o sentimento da sociedade, hoje, no meu parecer, eu procurei primar por um sistema que tivesse publicidade e transparência para que os autores pudessem saber onde a sua música toca, quantas vezes ela tocou, se foi pago o direito por parte do usuário e, principalmente, se aquele recurso chegou até a sua conta. Então, um sistema de controle por internet, que é possível. Também da democratização, para que nós tivéssemos peso igual para o voto das associações, e também restringir o voto aos titulares originários de direitos autorais, sem a participação de editoras, por exemplo, que tinham um direito de voto até maior do que alguns dos integrantes das direções.

(…)

O SENHOR FERNANDO BRANT (UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES) - (…) O modelo de gestão brasileira, que repete, em linhas gerais, o modelo de gestão coletiva europeia, em comunhão com as melhores práticas internacionais, funciona a partir de soluções de arrecadação e distribuição de direitos sofisticadas, com ferramentas tecnológicas criadas pelas associações ao longo dos anos.

(...)

O SENHOR RANDOLFE RODRIGUES (SENADOR DA REPÚBLICA) (…) o verdadeiro objetivo que é desqualificar a Lei nº 12.853, que é, na verdade, a democratização da gestão coletiva do direito autoral no Brasil. (…) É por conta disso que se estabeleceu uma sociedade de sociedades fechada à entrada de novas instituições. Um sistema fechado e, por assim dizer, é aqui que destacamos que não se trata, Senhor Ministro, de arguir aqui o artigo 5º do direito individual. Nós estamos aqui tratando de uma sociedade que se fechou para outras sociedades que queiram participar do sistema de gestão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

coletiva de direito autoral no Brasil e, portanto, criou um sistema ditatorial.

O que nós estabelecemos no projeto de lei e, depois, na Lei nº 12.853, é um sistema a partir do Estado brasileiro, e isso não é novidade no sistema de Direito no Brasil. Ora, é assim que ocorre no Brasil quando nós temos regimes, quando nós temos a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula o funcionamento de entidades privadas que fazem operação de voos no Brasil. É assim que ocorre no Brasil quando nós temos uma entidade do Estado que regula o sistema dos planos de saúde no Brasil. O Estado não está interferindo, mas está regulando o papel de entidades de direito privado. O que nós estamos fazendo, quando estabelecemos o papel do Ministério da Cultura para homologar a participação de entidades, é não dar a uma entidade a prerrogativa autoritária de, ao seu bel prazer, dizer quais entidades têm que participar do seu regime societário. (…) a CPI também diagnosticou a formação de cartel que, com certeza, daqui a pouco, o representante do CADE irá apresentar as informações aqui.

Por isso a CPI apresentou as sugestões que resultam na Lei nº 12.853, as sugestões de tempo de mandato, taxa de arrecadação, princípios de transparência, eficiência, modernização, regulação e fiscalização.

(…)

O SENHOR ROBERTO FREJAT (CANTOR, COMPOSITOR, INTEGRANTE DO GRPO DE AÇÃO PARLAMENTAR PRÓ-MÚSICA - GAP) - (…) O ECAD tornou-se um monstro feroz, julgando-se imune aos tribunais, já que, com a extinção do CNDA, ele se tornou a instância oficial de representação dos autores.

Iniciou-se, nesse período, um processo de ocupação da entidade, feito pelas grandes editoras e gravadoras, quase todas ligadas a grupos multinacionais, e o foco da arrecadação foi mudando.

Passou a existir uma dificuldade enorme de se ter acesso às atas de assembleia das sociedades e do ECAD. Por exemplo, a última ata de assembleia geral do ECAD, que está presente no site dele, é de julho do ano passado. As assembleias são mensais e só a de julho é a última.

Eu sou autor há trinta anos. Nunca recebi um convite para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

votação de alguma assembleia ou de alguma eleição de diretoria. Trinta anos! Nunca recebi um convite.

O ECAD se vangloria de uma estrutura técnica de excelência. A aferição por amostragem de rádio, nos dias de hoje, eu considero patética, tendo em vista o acesso que temos à tecnologia digitais de ponta pelo mudo inteiro. Qualquer rádio no Brasil - se a gente tiver uma rádio, hoje, no meio de uma reserva indígena -, ela tem um computador que pode enviar uma planilha, num programa qualquer de computador, e essa planilha vai ser recebida pelo ECAD e, só a partir de uma suspeita de fraude de declaração, aí, sim, o processo de amostragem deve funcionar. Mas o processo de amostragem é feito porque ele se limita a poucas rádios e você consegue concentrar nos maiores arrecadadores, e, aí, ficamos num círculo vicioso, onde só os maiores recebem e isso fica ali preso, dentro de si próprio.

Mudanças bruscas são feitas nas pontuações de pagamento dos direitos autorais, como foi feito com o caso dos compositores de trilhas sonoras, onde, de uma hora para outra, o ponto deles de aferição passou de um para um terço, depois para um sexto e, depois, para um doze avos, isso resolvido tudo dentro de assembleias internas, sem consulta a associados, sem a discussão geral da classe sobre um assunto tão importante.

(…)

O SENHOR PAULO ESTIVALLET DE MESQUITA (DEPARTAMENTO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES) – (…) A participação do Ministério das Relações Exteriores nessa Audiência Pública tem dois objetivos principais: o primeiro é transmitir a nossa avaliação em relação à compatibilidade da nova lei com os compromissos internacionais do Brasil; o segundo é compartilhar a nossa avaliação e a nossa análise das experiências internacionais em matéria de regulamentação pelo Estado dessas entidades de gestão coletiva.

Do nosso ponto de vista, a nova lei é plenamente compatível com os compromissos internacionais do Brasil em matéria de proteção de direito do autor e direitos conexos, principalmente os mais relevantes: aqui são a Convenção de Berna, a Convenção de Roma e o acordo tríplice da OMC. (…) Uum levantamento rápido, mas que é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

facilmente acessível pela Internet, mostra que, por exemplo, em relação ao controle permanente pelas autoridades sobre a atuação das entidades, existe, por exemplo: a nomeação de delegados que participam das assembleias na Áustria, na Bélgica, na Dinamarca, na Alemanha, na Finlândia, na França, na Grécia, na Itália, na Holanda, na Suécia, na Espanha; que a delegação da autoridade - ou seja, a autoridade que supervisiona as entidades de gestão coletiva - pode assistir às assembleias decisórias na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda; que todos os documentos pertinentes sobre a administração, sobre a compatibilidade, sobre as decisões constam da lei na Áustria, na Bélgica, na Alemanha, na Dinamarca, na Finlândia, na França, enfim, na Holanda, na Espanha, na Suécia; que o controle das contas das entidades é feito pelo Tribunal de Contas na Áustria, na Bélgica, na Dinamarca, na França, na Suécia; que a transparência em relação aos membros, o controle de tipo societário, mesmo que se exerça sobre sociedades de direito privado, com relatório anual das contas do Conselho de Administração e aprovação pela Assembleia Geral, existe em praticamente em todos os países da União Europeia. (…) Enfim, um último ponto que eu gostaria de mencionar diz respeito ao direito de associação, à liberdade de associação, né? Nós estamos falando aqui da Europa. E, no caso da França, por exemplo, a Lei de 1901, que estabelece essa liberdade de associação, foi recepcionada pelas Constituições da IV e da V República e é um parâmetro em matéria de liberdade de associação no mundo. Na Alemanha, a Lei Fundamental, que foi promulgada após a difícil experiência do nazismo, também estabelece o pleno direito de associação, excluídas apenas aquelas associações que tem objetivos contrários à legislação penal ou à ordem constitucional. Isso vale, enfim, a todos os países europeus. E, aliás, de resto, esse direito de associação está previsto na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Em nenhum país europeu se argumentou que a supervisão estatal sobre as entidades de gestão coletiva pudesse infringir o direito de associação.

(…)

O SENHOR RONALDO LEMOS (CONSELHO DE COMUNICAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E DIRETOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO) - (…) Como é de se imaginar, o monopólio desregulado leva a uma série de distorções econômicas e jurídicas. Eu vou citar apenas uma: recebemos, no Conselho de Comunicação Social, carta enviada pela Empresa Brasil de Comunicações e por outras entidades representantes das emissoras e rádios educativas do país. Essas entidades estão em disputa com o ECAD. A razão é o critério de preço estabelecido por ele para o uso de direitos autorais. Na palavra dessas associações, os valores que o ECAD insiste em praticar com as emissoras culturais, universitárias e institucionais estão construídos a partir de critérios incorretos, inconsistentes e inaceitáveis - eu estou citando a carta. Notadamente, são baseados em percentual sobre faturamento. Só que, como empresa pública, não se trabalha com conceito de faturamento, já que os recursos são provenientes de orçamentos de universidades públicas ou órgãos públicos. Na ausência de faturamento, o ECAD insiste em traduzir como faturamento a totalidade do orçamento anual de uma universidade pública, federal ou estadual, ou de uma secretaria municipal ou da própria EBC - isso consta da carta.

(…)

A SENHORA PAULA MAFRA LAVIGNE (UNS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E UNS E OUTROS PRODUÇÕES E FILMES) - (…) Ora, só os editores mandavam, só as multinacionais. O senhor acha que o Roberto Carlos é o maior arrecadador, como todo mundo pensa? Não. São as editoras multinacionais. Em todo lugar do mundo, é o autor que manda. Você viu os presidentes de associação? São autores. Aqui, a gente tem um monte de gente falando em nome da gente. E eu ouço que é mentira? Então eu vou ler uma lista de quem, por baixo, por menos, porque muitos autores a gente não teve como procurar, que eu estou representando aqui hoje. Como é que foi falado? Um grupo pequeno, um grupo de manipulados, desinformados, ingênuos. Foi uma desqualificação total de uma coisa que eu concordo com o Menescal, que foi uma coisa bacana de a gente se unir e querer ter representatividade.

Então eu vou ler essa lista desses ingênuos, desavisados, bobos, manipulados: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Holanda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Djavan, Milton Nascimento, Alceu Valença, Alcione, Alexandre Negreiros, Alexandre Pires, Ana Carolina, Ana Terra, Antônio Villeroy, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Carlos Mills, Chico Amaral, Chitãozinho e Xororó, Cláudio Lins, CPM 22, Dé Palmeira, Dudu Falcão, Ed Roque, Edu Lobo, Emicida, Fafá de Belém, Filipe Ret, Fernanda Abreu, Fernando Anitelli, Fernanda Fernandes, Flora Matos, Frejat, Gaby Amarantos, Herbert Vianna, Herbert Azul, Isabella Taviani, Ivan Lins, Ivete Sangalo, Jards Macalé, João Paraíba, Jorge Aragão, Jorge Ben Jor, Jorge Vercillo, Jota Quest, Lenine, Levi Lima, Luciano Queiroga, Lúcio Maia, da Nação Zumbi, Lula Queiroga, Maestro João Carlos Martins, Nuno Brown, Márcio Victor, do Psirico - agora estourou; Maria Gadú, Marisa Monte, Mauro Santa Cecília, Marcus Viana, Nando Reis, Otto, Paulinho Moska, Péricles, Preta Gil, Pretinho da Serrinha, Rita Lee, Roberta Miranda, Rogério Flausino, Ronaldo e os Barcellos, Sandy, Sérgio Ricardo, Seu Jorge, Teresa Cristina, Thiaguinho, Tim Rescala, Titãs, Tuca Fernandes, Vanessa da Mata, Xande de Pilares, Zé Renato e Zezé Di Camargo. E muitos outros, e muitos outros que nos apoiam nas redes sociais, que estão ali falando.

(…)

O SENHOR DENIS BARBOSA (INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL) - (…) É claro que o ECAD é uma entidade privada. É uma entidade privada que tem monopólio público. E deixo a apresentação com as suas fontes para uso posterior, mas o importante é que o fato de haver controle público - já foi demonstrado aqui, inclusive referido pelo Ministério das Relações Exteriores -, é o normal na prática. (…) Os pesquisadores levantaram que o maior usuário de ver gastar para o Judiciário é o ECAD, como está no relatório - e terminando agora - apresentado à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O mais visível infrator das normas de concorrência em relação ao chamado Sham Litigation, que é o abuso do direito de litigar, é o ECAD. E aí vai a listagem apresentada à Organização Mundial da Propriedade Intelectual; por um pequeno período as ações que foram declaradas pela justiça como reiteração abusiva do direito de litigar.

(…)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

O SENHOR JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO (COMPOSITOR, CANTOR E INSTRUMENTISTA) - (…) Eu queria reconhecer que, além do aspecto que está sendo trazido ao Supremo Tribunal Federal, os aspectos enfocados nessa ADIn, existem alguns aspectos nessa lei que evidentemente são um avanço para os autores. São avanços no sentido da transparência e da democratização das sociedades e do ECAD. No entanto, existe um outro lado que precisa ser objetivamente mencionado aqui, e que serve inclusive para um alerta com relação a que tipo de participação do Estado nós queremos ou a que tipo de participação do Estado o Governo quer.

Existem, por exemplo, de dispositivos na Lei 12.853 que representam exatamente os direitos dos usuários. Um exemplo disso é a nova redação do § 4º, art. 98, da Lei 9.610, que diz que a cobrança deve ser proporcional à utilização da obra. Ora, esse mesmo pleito foi feito durante anos pela Rede Globo em sua ação judicial contra o ECAD que, como foi dito aqui, foi encerrada no ano passado com um acordo. O que ocorreu foi que a autora da ação não conseguiu ver reconhecido judicialmente o seu direito a esse tipo de cobrança - proporcional à utilização da obra -, no entanto conseguiu inserir um artigo na lei prevendo essa mesma intenção. Não ganhou na justiça, mas incluiu na lei. Não me recordo de - nos anos em que participei, como representante do Fórum de Música de São Paulo, discutindo sobre eventual alteração da Lei 9.610 - ter havido um debate entre os autores, com relação a essa previsão legal."

22. Em estudo sobre a República e Federação no Brasil ponderei:

"A condição especial e hierarquicamente sobranceira do princípio fundamental republicano (ao lado de outros, que com ele se compõem e se conjugam, como os da Federação e o democrático), no conjunto dos princípios basilares do sistema constitucional, dota a opção constituinte da forma de governo de uma condição de vigor constitucional especial e determinante.

E nessa condição superiormente enfatizada no sistema e determinante no Direito vigente, há que serem buscadas as diretrizes para a aplicação de todas as normas de Direito que vigoram, tanto aquelas postas no texto e extraídas do contexto da Lei Fundamental,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

quanto aquelas que se lhe subordinam juridicamente. Assim, não apenas as normas constitucionais em sua expressão e em sua interpretação parte em voltam-se para os princípios fundamentais do sistema, um dos quais, no Brasil, é o da forma republicana de governo, como, e principalmente, a prática constitucional tem nessa eleição constituinte uma de suas vertentes um dos seus limites e muito do seu conteúdo determinante. (...)

A República é o símbolo jurídico, tornado norma impositiva de um sistema de convivência política segundo o Direito, no qual a coisa do povo é exercida, efetiva, imediata e permanentemente, segundo o seu interesse, não se podendo consagrar, nesse exercício, peculiaridades decorrentes de condição pessoal específica e de privilégios, preferências ou preconceitos.

A República é o brasão jurídico da igualdade no trato e no retrato da coisa pública; o símbolo tornado princípios jurídico-normativo, de cumprimento impositivo e impostergável, da publicização dos negócios de todos os cidadãos, titulares não apenas no poder, mas senhores do seu exercício e do seu destino" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *República e Federação no Brasil*: traços constitucionais da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 72/93).

Segundo as lições de Geraldo Ataliba:

"Como princípio fundamental e básico, informador de todo o nosso sistema jurídico, a ideia de república domina não só a legislação, como o próprio Texto Magno, inteiramente, de modo inexorável, penetrando todos os seus institutos e esparramando seus efeitos sobre os mais modestos escaninhos ou recônditos meandros.

Tal é sua importância no contexto do nosso sistema, tão dominadora sua força, que influi, de modo decisivo, na interpretação dos demais princípios constitucionais e, com mais razão, de todas as regras constitucionais.

A fortiori, todas as leis devem ter a sua exegese conformada às suas exigências, inclusive as leis constitucionais, a começar do próprio Texto Magno.

(…)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Alguns princípios constitucionais foram tradicionalmente postos pelos sucessivos legisladores constituintes como fundamentais a todo o sistema, e, por isso, em posição de eminência relativamente aos outros.

No Brasil os princípios mais importantes são os da federação e da república. Por isso, exercem função capitular da mais transcendental importância, determinando inclusive como se deve interpretar os demais, cuja exegese e aplicação jamais poderão ensejar menoscabo ou detrimento para a força, eficácia e extensão dos primeiros.

Diversas ordens de considerações evidenciam a posição privilegiada em que foram postos esses dois princípios, desde 1891.

Foram lógica e cronologicamente fixados como basilares, pela circunstância de virem mencionados em primeiro lugar (art. 1º) nos textos constitucionais republicanos (…).

Nos textos anteriores preceito de igual conteúdo substancial limitava-se a impedir o processamento de proposta de emenda detrimentosa da república.

A Constituição de 1988 foi mais explícita e arrolou matérias substanciais que são contexto ao princípio republicano (art. 60, § 4º), de modo a não deixar o intérprete, mesmo o mais resistente, dúvida sobre o alcance do princípio e, pois, do preceito que o protege.

São repetidos, enfatizados, reforçados e assegurados, até as últimas consequências, por inúmeras outras disposições constitucionais abundantes de preceitos que lhes explicitam o conteúdo, sentido, alcance, exigências e limites de eficácia. Praticamente toda a parte orgânica da Constituição é seu desdobramento.

(…)

Caracteriza-se modernamente o regime republicano pela tripartição do exercício do poder e pela periodicidade dos mandatos políticos, com consequentes responsabilidades dos mandatários.

Todos os mandamentos constitucionais que estabelecem os complexos e sofisticados sistemas de controle, fiscalização, responsabilização e representatividade, bem como os mecanismos de equilíbrio, harmonia (check and balances...) e demais procedimentos a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

serem observados no relacionamento entre os poderes, asseguram, viabilizam, equacionam, reiteram, reforçam e garantem o princípio republicano, realçando sua função primacial no sistema jurídico. Assim, funciona como alicerce de toda a estrutura constitucional, pedra de toque ou chave da abóbada do sistema.

(…)

Toda lei emanada de quaisquer órgãos constituídos do país há de submeter-se às balizas e limites contidos na Constituição e, sobretudo, tender a realizar (assegurando-lhe a sua eficácia, na maior plenitude possível) os princípios constitucionais, dos quais a federação e a república comparecem em posição singularmente relevante (porque fundamentais e básicos de todo o sistema).

Só legislação que respeite as exigências decorrentes desses princípios poderá ser aceita como legítima e válida. E é na conformidade das exigências dos princípios – mormente os mais conspícuos e básicos – que se há de interpretar essa mesma legislação.

As competências recebidas pelos órgãos legislativos do país hão de ser desenvolvidas não só na conformidade das balizas expressas contidas no texto constitucional, como, ainda, hão de ser todos os preceitos assim emanados realizadores e respeitadores dos princípios constitucionais fundamentais. Entender de outra maneira é reduzir a Constituição a mera tábua de sugestões, simples rol de recomendações. É negar-lhe a vis de Lei Máxima, vigor de Carta Fundamental, eficácia de Suprema Lei do País.

Por isso é que a interpretação da legislação e demais atos do governo haverá de ser sempre desempenhada – pela Administração ou pelo Judiciário – de modo a, exaltando a harmonia do sistema jurídico, valorizar condigna e adequadamente os seus princípios fundamentais, buscando dar-lhes eficácia e fazer com que todos os comportamentos se curvem às suas exigências. Só assim a república será valorizada e exalçada no plano prático, como o foi na elaboração constitucional e nos desígnios constituintes, refletindo com fidelidade o querer do povo, titular da república" (ATALIBA, Geraldo. 3.ed. *República e Constituição.* São Paulo: Malheiros, 2011. p. 33/37-38/43).

23. Do princípio republicano decorrem o princípio da publicidade, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

princípio da transparência, o princípio da eficiência e o dever de prestar contas.

Como pontuado pelo Ministro Roberto Barroso:

> *"a regra geral é a publicidade. Essa é uma decorrência de um conjunto de normas constitucionais, tais como o direito de acesso a informação por parte dos órgãos públicos (art. 5º, XXXIII) – especialmente quanto à documentação governamental (art. 216, § 2º) –, o princípio da publicidade (art. 37, caput e § 3º, II) e o princípio republicano (art. 1º), do qual se originam os deveres de transparência e prestação de contas, bem como a possibilidade de responsabilização ampla por eventuais irregularidades"* (MS 28178, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJ 8.5.2015).

24. A observância da publicidade, transparência, de prestação de contas e de eficiência não se cinge à atuação dos órgãos e dos agentes da Administração Direta e Indireta.

Ingo Wolfgang Sarlet adverte:

> *"É neste contexto que assume relevo a assim denominada (e já analisada) perspectiva (ou dimensão) jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, de acordo com a qual estes exprimem determinados valores que o Estado não apenas deve respeitar, mas também promover e zelar pelo seu respeito, mediante uma postura ativa, sendo, portanto, devedor de uma proteção global dos direitos fundamentais. A propósito, verifica-se que a doutrina tende a reconduzir o desenvolvimento da noção de uma vinculação também dos particulares aos direitos fundamentais ao reconhecimento da sua dimensão objetiva, deixando de considerá-los meros direitos subjetivos do indivíduo perante o Estado. Há que acolher, portanto, a lição de Vieira de Andrade, quando destaca os dois aspectos principais e concorrentes da problemática, quais sejam, a constatação de que os direitos fundamentais, na qualidade de princípios constitucionais e por força do princípio da unidade do ordenamento jurídico, se aplicam relativamente a toda a ordem jurídica, inclusive privada, bem como a necessidade de se protegerem os particulares também contra atos atentatórios aos direitos fundamentais provindos de outros indivíduos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

ou entidades particulares.(...)

Nas relações entre particulares – para além da vinculação das entidades dotadas de algum poder social e afora as hipóteses excepcionais ventiladas -, é possível sustentar, em qualquer hipótese, ao menos uma eficácia mediata (indireta) dos direitos fundamentais, no âmbito do que os alemães denominaram de eficácia irradiante (Ausstrahlungswirkung), que pode ser reconduzida à perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais. Isto significa, em última análise que as normas de direitos privado não podem contrariar o conteúdo dos direitos fundamentais, impondo-se uma interpretação das normas privadas (infraconstitucionais) conforme os parâmetros axiológicos contidos nas normas de direitos fundamentais, o que habitualmente (mas não exclusivamente) ocorre quando se trata de aplicar conceitos indeterminados e cláusulas gerais do direito privado. Neste contexto, a função jurídico-objetiva dos direitos fundamentais "traduz o seu reconhecimento como princípios imediatamente conformadores da ordem jurídica, dotados de um efeito irradiante para as relações sociais em que não participam entidades públicas, ou entidades a que tenham sido atribuídas prerrogativas de direito público. De acordo com a orientação dominante no Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, os direitos fundamentais exercem sua influência na esfera do direito privado por intermédio dos dispositivos que regem cada área específica do direito, de modo especial, por meio das cláusulas gerais e dos conceitos carentes de interpretação e integração. Uma desconsideração desta eficácia irradiante, por outro lado, significa ofensa aos direitos fundamentais, passível de dedução em Juízo, inclusive por intermédio do controle das decisões judiciais atentatórias à Constituição, e de modo especial, aos direitos fundamentais, por parte da jurisdição constitucional, entre nós exercida, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal.

Se a tese da assim designada eficácia mediata (indireta) segue dominante na doutrina e jurisprudência alemãs, inclinamo-nos hoje – pelo menos à luz do direito constitucional positivo brasileiro – em prol de uma necessária vinculação direta (imediata) prima facie também dos particulares aos direitos fundamentais, sem deixar de reconhecer, todavia, na esteira de Canotilho e outros, que o modo pelo qual se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *opera a aplicação dos direitos fundamentais às relações jurídicas entre os particulares não é uniforme, reclamando soluções diferencias mediante recurso, em especial, à ponderação e correlato teste da proporcionalidade"* (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 387/390-391).

25. A afirmação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais não é novidade neste Supremo Tribunal Federal. Também não o é para o próprio ECAD que, no julgamento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 201.819/RJ, Relatora a Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, teve assentada a necessidade de garantir direito de ampla defesa e de contraditório a um de seus associados:

> *"EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO" (DJ

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

27.10.2006).

26. Não bastasse isso, tem-se que a todos os sujeitos submetidos ao ordenamento jurídico brasileiro é dado o direito de acesso às informações, nos termos do art. 5º, inc. XXXIII, inc. II, da Constituição da República.

27. A Lei n. 12.527/2011, que *"regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal"*, é taxativa ao estabelecer:

> *"Art. 2º. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres".*

O ECAD está, pois, obrigado a observar os princípios e as regras nela contidos, destacando-se:

> *"Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;*
>
> *II- divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;*
>
> *III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;*
>
> *IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;*
>
> *V - desenvolvimento do controle social da administração pública".*

Certo é que consta da exposição de motivos do projeto de lei que deu origem à Lei n 12.853/2013:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *"A manutenção do escritório central para a arrecadação e distribuição de direitos autorais apenas se justifica se forem aprovados requisitos mínimos de transparência e controle público a respeito das atividades desempenhadas pelo mesmo. Caso não haja a aprovação de regras estabelecendo maior transparência e responsabilidade pública para o ECAD, deve ser modificada a redação do projeto de modo a suprimir o monopólio do ECAD e abrir a arrecadação de direitos autorais à livre concorrência, nos termos dos princípios que regem a Ordem Econômica da Constituição Federal. Nessa hipótese, um regime de concorrência levaria as entidades arrecadadoras a competir por eficiência e transparência, visando buscar sua legitimação perante os autores e o público em geral, algo que não acontece hoje, já que artistas e público pagante pelo uso das obras não têm alternativas quanto ao desempenho destas atividades, que são prestadas em regime de monopólio".*

28. Como assentado na manifestação da Advocacia-Geral da União antes de significar a inobservância de normas constitucionais, a nova gestão coletiva instituída pela Lei n. 12.853/2013 permite a tutela de direitos fundamentais dos autores:

> *"De fato, a partir de uma interpretação sistemática do Texto Constitucional, verifica-se que os direitos fundamentais não podem ser exercidos de modo lesivo a outros direitos de igual hierarquia. Não há, conforme adverte a doutrina constitucionalista", supremacia a priori de um direito fundamental sobre outro. Em verdade, as tensões entre direitos dessa natureza devem ser superadas a partir dos elementos do caso concreto, mediante a aplicação de princípios da hermenêutica constitucional, tais como a razoabilidade e a ponderação de valores.*
>
> *Desse modo, a liberdade de associação e a autonomia e intimidade dos associados deve ser compatibilizada com o sistema de gestão coletiva de direitos autorais, o qual, como visto, possui relevante interesse público. Em decorrência, impõe-se a adoção de mecanismos de supervisão das entidades envolvidas capazes de conferir transparência e segurança jurídica aos autores, aos usuários e à própria sociedade, tendo em vista que a função social de tais entidades extrapola a mera representação de seus associados e a defesa*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *de seus interesses patrimoniais.*
>
> *Ademais, nota-se que o ECAD exerce um monopólio legal na arrecadação e distribuição dos direitos autorais, razão pela qual a própria lei possui o poder-dever de regular a forma como ele será exercido. Nessa linha, esse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não estatal"13.*
>
> *Conclui-se, portanto, que, por não restar evidenciada a atividade tipicamente associativa, porquanto jungida a uma função social consubstanciada na garantia da máxima efetividade do direito dos autores à justa remuneração pelo uso de suas obras em todas as suas modalidades de fruição, com transparência, imparcialidade e equilíbrio perante os potenciais detentores desses direitos, encontra-se justificada a extensão do modelo de supervisão dessa atividade, tendo em vista o interesse público".*

29. No caso vertente tem-se que a aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei n. 12.853/2013, consubstancia legítima pretensão da comunidade de autores e artistas, que há muito reivindicam a gestão democrática e transparente dos direitos autorais que lhe são reservados, na esteira da complexa e múltipla proteção constitucional reservada ao tema.

30. Para J. J. Gomes Canotilho *"o princípio democrático aponta, no sentido constitucional, para um processo de democratização extensivo a diferentes aspectos da vida econômica, social e cultural".* E, referindo-se à dispositivos da Constituição portuguesa, exemplifica: *"o controle da gestão, a gestão democrática das escolas, a liberdade interna da imprensa, a participação na administração local (…)* [s]*ão exemplos do entendimento do princípio democrático como princípio informador do Estado e da sociedade"* (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003. p. 290).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

31. A um só tempo, a lei manifesta, ainda, o empoderamento dos cidadãos (agora não mais sob a perspectiva patrimonialista dos autores, mas do povo brasileiro) do inalienável espaço da livre expressão cultural, pelo que o Estado *"garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais*" (art. 215, *caput*, da Constituição da República).

E direitos culturais (de produção e acesso à cultura) são direitos humanos, de conteúdo transnacional:

> *"O Relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento da UNESCO defende a criatividade como elemento intangível, cuja natureza deve ser cultivada e não dilapidada. Por isso, 'a criatividade deve ser nutrida e cuidada onde quer que apareça, justamente porque não pode ser ensinada ou encomendada. A despeito do seu potencial universal de desenvolvimento em um ambiente saudável, a centelha da criatividade artística é, de fato, tão rara que necessita ser ventilada onde que se se acenda, na esperança de que venha a tornar-se chama* (CUÉLLAR, Jávier Pérez: 1997, 105)'" (ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. A Ordem dos Músicos do Brasil e as liberdades de criação e de expressão – um indesejável obstáculo ao trabalho do artista. Revista da Legislação do Trabalho. N. 03, Ano 74, Março de 2010. p. 333, grifos nossos).

32. Incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, nos termos dos Tratados, Declarações e Convenções assinados pela República Federativa do Brasil, expressamente assegurados nas normas constitucionais, a responsabilidade estatal não se limita a garantir a liberdade da criação artística mas também a promoção e implementação de todos os meios de expressão e acesso aos direitos fundamentais sociais culturais.

33. As questões afetas à expressão cultural são sensíveis e de múltiplas implicações, pelo que não se resolvem, no plano constitucional,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

apenas sob a perspectiva privatística do direito de propriedade intelectual da sua produção. Ao contrário, congrega valores que, em última análise, tocam na dignidade da pessoa humana. Como assentei no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130,

> *"a liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político. A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana. Por isso é que, sem liberdade – aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento – não há democracia"* (DJ 6.11.2009).

34. Por ser *"a liberdade ... indivisível, ou seja, os direitos fundamentais são interdependentes e se apoiam uns nos outros, e, se fortalecem reciprocamente"* (MURILLO, Pablo Lucas. *El Derecho a La Autodeterminación Informativa.* Madri: Tecnos, 1990. p. 38), os direitos ora analisados interpenetram[1] o direito à cultura, permitindo que a expressão artística, elemento de *"transitivação ou projeção do que se encontra na alma do artista, no mundo"*[2], sirva como instrumento de construção dos povos.

Nas lições de J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira

> *"o direito à fruição e criação cultural é um direito individual e*

---

1 Jorge Miranda ensina que, em casos como o presente, não "*se trata de um mero somatório, mas sim de uma interpenetração mútua* [de direitos], *com a consequente necessidade de harmonia e concordância prática. Os direitos vindos de certa época recebem o influxo dos novos direitos, tal como estes não podem deixar de ser entendidos em conjugação com os anteriormente consagrados: algumas liberdades e o direito de propriedade não possuem hoje o mesmo alcance que possuíam no século XIX, e os direitos sociais adquirem um sentido diverso consoante os outros direitos garantidos pelas Constituições"* (MIRANDA, JORGE. "O regime dos direitos sociais". *Revista de Informação Legislativa*. Brasília. Ano 47. n. 188 out./dez. 2010. p.24).

2 Para José Cretella Júnior *"o vocábulo 'expressão' é sinônimo de 'manifestação', de 'projeção', de 'transitivação'. Atividade intelectual é algo interno ou intransitivo do homem, analogamente ao sentimento, à paixão, à consciência à crença, à fé. Todas essas atividades pertencem ao fórum internum"* (CRETELLA JÚNIOR, José. *Comentários à Constituição Brasileira de 1988.* vol. I. art. 1º a 5º, LXVII. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 255).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *colectivo, cujas principais dimensões são: (a) acesso a todos os bens, meios e instrumentos culturais e a todos os níveis; (b) participação na cultura, possibilitando aos cidadãos e às comunidades o direito de conformação do processo de produção cultural, como titulares de participação democrática activa (criação) e não meramente passiva (fruição); (c) comparticipação na defesa e enriquecimento do património cultural comum"* (CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. *Constituição da República Portuguesa anotada.* vol. I. 4. ed. Coimbra editora: Coimbra, 2007. p. 926).

35. Partindo dessas premissas, e especificamente no campo da exploração econômica da produção cultural, este Supremo Tribunal confirmou, por exemplo, a constitucionalidade de norma estadual assecuratória de meia-entrada aos estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino, ao assentar:

> *"Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto* [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. *Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes"* (ADI 1.950/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.6.2006).

36. Ainda no Direito Internacional, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas constituiu ato internacional destinado a proteção dos direitos autorais. Assinada em 9 de setembro de 1886 e revista em Paris em 24.07.1971, a Convenção resguarda os direitos dos autores de obras literárias e artísticas, levando em conta a intensa circulação dessas obras entre as fronteiras dos países e a diversidade de legislações nacionais sobre direitos autorais que figuravam antes de sua adoção. O Brasil ratificou a Convenção, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 94, de 4.12.1974, e internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

37. Os direitos conexos receberam proteção internacional pela Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, também denominada de Convenção de Roma, adotada em 26 de outubro de 1961. A Convenção segue o espírito da Convenção de Berna e estabelece um leque de direitos aos resguardados por seu texto. O Brasil também é parte de tal ato internacional. Foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 26, de 5.08.64 e promulgado pelo Decreto nº 57.125, de 19.10.1965.

38. Somam-se a essas duas Convenções, a Convenção Universal sobre o Direito de Autor, assinada em 6.09.1952 e revista em Paris em 13.10.1959. Assim como a Convenção de Berna, a Convenção Universal conduz proteção aos direitos autorais, conforme o art. I expõe:

> *"Os Estados contratantes comprometem-se a tomar todas as disposições necessárias para assegurar a proteção suficiente e eficaz dos direitos dos autores e de quaisquer outros titulares dos mesmos direitos sobre as obras literárias, científicas e artísticas, tais como os escritos, as obras musicais, dramáticas e cinematográficas, as obras de pintura, gravura e escultura".*

39. O ordenamento jurídico brasileiro internalizou a norma, que fora aprovada pelo Decreto Legislativo nº 55, de 28.06.1975, pela promulgação em Decreto nº 76.905, de 24.12.1975.

40. A Constituição da República, em seu art. 216, é enfática ao qualificar como *"patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem (...) as criações científicas, artísticas e tecnológicas"* (art. 216, inc. III, da Constituição da República).

41. Vê-se, portanto, que a discussão afeta às formas de gestão e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

cobrança de direitos autorais no Brasil, não se limita ao aspecto patrimonial privado das produções artísticas ou intelectuais. Em outras palavras, falar em direitos autorais (art. 5º, inc. XXVII, da Constituição) é, precipuamente, falar em patrimônio cultural (art. 215), é agregar valor e função social (art. 5º, inc. XXIII) a essa modalidade imaterial de propriedade (art. 5º, inc. XXVII).

42. A natureza *sui generis* dos direitos autorais, que passa pelo direito público, congrega valores constitucionais de alto relevo histórico, ultrapassando a esfera econômica. Na clássica lição de José Afonso da Silva, uma visão civilista da propriedade *"não alcança a complexidade do tema, que é resultante de um complexo de normas jurídicas de direitos público e de direito privado, e que pode interessar como relação jurídica e como instituição jurídica"* (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 117).

43. Conforme ponderei no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.815 (Biografias, Sessão 10.6.2015) *"quem busca a luz não há de exigir espaço intocado de sombra"*. No exercício da liberdade de criação e da profissionalização artística, a acepção constitucional do que seja privado ou público, sujeita-se ao temperamento do vocação social e cultural daqueles que promovam

> *"as suas atividades em público e para o público, do qual extraia a sua condição profissional e pessoal, difíceis como são os lindes de uma e outra quando o nome, a profissão ou a função extraem do público o seu desempenho e do qual dependa o seu êxito. Quem busca a luz não há de exigir espaço intocado de sombra; ou [quem] extraia ou retire dos cidadãos, pelo exercício de sua função ou atividade, os ganhos materiais, profissionais ou de reconhecimento, com os quais se dá a viver, pelo que há de ser por eles conhecido.; ou [aquele que] extraia ou retire dos cidadãos, pelo exercício de sua função ou atividade, os ganhos materiais, profissionais ou de reconhecimento, com os quais se dá a viver, pelo que há de ser por eles conhecido"*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Ainda para José Afonso da Silva:

> *"O caráter absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo a qual se exercício não estaria limitado senão na medida em que ficasse assegurado aos demais indivíduos o exercício de seus direitos), foi sendo superado pela evolução, desde a aplicação da teoria do abuso do direito, do sistema de limitações negativas e depois também de imposições positivas, deveres e ônus, até chegar-se à concepção da propriedade como função social, e ainda à concepção da propriedade socialista, hoje em crise".* (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 117).

44. A função social da propriedade (de qualquer espécie) é princípio estruturante desse direito, de amplitude e aplicação imediata, ensina José Afonso da Silva. Elemento que preordena *"fundamentos às limitações, obrigações e ônus relativamente à propriedade privada"*, como se tem, por exemplo, na limitação legal do direito hereditário da propriedade intelectual:

> *"O direito hereditário da propriedade intelectual cabe aos herdeiros descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais, de acordo com a lei civil, mas também se defere aos herdeiros testamentários. A herança dos direitos de autor vige pelo tempo que a lei fixar. A Lei 5.988, de 14.12.1973, ora revogada, o reputava vitalício, mas essa situação foi modificada pela Lei 9.610, de 19.2.1998, que, conforme sua ementa, alterou, atualizou e consolidou os direitos autorais. Segundo suas disposições, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento. Com o falecimento do autor, esses direitos passarão a seus herdeiros, de acordo com a ordem das vocações sucessórias da lei civil, o que inclui a União, Estado, Distrito Federal e Município, aplicando-se o mesmo prazo às obras póstumas (arts. 41-44). Findos os 70 anos, a obra ou obras caem no domínio público, e isso quer dizer que qualquer um pode explorá-las economicamente (art. 45), respeitados sempre os direitos morais do autor, integridade da obra, etc"* (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 119).

Para Maristela Basso:

> *"Lembramos que a base constitucional dos direitos intelectuais, de certa forma, também se encontram em outros momentos da CF de 1988, além do desdobramento do inciso seguinte (XXVIII). Ressaltamos as linhas gerais referentes à liberdade de expressão, notadamente a livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV); a livre expressão da atividade intelectual e da comunicação (art. 5º, IX), o acesso à informação (art. 5º, inciso XIV). Verifica-se, por meio desses dispositivos, que a intenção primeira da Constituição Federal é a de estabelecer liberdade, e não a de criar direitos exclusivos. E se o que aqui institui são liberdades, então são as restrições que terão de ser justificadas pela Constituição.*
>
> *(...)*
>
> *Predomina na doutrina o entendimento de que o direito do autor é um direito autônomo, sui generis. De início, a introdução do direito de autor no sistema codificado de-se pela via dos direitos reais, ainda que se tratasse de bens incorpóreos, como direito de propriedade imaterial. Em seguida, a concepção foi fundada na teoria dos direitos da personalidade, diante da ênfase dada aos direitos morais do autor, que compreenderiam direitos da própria pessoa. Isso se deu porque sua natureza jurídica assenta-se sob as duas bases tradicionais e distintas: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Da mesma forma, esses bens imateriais são objetos de negócios jurídicos (licenciamento, concessão, cessão), matéria do direito das obrigações. E por isso mesmo que essas tentativas de enquadramento no dreito público ou no direito privado devem ser descartadas, por se revelarem insuficientes. É exatamente pelo fato de se repartir nesses três feixes – pessoal, real e obrigacional – que o direito do aturo constitui nova modalidade de direito privado* – sui generis." (BASSO, Maristela, Art. 5º, inc. XXVII In: CANOTILHO, J.J. Gomes, et al (Coords.) *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina: 2014. p. 327 *apud* ASCENÇÃO, José de Oliveira, *Direito Intelectual, exclusivo e liberdade*, p. 42).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

45. *"A propriedade atenderá a sua função social - diz o art. 5º, XXIII, para a propriedade em geral. Essa disposição bastava para que toda forma de propriedade fosse intrinsecamente permeada daquele princípio constitucional"*, enfatiza José Afonso da Silva. E prossegue:

> *"Mas a Constituição não se limitou a isso: reafirmou a instituição da propriedade privada e sua função social como princípios de ordem econômica (art. 170, II e III), relativizando, assim, seu significado, como veremos. Além disso, inscreveu o princípio da função social da propriedade, com conteúdo definido em relação às propriedade urbana e rural, com sanções pra o caso de não ser observado (arts. 182, 184 e 186). (...) A norma que contém o princípio da função social da propreidade incide imediatamente, é de aplicabilidade imediata, como o são todos os princípios constitucionais"* (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 120).

46. Constitucional, portanto, a norma do art. 97, § 1º, alterada pela Lei n. 12.853/2013, segundo a qual, as associações de titulares de direitos de autor, por determinação desta lei, devem atender à sua função social. Para tanto, a lei mostra-se coerente ao adotar *"os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma"* (art. 98, § 2º, da Lei n. 12.853/2013).

47. De igual modo, o art. 98 e seus desdobramentos visam preordenar instrumentos facultativos e sujeitos à deliberação dos associados *"para ações de natureza cultural e social"* que os beneficiem de forma coletiva (art. 98, § 16, da Lei n. 12.853/2013).

Conforme pontuou a Advocacia-Geral da União:

> *"A liberdade de associação e a autonomia e intimidade dos associados deve ser compatibilizada com o sistema de gestão coletiva de direitos autorais, o qual, como visto, possui relevante interesse público. Em decorrência, impõe-se a adoção de mecanismos de supervisão das entidades envolvidas capazes de conferir transparência e segurança jurídica aos autores, aos usuários e à própria sociedade,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *tendo em vista que a função social de tais entidades extrapola a mera representação de seus associados e a defesa de seus interesses patrimoniais.*
>
> *Ademais, nota-se que o ECAD exerce um monopólio legal na arrecadação e distribuição dos direitos autorais, razão pela qual a própria lei possui o poder-dever de regular a forma como ele será exercido. Nessa linha, esse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não estatal".*

48. Ao contrário do que alegam os Autores, a lei impugnada não subverte, antes, promove a gestão democrática e transparente da arrecadação de direitos autorais, sem perder de vista, a tutela da cultura nacional e do patrimônio imaterial do povo brasileiro. Cuida do todo e da parte, na medida em que democratiza e torna transparente o sistema de cobrança de direitos a que se sujeitam artistas e público.

49. O art. 5º, inc. XXVIII, al. 'b', da Constituição é enfático ao assegurar, nos termos da lei, *"o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas"*.

Essa norma não se limita a conceder mero direito de informação aos autores, de peticionarem ou obter dados quanto à arrecadação de direitos autorais. Vai muito além. O que a Constituição assegura expressamente é o direito subjetivo de fiscalização do aproveitamento econômico das obras criadas. Dando concretude a essa garantia constitucional a lei 12.853/2013 impõe (por exemplo, nos art. 98-B e 100) a gestão compartilhada, democrática e igualitária das Associações de Titulares de Direitos de Autor.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

50. As legislações de países como Espanha, França e Portugal apresentam normas direcionadas a regulação de entidades coletivas de direitos autorais.

Na Lei de Propriedade Intelectual espanhola, aprovada pelo Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril de 1996, exige-se a autorização do Ministério da Cultura para a constituição de entidades de gestão, que

> *"pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual" (art. 147). A lei permite que o Ministério da Cultura revogue a autorização dessas entidades, caso essas não cumpram com as obrigações estabelecidas na normativa (art. 149). O estatuto dessas instituições deve conter os direitos dos sócios e o regime de voto, "que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderación que limiten razonablemente el voto plural, garantizando, en todo caso, una representación suficiente y equilibrada del conjunto de los asociados. Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente en la duración de la condición de socio en la entidad de gestión, en las cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será igualitario"*. (art. 151, 5).

51. Assim como na legislação espanhola, o Código de Propriedade Intelectual francês trata das entidades de gestão, denominadas de *"societés de perception et de répartition"*, que se ocupam da defesa dos direitos dos autores. O Código, que entrou em vigor em 3 de julho de 1992, exige a submissão ao Ministro da Cultura do estatuto e regras gerais dessas entidades de gestão (art. L321-13).

52. No ordenamento jurídico português, os autores de obras são resguardados pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/85, de 14.03.85. Ademais, a legislação portuguesa conta com Lei nº 26/2015, de 14 de abril de 2015, que regula as entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

Na normativa, elas são entendidas como *"associações ou cooperativas privadas com personalidade jurídica e fins não lucrativos"* (art. 5º), que se dedicam à gestão dos direitos patrimoniais de seus associados e às ações que beneficiem aqueles que representam (art. 3º).

A lei exige que essas entidades requeiram autorização e registro na Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) do governo português (art. 11º), sendo a autorização passível de revogação, como em casos em que o estatuto da entidade não estiver em conformidade com os demais dispositivos da normativa (art. 12º).

53. De volta ao ordenamento brasileiro, a lei impugnada, sem afronta à Constituição, mas no exato sentido de sua concretude, as opções políticas do legislador ordinário, havidas na lei impugnada, aperfeiçoam o convívio republicano e democrático entre os interesses público e privado, afetos à matéria. Para tanto, institui sanções proporcionais pelo seu descumprimento (art. 109-A).

54. O desenvolvimento tecnológico, em especial o da tecnologia da informação impulsionado pela capilaridade da internet, tem permitido o aprimoramento dos instrumentos de gestão, assegurando-lhes maior transparência e eficiência. Esse desenvolvimento alcançou, como não poderia deixar de ser, a gestão coletiva de direitos autorais, tendo o projeto que resultou na promulgação da Lei n. 12.853/2013 se inspirado na concretização de princípios orientadores que deve subordinar a atuação das associações incumbidas da gestão coletiva do patrimônio autoral. Sobre o tema, Ronaldo Lemos leciona:

> *"a) Transparência. O projeto de lei cria obrigações claras de transparência para gestão coletiva, por se tratar de atividade que afeta número difuso de pessoas, tanto na sociedade quanto no segmento de artistas, produtores e titulares de direitos.*
>
> *b) Eficiência. O projeto estabelece a eficiência como princípio, tanto técnico quanto econômico. Artistas terão direito a serem informados sobre seus direitos e créditos. Além disso, as regras de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

concorrência previstas na Constituição Federal aplicam-se à gestão coletiva.

c) Modernização. O projeto reorganiza a gestão coletiva, racionalizando a estrutura das associações que a compõem. As associações passam a ser divididas por direitos específicos. Estabelece também o princípio da modernização tecnológica em favor do artista e dos titulares de direitos autorais.

d) Regulação. O projeto mantém a existência de um único escritório central. Em contrapartida, este fica subordinado ao Ministério da Justiça, que funcionará como instância reguladora e supervisara.

e) Fiscalização. O projeto atribui ao Ministério da Justiça a prerrogativa de fiscalizar a gestão coletiva, selecionando e homologando as entidades por ela responsáveis e prevenindo abusos, inclusive quanto ao

arbitramento de preços.

(...)

A razão para que as associações de gestão coletiva se subordinem a esses princípios consiste no fato de que as mesmas são depositárias de vultosos recursos arrecadados com força de lei perante diversos estratos da sociedade brasileira. Esses recursos são recebidos não em seu próprio nome, mas em nome dos seus associados, artistas, compositores e demais titulares de direitos autorais.

Dessa forma, o Ecad e as associações que o compõem, corno depositários destes recursos, possuem deveres fiduciários com relação ao grupo difuso que a eles contribui, quanto ao grupo difuso que deles deve receber. Dessa relação fiduciária emerge a necessidade de regulação do sistema de gestão coletiva. Através da proposta, ficam estabelecidas regras mínimas de transparência, eficiência e idoneidade como forma de assegurar seu melhor funcionamento e aperfeiçoamento institucional

A manutenção do escritório central para a arrecadação e distribuição de direitos autorais apenas se justifica se forem aprovados requisitos mínimos de transparência e controle público a respeito das atividades desempenhadas pelo mesmo. O monopólio exercido pelo Ecad é um privilégio concedido por lei, que implica também maior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *responsabilidade por parte das entidades arrecadadoras: em troca do monopólio concedido pela sociedade é natural que o Ecad seja obrigado a prestar contas de forma transparente a respeito de suas atividades"* (LEMOS, Ronaldo. A gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil: a regulação do Ecad e sua reforma. In Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Org. Sérgio Guerra. Editora Fundação Getúlio Vargas. p. 339-347).

Nessa mesma linha, ao se pronunciarem sobre a necessidade de adequação do sistema de gestão do patrimônio intelectual ao novo modelo surgido a partir do desenvolvimento tecnológico e de aprimoramento da legislação pertinente, Michele Braum e Luiz Gonzaga Silva Adolfo assinalam:

> "[A] *virtualização das criações intelectuais trouxe ao mundo dos Direitos Autorais maior complexidade no que diz respeito à proteção desses direitos. Ainda, a falta de um sistema legal realmente eficaz e capaz de atender à gestão coletiva dos direitos autorais acarretou certa insegurança tanto para os autores quanto para os usuários das obras.*
>
> *(...)* [O] *contexto atual, diferentemente do estabelecido na legislação autoral brasileira já obsoleta, suscita alguns questionamentos no que tange às andanças das criações intelectuais na rede. (...) Por sua vez, as facilidades advindas da utilização da Internet como meio de comunicação, aumentando de forma exponencial o acesso à informação, como já afirmado, considerando a sua grande capacidade difusora e a liberdade que é sua característica, tornam-na notável meio de distribuição de criações autorais, incitando desafios quando se trata de gestão coletiva de Direitos Autorais, porque a simples circulação das obras e, até mesmo, o download delas são situações corriqueiras no dia a dia da sociedade informacional. (...)*
>
> *Nesse panorama, reitera-se que se entende imprescindível uma melhor regulação da atividade de gestão coletiva dos Direitos Autorais no Brasil, com intuito de se adequar ao contexto tecnológico contemporâneo, abrangendo todos os tipos de obras intelectuais e, ainda, estabelecendo competências de regulação por uma gestão*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *fiscalizada pelo poder público, o que possivelmente ocorrerá após a sanção do Projeto de Lei sobre gestão coletiva de Direitos Autorais, e para a solução dos conflitos decorrentes da proteção do Direito Autoral. Dessa maneira, Cordeiro enfatiza que isso "implica entidades de gestão modernas, transparentes e rápidas"* (grifo do autor)" (Braum, Michele e Adolfo, Luiz Gonzaga Silva. A gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil: uma reflexão sobre o contexto da lei 9.610/98. Revista Direito, Estado e Sociedade. N. 42, jun/jul 2013, p. 194-197).

Prosseguem os autores destacando que o aprimoramento do sistema de gestão adotado no Brasil requer melhorias no sistema regulatório, em especial o incremento da supervisão e fiscalização estatal como meio de equilibrar a relação entre os agentes envolvidos na gestão coletiva de patrimônio autoral:

> *"A título de esclarecimento, registra-se que o Brasil é um dos vinte maiores mercados de música do mundo, destacando-se como caso único de país que não possui regulação da atividade de gestão coletiva e, muito menos, de competências para resolução de conflitos nessa área. É bem verdade que*
>
> *A questão sempre levantada contra as sociedades de administração coletiva é a do monopólio. Toda a instituição coletiva de administração de licenças, por sua própria natureza, estará sempre numa posição dominante. Sem mecanismos que garantam repressão ao abuso, faltará o interesse público para as sociedades de administração coletiva. Nos casos (não poucos), em que a situação de monopólio foi denunciada, considerou-se que é preferível aceitar, a bem do interesse público, a utilização do monopólio de fato, mas controlando-o de outras formas. O Brasil prevê expressamente monopólio do ECAD para arrecadação de direitos autorais. O Brasil prevê expressamente o monopólio de um escritório central para arrecadar direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiofusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais (art. 99).*
>
> *(...)*
>
> *É bem verdade que a Constituição Federal de 1988 permite a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

> *liberdade de associação, como visto; no entanto ela não pode ser realizada de qualquer modo e sem supervisão do Estado. Assim, havendo qualquer tipo de irregularidade, a entidade supervisora (vinculada ao Ministério da Cultura, como propõe o anteprojeto da LDA e propõe também o já aprovado Projeto de Lei sobre gestão coletiva de Direitos Autorais pendente apenas de sanção Presidencial) poderia apurar o ocorrido "[...] sem prejuízo da apreciação pelos Órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da concorrência".*
>
> *Deve-se frisar que o que se está discutindo neste trabalho não significa a intervenção do Estado nas associações de gestão coletiva de Direitos Autorais; a supervisão da gestão coletiva vai além disso: garante os direitos do detentor-autor, exige transparência das entidades de gestão coletiva; estabelece o autor como o protagonista de seus direitos; busca o equilíbrio entre os interesses públicos e privados; etc."* (Braum, Michele e Adolfo, Luiz Gonzaga Silva. A gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil: uma reflexão sobre o contexto da lei 9.610/98. Revista Direito, Estado e Sociedade. N. 42, jun/jul 2013, p. 207).

55. Na espécie, a lei impugnada estabelece balizas constitucionalmente viáveis para o setor, guiada pela "*razoabilidade, boa-fé, usos locais de utilização de obras (...) considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento*" (art. 97, §§ 3º e 4º, da Lei n. 12.853/2013).

Não se substitui, contudo, aos interesses e à liberdade de seus associados (art. 98), objetivando o fortalecimento da coesão e da justeza (inclusive fiscal – arts. 99, § 6º; 98-A; 100; 100-A) do sistema arrecadador (por exemplo, na vedação à dupla associação para a gestão coletiva de direitos de mesma natureza, na regulamentação básica dos instrumentos de pagamento e cobrança de valores).

No ponto, a Procuradoria-Geral da República pondera:

> *"Conforme exposto alhures, a interferência do legislador na organização das associações justifica-se pela já alegada função social*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

da propriedade imaterial. É incoerente falar em irrestrita liberdade de associação para esse domínio institucional, porquanto, como se viu, o próprio Ecad foi criado por lei, não como manifestação da autonomia da vontade. Tais associações, assim como o Ecad, enquadram-se na categoria de associações não expressivas, nas quais se admite maior intervenção estatal. Veja-se a classificação proposta por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO:

Às sociedades expressivas (de cunho espiritual, ideológico) contrapõem-se as não expressivas (de finalidades profissionais ou comerciais). Neste último grupo, incluem-se as associações que se dedicam a viabilizar certas atividades essenciais aos associados, sobretudo quando atuam de forma monopolizadora. São também não expressivas as associações que exercem, com marcado predomínio na sociedade, uma função social ou econômica relevante. Essas associações, ao contrário das expressivas, estão sujeitas a imposições estatais relacionadas com o seu modo de existir, em virtude da pertinência a elas de outros valores constitucionais concorrentes.

41. Sobre o direito à liberdade de associação, o ilustre autor corretamente anota:

A liberdade de associação gera, ao lado da sua feição de direito de defesa - impondo barreira à interferência estatal -, uma obrigação positiva para o Estado. Não obstante o reconhecimento da personalidade jurídica não seja essencial para que a associação se veja protegida constitucionalmente, imperativos de segurança jurídica cobram que o legislador preveja formas de associação que viabilizem aos grupamentos atingir plenamente os seus objetivos. Para isso, não raro, a associação terá que assumir forma disciplinada pelo legislador. Cogita-se, então, aqui, de uma pretensão a que o legislador disponha sobre tipos associativos, do que resulta um aspecto de direito a prestação normativa da liberdade de associação. [...] Reconhece-se, de toda sorte, ao legislador uma liberdade ampla de conformação neste particular, respeitados certos limites, como, por exemplo, o de não se impor a permanência eterna do associado na pessoa jurídica de direito privado e o de não se reduzir, para além do necessário, a margem de auto-organização da própria entidade.

42. Nessa perspectiva, o direito fundamental à liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

associação possui não só face negativa, mas também feição positiva para o Estado, que deve contribuir para a efetiva conformação dos direitos autorais, de modo a atender os diversos valores constitucionais concorrentes a liberdade associativa.

43. Afinal, a Constituição assegura não só a liberdade de associação, mas protege também o direito às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, além de garantir o direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei questionada, fazendo apropriada ponderação de valores constitucionalmente protegidos, veio para mais bem proteger e concretizar o direito autoral".

Pelo que conclui:

46. O art. 98, § 1º, da Lei 9.610/98 estabelece a exigência de habilitação prévia em órgão da administração pública federal para o exercício da atividade de cobrança de direitos autorais por parte das associações. Por sua vez, o art. 98-A dispõe sobre o procedimento de habilitação e sobre a possibilidade de anular-se o ato de qualificação. Os arts. 49 a 62 fixam a necessidade de adequação das associações já constituídas às condições contidas na Lei 12.853/2013. Por fim, os arts. 7º e 8º definem a competência do Ministério da Cultura para promover o aprimoramento da gestão coletiva de direitos autorais.

47. Segundo as requerentes, esse conjunto normativo violaria a liberdade de associação, o direito adquirido e o princípio da proporcionalidade, na medida em que condiciona o exercício da cobrança de direitos autorais das associações preexistentes e das que venham a ser constituídas a prévia habilitação em órgão público federal.

48. Não se vislumbra violação aos preceitos constitucionais. As normas não impedem a formação de associações representativas da classe dos músicos, mas apenas criam condição para que elas possam exercer a atividade específica de cobrança e distribuição de direitos autorais. Nesse sentido, não há intervenção estatal na constituição e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

na dissolução dessas pessoas jurídicas. A condição prevista na lei, por outra parte, é compatível com o regime público da gestão coletiva de direitos autorais, na linha que vem ao menos desde a Lei 5.988/73 e que perdura na ordem constitucional pós-1988.

49. Esses dispositivos possibilitam que o exercício da atividade de cobrança de direitos autorais ocorra de maneira mais transparente, eficiente e justa, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

50. É pertinente destacar outro trecho da justificação do projeto de lei, que esclarece a necessidade de habilitação das associações (sic):

[...] Isso não impede o direito de livre associação dos titulares de direitos, garantido no Artigo 5º, Inciso XVII, da Constituição Federal, pois não obsta ou dificulta de qualquer maneira a criação de associações por autores ou titulares de direitos conexos. Modalidades de outorga de habilitação e qualificação, diga-se, aplicam-se às mais diversas atividades, como é o caso das instituições financeiras, as OSCIPs, os cartórios, os registros de títulos e documentos, dentre muitas outras. Não há o que se falar em cerceamento da liberdade de associação derivada da necessidade de habilitação, ainda mais considerando-se que a preservação da existência de um único Escritório Central, implica, em si, em intervenção pública na atividade econômica de arrecadação de direitos autorais, o que por si só justifica que, em contrapartida, a atividade seja regulada e fiscalizada de perto.

51. Como se analisou, a cobrança e a distribuição de direitos autorais não se incluem nas atividades típicas de associação de direito privado, mas constituem função social, o que justifica a regulamentação e o controle dessas entidades - sobremodo em face da má experiência brasileira de autonomia exacerbada do Ecad. A exigência de qualificação das associações, ao conferir transparência, eficiência e segurança jurídica e ao assegurar proteção aos direitos autorais, amolda-se exatamente à atuação positiva do poder público na promoção da liberdade de associação no domínio do Direito Autoral.

52. Tampouco caracteriza ofensa a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito a aplicação da nova regulamentação às associações já constituídas, nos termos dos arts, 4º a 6º da Lei 12.853/2013".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

56. A lei democratiza o processo decisório das associações ao limitar o abuso do poder econômico (e sua perpetuação) na condução da vida cultural brasileira (por exemplo, pela imposição de mandatos a seus dirigentes, pela previsão do voto unitário de cada associação integrante) fidelizando a expressão cultural à universalidade de seus agentes, independentemente do peso financeiro.

57. Circunscrever o que muitas vezes é a própria viabilidade da expressão artística (e da sobrevivência de muitos artistas) a interesses de monopólios, de administração pouco conhecida, é perigoso e não promove a causa da arte, que se alimenta da arte.

> *"A história da arte possibilita-nos, de fato, identificar e descobrir elementos de continuidade cultural na forma dos motivos artísticos que uma cultura transmite a outra, e estabelecer os elos que ligam os povos primitivos de qualquer período, tanto a seus vizinhos contemporâneos, como a seus predecessores. (...) Cabem aqui algumas palavras de explicação para definir a natureza do enfoque 'difusionista' aplicado à arte e à civilização, e que pode ser resumido na frase atribuída a Leo Frobenius: 'O mapa não mente!'. (...) Uma cultura primitiva traz muitas vezes incubadas as ideias básicas que outra mais avançada faz frutificar. A arte ilustra este processo"* (LOMMEL, Andreas. *A arte pré-histórica e primitiva.* Enciclopédia Britânica do Brasil. 7. ed. vol. 1. p. 8 e 12).

A obra, hoje tida por original, lança, na verdade, raízes na inspiração de outros artistas, não havendo como se privatizar as típicas manifestações do espírito humano:

> *"as artes são distintas e distinguíveis entre si apenas se encaradas do exterior, fisicamente, em seus caracteres (linhas, cores, tons, sons particulares, etc.). Mas a obra de arte é sempre um ato espiritual: e do físico ao espiritual, e dos conceitos da física àqueles da filosofia não há passagem"* (GALEFFI, Romano. 'A tese da autonomia da arte fundamento indispensável de toda estética filosófica.' Revista Brasileira de Filosofia. Vol. XXV, Fasc. 99, Julho – Setembro de 1975, p. 292*).*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

58. Quanto mais democráticos forem os processos e instrumentos de gestão cultural, mais livre e igualitária será a sua expressão material. E quanto mais livre sua expressão, mais viva, rica e frondosa será a nossa cultura.

59. Por fim, cumpre salientar, que a interpretação literal do art. 98 da Lei n. 12.853/2013 poderia conduzir à negativa de acesso individualizado dos autores ao Poder Judiciário:

> *"Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos".*

Interpretação conforme o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição, conduz à conclusão de que o ajuizamento de ação coletiva pela associação de autores não obsta o acesso individualizado de seus associados ao Poder Judiciário.

É dizer, observados os efeitos processuais decorrentes da opção livremente assumida pelo associado, não poderá a associação, de forma direta ou indireta, praticar quaisquer atos contrários aos demais direitos fundamentais titularizados por aquele que preferiu defender direito próprio por via diversa da coletiva.

60. Pelo exposto, **julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445352.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
REQTE.(S)	: ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS, ARRANJADORES E REGENTE AMAR - SOMBRÁS - SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA E OUTRO(A/S)
REQTE.(S)	: ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS
REQTE.(S)	: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - SBACEM
REQTE.(S)	: SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM
REQTE.(S)	: SOCINPRO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS
REQTE.(S)	: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
ADV.(A/S)	: PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S)	: SYDNEY LIMEIRA SANCHES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S)	: RODRIGO BRANDAO VIVEIROS PESSANHA E OUTRO(A/S)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173633.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sou daqueles – e acredito ser o pensamento dos Colegas o mesmo – que continuam acreditando que, em Direito, o meio justifica o fim, mas não o fim o meio.

Em termos de interferência na vida associativa, exagerou-se sobremaneira na dose, a menos que possa fechar a Lei das Leis, a Constituição Federal, no que se tem, no rol das garantias constitucionais, que a criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no funcionamento. Chegou-se a dispor, inclusive, sobre eleição dos dirigentes da associação.

O caso é importantíssimo, presente a higidez da Carta da República. Como disse, não elaborei voto escrito, porque o tempo não é suficiente sequer para elaborar votos relativos a processos sob minha relatoria, muito menos para confeccionar, depois da reflexão cabível, voto como vogal, voto escrito.

Mas, de qualquer forma, ante a importância da matéria, peço vista.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173633.

28/04/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Eu vou pedir vênia ao Ministro Marco Aurélio, não sem antes cumprimentar os eminentes Advogados que assomaram a tribuna, e o faço na pessoa do Professor Carlos Mathias, que, depois de uma longa ausência, volta com muito brilho às lides forenses, e não sem antes também de cumprimentar o eminente Relator, que traz um voto, como disse o Ministro Barroso, esgotando a matéria, abordando-a sob diversos ângulos, sob o ângulo de várias disciplinas jurídicas.

Eu fique particularmente impressionado com a intervenção da Doutora Grace, como sempre ela traz luzes para as discussões do Plenário desta Corte, quando, logo de início, Sua Excelência afirmou que a alínea "b" do inciso XXVIII do art. 5º da Constituição Federal expressamente autoriza a fiscalização do aproveitamento econômico das obras que os autores criam. Portanto, aqui, parece-me que a Constituição criou uma exceção legal, permitindo uma intervenção, e acredito que mitigada, nesta liberdade quase que absoluta de associação que a Constituição garante aos cidadãos brasileiros.

Mas, não fosse isso, o Ministro Fux demonstrou à saciedade que essa Lei nº 12.853 protege, a meu ver, de forma razoável e eficiente, o direito dos autores e também de seus usuários. E mais, ela não inibe a criatividade, empresta transparência e torna o sistema mais democrático.

Ditas essas palavras, e de forma improvisada, eu me associo integralmente ao voto denso e substancioso do Ministro Luiz Fux para rejeitar as preliminares, conhecer das ações diretas de inconstitucionalidade, mas negar-lhes provimento também.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Julgando-as improcedentes.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Julgando-as improcedentes. Perfeito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384513.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, há um pedido de vista.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Sendo assim, vou sobrestar o meu pronunciamento para ouvir primeiro o voto-vista do Ministro Marco Aurélio, porque certamente Sua Excelência trará bons argumentos para que eu possa refletir, mais uma vez, sobre a matéria. Peço escusas pelo equívoco que cometi. Entendi que Sua Excelência já havia enfaticamente se pronunciado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12384513.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS, ARRANJADORES E REGENTE AMAR - SOMBRÁS - SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA
ADV.(A/S) : CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA (000530/DF) E OUTRO(A/S)
REQTE.(S) : ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS
REQTE.(S) : SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - SBACEM
REQTE.(S) : SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM
REQTE.(S) : SOCINPRO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS
REQTE.(S) : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
ADV.(A/S) : PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO (60962/RJ) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S) : SYDNEY LIMEIRA SANCHES (66176/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S) : RODRIGO BRANDAO VIVEIROS PESSANHA (0107152/RJ) E OUTRO(A/S)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deliberou adiar o julgamento do feito. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 14.04.2016.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que rejeitava as preliminares, conhecia integralmente da ação e julgava improcedentes os pedidos formulados, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, o Ministro Dias Toffoli, participando, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na VIII Conferência Ibero-americana sobre a Justiça Eleitoral, promovida pelo Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA Internacional) e pelo Tribunal Superior Eleitoral, realizada em Manaus, Amazonas, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram, pela requerente ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos e outros, o Dr. Pedro Paulo Salles Cristófaro; pela requerente ABRAMUS - Associação Brasileira de Música e Artes, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10914116

Dr. Roberto Corrêa de Mello; pela requerente Associação de Músicos, Arranjadores e Regente AMAR – SOMBRÁS – Sociedade Musical Brasileira, o Dr. Carlos Fernando Mathias de Souza; pelo *amicus curiae* União Brasileira de Editoras de Músicas – UBEM, o Dr. Sydney Limeira Sanches; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Procure Saber – APS, o Dr. Rodrigo Brandão Viveiros Pessanha; e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 28.04.2016.

Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 10914116

27/10/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

VOTO - VISTA

Embora desnecessário, esclareço o pedido de vista formulado em 28 de abril de 2016, declarando-me habilitado a votar em 2 de maio seguinte. Em meio às sustentações, apreciando a espécie na bancada, já que não recebo com antecedência voto do Relator, formei convencimento sobre a controvérsia. Eis que fui surpreendido com elogios à Lei nº 12.853/2013, no que veio a modificar a Lei nº 9.610/1998. O voto do Relator no sentido da improcedência dos pedidos formulados nas iniciais das ações diretas de inconstitucionalidade foi acompanhado, com louvor, pelos demais integrantes. Ante a sinalização de que estaria equivocado na concepção formada como vogal, entendi por bem pedir vista para proceder a exame mais aprofundado, o que busquei fazer imediatamente, para não truncar, projetando no tempo, o desfecho do julgamento.

A Lei nº 12.853/2013 alterou os artigos 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescentando os artigos 98-A, 98-B, 98-C, 94-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A, considerada a Lei nº 9.610/1998, e revogou o artigo 94 dela constante.

A Constituição Federal está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, submetendo a todos indistintamente, ou seja, as pessoas naturais e jurídicas, de direito privado e público, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Argumentos metajurídicos não implicam a colocação, em segundo plano, de princípios e preceitos nela contidos, sob pena de grassar o subjetivismo, o critério de plantão. Dela extraio que a República Federativa do Brasil tem, como fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, antecedido o inciso IV do artigo 1º da referência à dignidade da pessoa humana. São fundamentos da República:

> I – a soberania;
> II – a cidadania;
> III – a dignidade da pessoa humana;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

> IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
> V – o pluralismo político.

No principal rol das garantias constitucionais, previsto no artigo 5º, constata-se a existência de preceitos umbilicalmente ligados ao que debatido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Nele, sobressai que "a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento" – inciso XVIII. Sem dificuldade, considerado o ato de interpretar, colhe-se a liberdade na criação de associações e a vedação peremptória, definitiva à interferência estatal no funcionamento. Em inciso que se segue – o XX –, tem-se, mais uma vez, a homenagem à liberdade ao dispor-se que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".

Desnecessário dizer que associação, como pessoa jurídica de direito privado, não se confunde com seguimentos da Administração Pública, quer direta, quer indireta, nesta compreendidas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Mais adiante, a Constituição Federal revela ser livre a associação profissional ou sindical e não poder a lei exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização respectiva – artigo 8º, inciso I. O inciso II versa a possibilidade de criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a ser definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não se podendo ter abrangência inferior à de um Município. Da mesma forma que ocorre no tocante às associações, quase sempre embriões de sindicatos, o inciso V do citado artigo 8º dispõe que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

No Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira da Constituição de 1988, apontada por Ulysses Guimarães como cidadã, surgem princípios gerais da atividade econômica, evidenciando-se a propriedade privada, a função social da propriedade e a livre concorrência – artigo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

170, incisos II, III e IV. O parágrafo único do artigo 170 veicula que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. No artigo 174, aponta-se o perfil do Estado sob o ângulo normativo e regulador da atividade econômica, aludindo-se ao exercício, na forma da lei – princípio da legalidade, tão caro nas sociedades ditas democráticas –, das funções de fiscalização, incentivo e planejamento. No tocante a este último, assinala-se ser determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

A Constituição Federal de 1988 deu ênfase ao campo dos direitos individuais, tanto que se mostrou a primeira a versá-los, antes mesmo da disciplina alusiva à estrutura do próprio Estado. O que se nota, considerada a Lei nº 12.853/2013? A ênfase ao objetivo a ser alcançado, em detrimento do meio, e o que é pior: com inobservância a princípios e garantias constitucionais.

Transcrevo, para efeito de documentação, os preceitos impugnados, referidos no parecer da Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.062:

> Art. 5º
>
> […]
>
> XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão." (NR)
>
> Art. 68.
>
> § 6º. O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede.
>
> § 8º. Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6º será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

fonogramas utilizados no mês anterior." (NR)

Art. 97

§ 1º. As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função social.

§ 2º. É vedado pertencer, simultaneamente, a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza.

§ 3º. Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de origem.

§ 4º. As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.

§ 5º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente as associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo.

§ 6º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo. (NR)

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

§ 1º. O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.

§ 2º. As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma.

§ 3º. Caberá às associações, no interesse dos seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.

§ 4º. A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.

§ 5º. As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual.

§ 6º. As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras.

§ 7º. As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações.

§ 8º. Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento.

§ 9º. As associações deverão disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de direitos, dos valores arrecadados e distribuídos.

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 ([…]) anos, devendo ser distribuídos à medida da sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

identificação.

§ 11. Findo o período de 5 ([...]) anos previsto no § 10 sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim.

§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.

§ 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 ([...]) anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição.

§ 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros.

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no *caput* e no § 3º deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 ([…]) horas de antecedência de sua prática.

§ 16. As associações, por decisão do seu órgão de deliberação e conforme máximo previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% ([…]) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva (NR)

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará:

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição;

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações:

a) cadastros das obras e titulares que representam;

b)contratos e convênios mantidos com usuário de obras de seus repertórios, quando aplicável.

c) estatutos e respectivas alterações;

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias;

e) a) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes;

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável;

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável;

h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável;

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de 1 ([...]) ano e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos do art. 100;

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica dos associados;

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados;

III – outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte.

§ 1º. Os documentos e informações a que se referem os incisos II e III do *caput* deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura.

§ 2º. *A* habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

instituídos por esta Lei e por seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei, assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público.

§ 3º. A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se concederá prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente.

§ 4º. A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora.

§ 5º. A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente, ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§ 6º. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

documentos e as informações previstos nos incisos II e III deste artigo.

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão:

I – dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;

II – dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua retenção;

III – buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos;

IV – oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço dos seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica;

V – aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição;

VI – garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade;

VII – garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser atualizadas periodicamente, em intervalo nunca superiora 6 ([...]) meses.

Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados.

§ 1º. O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado.

§ 2º. Se as contas não forem prestadas na forma do § 1º, o pedido do associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na forma do regulamento.

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

§ 1º. O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra.

§ 2º. O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário dos titulares a eles vinculados.

§ 3º. O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário.

§ 4º. A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% ([...]) dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. ([...]), até que, em 4 ([...]) anos da data de publicação desta Lei,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

ela não seja inferior a 85% ([...]) dos valores arrecadados.

§ 5º. O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.

§ 6º. A inobservância da norma do § 5º tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis.

§ 7º. Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos.

§ 8º. Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram.

§ 9º. O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 98. (NR)

Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o *caput* do art. 99 deverá admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública Federal na forma do art. 98-A.

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador.

Art. 99-B. As associações referidas neste Título estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em legislação específica que trate da prevenção e repressão às infrações contra

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

a ordem econômica.

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, 1 ([...]) vez por ano, às suas expensas, após notificação, com 8 ([...]) dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa associação autoral a seus representados. (NR)

Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais respondem solidariamente, com seus bens particulares, por desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os associados, por dolo ou culpa.

Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuirão, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível.

Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no § 6º do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos termos do regulamento desta Lei, a multa de 10% ([...]) a 30% ([...]) do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos.

Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste Título.

Pinço dos artigos acima referidos os mais emblemáticos quanto à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

inconstitucionalidade. O inciso XIV inserido no artigo 5º da Lei nº 9.610 veio a disciplinar, de forma abrangente, o que se entende como titular originário da obra intelectual. Indicou que o são não só o autor da obra intelectual como também o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. Eis condomínio que conflita com textos constitucionais, mais precisamente os dos incisos XXVII e XXVIII do artigo 5º:

> XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
>
> XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
>
> a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
>
> b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

O preceito da alínea "b" versa o direito de fiscalização e não pode ser interpretado a ponto de transmutar-se a titularidade única do autor da obra intelectual em coletiva, presente o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. Sob o ângulo da liberdade de associação e também do autogoverno desta última, com os artigos a partir do 97, em síntese, a Lei nº 12.853/2013 encerra interferência a alcançar não só a dignidade da pessoa humana, a autodeterminação, predicado inerente à referida dignidade, como também o autogoverno das associações. Proibiu-se o ato de associar-se, simultaneamente, a mais de uma associação, considerada gestão coletiva de direitos da mesma natureza. Admitiu-se a transferência, a qualquer momento, de associação, impondo-se a comunicação à de origem. Apontou-se que apenas os titulares originários de direitos do autor ou de conexos diretamente filiados às associações poderão votar ou ser votados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

nestas últimas. Com isso, olvidou-se que a regência da matéria há de estar nos estatutos da associação ante a liberdade constitucional de o seguimento organizar-se. Também dispôs-se que somente titulares originários de direitos do autor ou de conexos podem assumir, nas associações, cargos de direção. Vê-se que o legislador ordinário substituiu-se, sob o ângulo do autogoverno, às próprias associações, interferindo de modo impróprio, porque inconstitucional, na governança destas.

O artigo 98 foi além, veiculando substituição processual que conflita com a interpretação emprestada pelo Supremo ao inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal. Os precedentes são no sentido de exigir-se autorização expressa e específica para que as associações atuem como substitutas processuais. Decorreram da clareza do texto do inciso XXI do artigo 5º: "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". O previsto no artigo 98 revela a representatividade substitutiva a partir da simples filiação. O § 1º do citado artigo disciplinou a necessidade de a associação, para existir juridicamente, obter habilitação em órgão da Administração Pública federal, remetendo o mencionado parágrafo aos requisitos versados, para essa habilitação, no artigo 98-A. Seguem-se dispositivos a revelaram a interferência da Administração Pública no dia a dia da associação, vindo-se, até mesmo, a cogitar-se da duração do mandato dos dirigentes e da impossibilidade de se candidatarem a mais de uma eleição. O § 15 do artigo 98 condicionou a atuação dos titulares de direitos autorais, dos direitos substanciais, alfim, aqueles que são de início legitimados para praticar atos, visando a proteção das obras criadas, à comunicação prévia a associação, invertendo-se a ordem no tocante à legitimação. Os artigos que se seguem ao 98, individualizados pelo número e uso do alfabeto, estão umbilicalmente ligados à intervenção do poder público na associação, surgindo inconstitucionais ante o fato de o inciso XVIII do artigo 5º da Carta da República vedar toda e qualquer interferência estatal no funcionamento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

A nova disciplina inverte situações. Maltrata a autonomia individual, praticamente transforma, em que pese a manutenção da nomenclatura, associação em autarquia. Implica interferência normativa e prática em entidade que se quer livre da ingerência do Estado.

Há de ter-se presente o princípio invencível da supremacia da Carta Federal, os alicerces dela constantes, no que fundam e vinculam a ordem normativa, especialmente consideradas liberdades consagradas. Em termos de direitos fundamentais, não pode haver tergiversações, no que estão previstos com densidade, a afastá-las. A intervenção do Supremo impõe-se toda vez que verificado descompasso – no caso, flagrante – entre a norma legal e o ditame constitucional. Inexiste, ante o princípio lógico do terceiro excluído, o meio-termo.

A liberdade de autogoverno das associações, no que protegidas da interferência do Estado, está pedagogicamente e em bom vernáculo versada no principal rol das garantias constitucionais – o do artigo 5º, mais precisamente no inciso XVIII. Tem-se, com isso, o enaltecimento de valores políticos, morais, culturais e sociais de essencialidade maior. Os fins constitucionais fazem-se em jogo. Vive-se a era da democracia constitucional, prevalecendo o autogoverno, a ideia de autodeterminação coletiva como condição de uma sociedade livre. A liberdade é pressuposto da democracia. Onde não houver liberdade, imperará o arbítrio, antítese da ideia de Estado Democrático de Direito. O sistema político-constitucional limita o poder delegado aos representantes – deputados e senadores. Essa é a síntese dialética entre democracia e constitucionalismo. Tirania e paralisia estatais são extremos a serem combatidos. Na quadra atual, cabe ao Judiciário combater esses extremos, seja bloqueando medidas estatais hostis aos direitos fundamentais, seja impondo comportamentos positivos ao Estado em favor desses direitos.

Em última análise, cumpre ao Supremo essa atuação: de bloqueio e de catalisador. O intérprete há de estar atento às diferenças estruturais e teleológicas dos comandos constitucionais. Este Tribunal não pode ser um meio guardião da Constituição Federal porque, se o for, o copo estará invariavelmente meio cheio ou meio vazio, a depender das preferências

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

ideológicas de cada um. Razões pessoais hão de ceder, sempre e sempre, às previsões constitucionais. Deve-se impor ao Estado o cumprimento de deveres positivos em favor da efetividade dos direitos sociais, sob pena de prevalência de posturas demagógicas e que longe estão de contribuir para o desejável avanço cultural.

Reafirmando que, em Direito, o meio justifica o fim mas não este àquele, tenho como inconstitucional a disciplina dos direitos autorais e da existência das associações respectivas advindas da Lei nº 12.853/2013. Julgo procedentes os pedidos formalizados nas ações diretas de inconstitucionalidade, ficando restabelecida, na plenitude, a regência decorrente da Lei nº 9.610/1998 tal como apanhada pelo diploma legal impugnado, ou seja, pela Lei nº 12.853/2013.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11968801.

27/10/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhora Presidente, peço vênia ao Ministro **Marco Aurélio** e acompanho o Relator e os demais que com ele somaram.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12039374.

27/10/2016 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, o Ministro Marco Aurélio traz, como sempre, um voto extremamente denso e substantivo, que nos faz meditar. Sua Excelência traz à colação justamente a liberdade de associação, que é amplamente assegurada na nossa Carta Magna, na Constituição Cidadã de 1988.

No entanto, eu ouso discordar do eminente Ministro Marco Aurélio, não obstante o brilho de seus argumentos, entendendo que aí se aplicam ou se sobrepõem outros dispositivos constitucionais que talvez superem essa amplíssima liberdade do direito de associação ao qual Sua Excelência alude.

De início, eu gostaria de me reportar ao que se contém no art. 215 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte:

> "Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais" - e nós estamos aqui tratando de direitos culturais - "e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais".

Então, desde logo, eu vejo aqui uma autorização expressa do constituinte para a intervenção do Estado nesse domínio fundamental que é o da cultura.

Como todos nós sabemos, desde os tempos de Clóvis Beviláqua - para ficarmos apenas no exemplo brasileiro -, o direito autoral é de natureza patrimonial, regulada pelo Direito Civil. É claro que é um direito de propriedade de natureza especial, mas, como tal, e por apresentar esse caráter - e isso está na nossa Constituição também, no art. 5º, nos seus distintos incisos -, a propriedade desempenha uma função social. Assim ela também não é absoluta, e, aí, mais uma vez, com base nesta perspectiva, se autoriza a intervenção do Estado nesse tipo de propriedade de natureza especialíssima, que é o direito autoral. Portanto, eu vejo que há fundamentos constitucionais para que o Estado regule a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12049392.

matéria tal como o fez.

Num primeiro momento, sabemos todos, o direito autoral foi regulado pela Lei 9.610/98, que durou um certo tempo, mas apresentou deficiências e foi substituída depois, ou alterada em parte, pela Lei 12.853/2013. E o Ministro Luiz Fux, no seu voto, nos trouxe um interessantíssimo esquema, em que Sua Excelência, que foi o Relator destes feitos, mostra que, antes da Lei 12.853, portanto sob a vigência da Lei 9.610/98, existiam algumas distorções. Havia pouca transparência, preços abusivos no licenciamento, altas taxas de administração, barreiras à entrada de novas associações, fraudes e ambiguidades no registro de obras, incentivo à litigiosidade etc.

Aí vem esta nova normativa que procura corrigir tais vícios, estas distorções trazendo uma maior publicidade, o fim do licenciamento exclusivo pelo *blanket license*, que é aquela licença abrangente, limites máximos para taxas de administração, liberdade de criação de novas associações, evitando o monopólio daquelas já existentes, transparência e supervisão do Ministério da Cultura quanto ao registro de obras, a intervenção do Estado e, finalmente, mecanismos de mediação e arbitragem, matérias que estão justamente na ordem do dia. O novo CPC incentiva a conciliação e a mediação em substituição à litigiosidade, à essa cultura de conflituosidade que impera no País e que faz com que tenhamos mais de cem milhões de processos em tramitação.

Portanto, com essas brevíssimas considerações, Senhora Presidente, entendo legítima a intervenção do Estado, com arrimo em diversos dispositivos constitucionais, e, logo, absolutamente compatível com a Carta Magna, *data venia* do Ministro Marco Aurélio, a Lei 12.853, naquilo que introduziu alterações na Lei 9.610/98.

É como voto, acompanhando o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12049392.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ABRAMUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS, ARRANJADORES E REGENTE AMAR - SOMBRÁS - SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA
ADV.(A/S) : CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA (000530/DF) E OUTRO(A/S)
REQTE.(S) : ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS
REQTE.(S) : SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - SBACEM
REQTE.(S) : SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM
REQTE.(S) : SOCINPRO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS INTELECTUAIS
REQTE.(S) : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
ADV.(A/S) : PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO (60962/RJ) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : UNIÃO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICAS - UBEM
ADV.(A/S) : SYDNEY LIMEIRA SANCHES (66176/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PROCURE SABER - APS
ADV.(A/S) : RODRIGO BRANDAO VIVEIROS PESSANHA (0107152/RJ) E OUTRO(A/S)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deliberou adiar o julgamento do feito. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 14.04.2016.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que rejeitava as preliminares, conhecia integralmente da ação e julgava improcedentes os pedidos formulados, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, o Ministro Dias Toffoli, participando, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na VIII Conferência Ibero-americana sobre a Justiça Eleitoral, promovida pelo Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA Internacional) e pelo Tribunal Superior Eleitoral, realizada em Manaus, Amazonas, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram, pela requerente ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos e outros, o Dr. Pedro Paulo Salles Cristófaro; pela requerente ABRAMUS - Associação Brasileira de Música e Artes, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 11983313

Dr. Roberto Corrêa de Mello; pela requerente Associação de Músicos, Arranjadores e Regente AMAR – SOMBRÁS – Sociedade Musical Brasileira, o Dr. Carlos Fernando Mathias de Souza; pelo *amicus curiae* União Brasileira de Editoras de Músicas – UBEM, o Dr. Sydney Limeira Sanches; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Procure Saber – APS, o Dr. Rodrigo Brandão Viveiros Pessanha; e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 28.04.2016.

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedentes os pedidos formulados, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 27.10.2016.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 11983313